العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

• المذكـرة الأساسيـة •

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

- تأصيل تحليلي
- تطبيقات قضائية
- صياغة أكاديمية

مـدنـي (عقد البيع)

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثالثة

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

عقد البيع

المحاور الآتية

التعريف بالعقد	أركان العقد	آثار العقد	التزامات العقد

العقود المسماة وغير المسماة: تنقسم العقود من حيث تنظيم المشرع لها إلى نوعين، ويؤيد ذلك العنصران الآتيان:

العقود المسماة: التي حظيت بتنظيم المشرع وبيان قواعدها الخاصة لأهميتها العملية وكثرة تداولها — كالبيع، الإيجار، الشركة، الوكالة، التأمين، العمل، المقاولة.

العقود غير المسماة: التي لم يرد لها تنظيم خاص — كعقد النشر، النزول في فندق، العلاج مع مستشفى أو طبيب.

حكم غير المسماة: لا تقبل الحصر (شبه إجماع)، ويحكمها ما يتراءى للمتعاقدين وفقاً للقواعد العامة في نظرية العقد (المواد 89-161 مدني)؛ فإن لم يوجد نص رجع إلى مصادر التشريع الأخرى: العرف، مبادئ الشريعة الإسلامية، مبادئ العدالة والقانون الطبيعي.

تطور قائمة المسماة: تختلف بين الدول، وتزيد وتنقص باختلاف الزمن في الدولة الواحدة بحسب أهمية العقود — فالقانون المدني القديم لم يكن يورد التأمين ضمنها، وأورده الجديد، ولا يضع الجديد تنظيماً خاصاً لعقود زادت أهميتها — كالنشر والنزول في فندق — مع أنها مسماة في بعض الدول.

العقود المسماة في المجموعة المدنية: **اثنان وعشرون عقداً** في خمس مجموعات:

1. **العقود الواردة على الملكية:** البيع، المقايضة، الهبة، الشركة، القرض، الصلح.
2. **العقود الواردة على الانتفاع:** الإيجار، العارية.
3. **العقود الواردة على العمل:** المقاولة، التزام المرافق العامة، عقد العمل، الوديعة.

4 **العقود عقود الغرر (الاحتمالية):** المقامرة، الرهان، المرتب مدى الحياة، التأمين، **الأولان:** المشرع نظم **بطلانهما** ؛ **الآخران:** نظم أحكامهما عامة لأنهما غير مخالفين للنظام العام من وجهة نظره «التأمين محطة بحث هذا العام»

5 **عقود التأمينات:** التأمينات الشخصية كالكفالة؛ والعينية كالرهن الرسمي والحيازي، **ملاحظة:** عولج هذان الأخيران في باب الحقوق العينية التبعية لا العقود؛ لارتباطهما الوثيق بالحق العيني الناشئ عنهما: فالرهن حق شخصي (رابطة بين دائن ومدين)، لكنه ينشأ عنه حق عيني تبعي يعطي الدائن سلطة تتبع الشيء المرهون، والأفضلية على سائر الدائنين العاديين أو المرتهنين المتأخرين في المرتبة.

مشروعية البيع في التشريع الإسلامي: مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

الكتاب: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» — تحل البيع وتجعله مشروعاً،

السنة: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء»

الإجماع: أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة.

تعريف البيع وتمييزه عما يختلط به

أولاً ← تعريف عقد البيع:

تعريف المشرع (م 418 مدني): **"البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل المشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر ثمن نقدي،"**

المذكرة الإيضاحية – ميزتان عن تعريف القانون القديم: أوردت المذكرة الإيضاحية ميزتين للتعريف الجديد عن تعريف القانون القديم، ويؤيد ذلك العنصران الآتيان:

1 **المحل:** لا يقتصر على نقل الملكية بل يتعداه إلى أي حق مالي آخر (حق انتفاع، حق ارتفاق)، وقد يقع في حقوق شخصية (حوالة الحق).

2 **الثمن:** لابد أن يكون من النقود — وصف جوهري يميز البيع عن المقايضة.

! **ملاحظة – بخلاف الشريعة:** البيع مبادلة مال بمال، فيشمل المقايضة والصرف والسلم.

ما يستفاد من التعريف: يستفاد من التعريف أن البيع عقد رضائي وملزم للجانبين ومن عقود المعاوضة، ويؤيد ذلك العناصر الآتية:

1. **عقد رضائي:** لم يشترط شكلاً خاصاً.
2. **ملزم للجانبين:** البائع ينقل الملكية، المشتري يدفع الثمن.
3. **من عقود المعاوضة:** كل طرف يتلقى عوضاً عما يبذله.

تلافي النقد الموجه لتعريف القانون القديم: يكشف التعريف عن تلافي النقد الموجه لتعريف م 235 القديم: "عقد يلتزم به أحد المتعاقدين نقل ملكية شيء للآخر في مقابل التزام ذلك الآخر بدفع ثمنه المتفق عليه" — وقد أُخذ عليه قصره محل البيع على ملكية الأشياء فقط، مع أن البيع يرد على أي حق مالي آخر (حق انتفاع، ارتفاق، حقوق الدائنين، الملكية الأدبية)، وقد تلافى التعريف الجديد هذا النقد فأدخل هذه الأشياء في محله.

ما يؤخذ على التعريف: وجه الفقه إلى التعريف نقدين رئيسيين، ويؤيد ذلك العنصران الآتيان:

1. **إغفال انتقال الملكية بمجرد العقد:** أهم أثر في القانون الحديث، وقد نص عليه التقنين الملغى صراحة (م 91/145، 92/146)، ووفقاً لم 204 الحالي (الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم، دون إخلال بقواعد التسجيل).
   الرد: التعريف وإن أغفل المادة يتضمن نقل الملكية أو الحق العيني فعلاً، ولا يقتصر دوره على إنشاء التزام بالنقل، ويضيف بعض الفقهاء: انتقال الملكية ليس أثراً للبيع، بل أثر للالتزام بنقل الملكية الذي ينشئه البيع.
2. **التعريف بالأثر معيب منطقياً:** المنطق يقضي بأن يكون التعريف ببيان الماهية (الأركان والعناصر المكونة)، لا بالآثار؛ وجوهر العقد ليس الأثر بل التراضي (بدقة).
   رأينا: التعريف بالأثر معيب منطقياً، لكنه عملياً وواقعياً غير معيب؛ فالالتزام بنقل الملكية والالتزام بالثمن — وهما جوهر الآثار — لا يتصور وجودهما دون إرادة تعطيهما شهادة الميلاد، ولولا الإرادة الموجودة فعلاً لما كان لتلك الآثار أثر، وقد عبر المشرع عن هذا بـ"يلتزم به البائع" — ما يفصح عن اتجاه إرادته نحو هذا الالتزام، فيكون تعريفاً صحيحاً.

الشريعة الإسلامية: البيع يترتب عليه نقل الملكية بذاته — من قبيل ترتيب المسبب على السبب؛ فإذا كان العقد سبباً للملك كان الملك مسبباً عنه.

ثانياً ← خصائص عقد البيع:

1. **عقد رضائي:** ينعقد بمجرد اتفاق الطرفين دون إجراء شكلي، يستوي أن يكون كتابة أو مشافهة أو إشارة أو موقفاً لا تدع ظروفه شكاً، ويجوز أن يكون صريحاً أو ضمنياً (م 90 مدني)، وليس عقداً عينياً — ينعقد دون تسليم المبيع أو دفع الثمن، وكل ما يشترطه القانون هو وجوب إثباته كتابة إذا زادت قيمة الالتزام عما حدده قانون الإثبات (م 60 من قانون الإثبات).

ملاحظة: يظل رضائياً ولو كان ساتراً لوصية — فلو كانت الوصية مستورة في عقد بيع فلا محل للنص بأنه لم يستوف الأركان الشكلية للوصية؛ لأن العبرة بشكل العقد الساتر لا المستور، والرضائية ليست من النظام العام، فيجوز الاتفاق على خلافها.

2. **من أعمال التصرف:** الرضا لا يصدر إلا من شخص له أهلية التصرف — بائعاً أو مشترياً.

3. **عقد ملزم للجانبين:** يرتب التزامات متبادلة: البائع بنقل الملكية والتسليم والضمان؛ المشتري بدفع الثمن، ويترتب عليه: لكل طرف أن يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم الآخر بالتنفيذ أو بعرض الوفاء (م 1/246 مدني)، ولكل منهما طلب الفسخ عند عدم التنفيذ (م 157).

4. **عقد معاوضة:** يتم مقابل ثمن نقدي — يلزم الاتفاق على مقابل هو الثمن، وأن يكون من النقود، فلو عدم الثمن كان العقد هبة، وتتحقق الصورة العملية لانعدام الثمن بإحدى صورتين، ويؤيد ذلك الفرعان الآتيان:

1. **الثمن الصوري:** تحديد ثمن دون أن يلتزم المشتري بأدائه فعلاً — بإعفاء باتفاق مستتر.

2. **الثمن المعدوم حكماً:** تقدير ثمن يبلغ من عدم التناسب مع قيمة المبيع حداً يجعله في حكم المعدوم،

النتيجة في الحالتين: فلو كان كذلك لكان هبة لا بيعاً، ومن ثم تسري عليه الأحكام الموضوعية للهبة — ومنها م 1/488: "تكون الهبة بورقة رسمية إلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر،"

MARA 01105405478

5. **ناقل للملكية:** ينقل الملكية — على شيء معين أو أي حق مالي آخر (م 418)، وينقلها بذاته وفور نشوئه إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم (م 204)، م 932: الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول تنتقل بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف، وفقاً لم 204.

تأخر نقل الملكية: في بيع المنقول المعين بالنوع — يتراخى إلى وقت الإفراز، وفي بيع العقار — تتراخى إلى ما بعد التسجيل، إلا أن البائع يلتزم بمقتضى العقد بكل ما يلزم لتمكين المشتري من التسجيل.

6. **خصائص أخرى:** للبيع ثلاث خصائص أخرى، ويؤيد ذلك الفروع الآتية:

1. **محدد القيمة:** كل طرف يعلم وقت الانعقاد مقدار التزامه إعطاءً ومقدار حقه أخذاً — إلا في بعض صوره: كالبيع في مقابل إيراد مرتب مدى الحياة (مقدار الثمن مرتبط بمدى حياة البائع، فيزيد بطولها وينقص بقصرها، فتحديده محتمل).
2. **عقد مساومة:** لا يتم إلا بعد أخذ ورد ومناقشة عناصر الالتزام بحرية واختيار — بخلاف عقود الإذعان.
3. **مدني أو تجاري:** مدني إذا كان موضوعه عملاً مدنياً، تجاري إذا كان مضمونه عملاً تجارياً.

> **استثناءات الرضائية:** تظل الرضائية هي الأصل في البيع، لكن القانون يشترط شكلاً خاصاً في حالات معينة، ويؤيد ذلك الاستثناءات الآتية:

1. **بيع السفن البحرية:** م 3 من قانون التجارة البحري: بيع السفينة كلها أو بعضها اختياراً يلزم أن يكون بسند رسمي سواء حصل قبل السفر أو في أثنائه، وإلا كان البيع لاغياً.
2. **الثمن على هيئة مرتب مدى الحياة:** م 743: البيع لا يكون صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً.
3. **التصرف في حق المؤلف:** م 2/37 من القانون 354/1945: كل تصرف يرد على حق المؤلف في استغلال مصنفه لا ينعقد إلا بالكتابة.
4. **ورود البيع على عقار:** بعد قانون التسجيل 1923 (ألغاه قانون الشهر العقاري 114/1946، الصادر 11/8/1946، العامل من 1/1/1947)، م 13 منه: وجوب شهر التصرفات الناقلة للملكية بين الأحياء.

⚠ **الخلاف حول رضائية بيع العقار:** ذهب الفقه إلى رأيين في تكييف بيع العقار بعد تحتم التسجيل، ويؤيد ذلك الآتي:

1 **الرأي الأول:** أصبح عقداً شكلياً لا يتم إلا بالكتابة، والتسجيل لازم لنقل الملكية — بالنسبة للمتعاقدين وللغير.

✓ **الراجح:** يظل رضائياً ولو ورد على عقار؛ فتحتيم التسجيل يقتضي تدوينه في محرر — لأن التسجيل لا يرد على العمل القانوني في ذاته بل على المحرر المثبت له، وقد تبدد الفهم الذي شابه، وانعقد إجماع الفقه على أن القانون لم يغير من طبيعة البيع الرضائية، وإنما اشترط التسجيل لنقل الملكية فحسب، فبيع العقار ينعقد كبيع المنقول بمجرد التراضي، والكتابة أداة إثبات تجعله صالحاً للتسجيل؛ فإذا لم يدون جاز إثباته بالإقرار أو اليمين أو غيرهما وفقاً لقواعد الإثبات، وقام الحكم المثبت له مقام المحرر الذي يصدر من الطرفين من حيث التسجيل.

📖 **الخصائص في الشريعة الإسلامية:** الخصائص تكاد تتطابق، لولا فرقين، ويؤيد ذلك العنصران الآتيان:

1 **الفرق الأول:** البيع ناقل للملكية بذاته.

2 **الفرق الثاني:** المعاوضة لا يتحتم أن تكون نقوداً.

📖 **نص المادة 507 من التقنين المدني العراقي:** "البيع باعتبار المبيع إما أن يكون بيع العين بالنقد، وهو البيع المطلق، أو النقد وهو الصرف، أو بيع العين بالعين وهو المقايضة."

ثالثاً ← تمييز البيع عما يختلط به:

ℹ **تمهيد:** البيع ناقل للملكية أو منشئ لالتزام بنقلها — يختلف عن الإيجار والمقاولة والوكالة؛ ونقل الملكية فيه بمقابل — يختلف عن الهبة والمقايضة والوصية.

1 الفرق بين البيع والإيجار:

📖 **الإيجار هو:** **"عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم،"** فمضمون الالتزام الجوهري: تمكين المستأجر من الانتفاع.

✨ **الفرق الجوهري:** تختلف آثار كل من البيع والإيجار، ويؤيد ذلك العنصران الآتيان:

MARA 01105405478

1. **البيع:** ينقل الملكية — يخلف المشتري البائع فيها، فأثره **حاسم** .
2. **الإيجار:** المستأجر لا يكون خلفاً للمؤجر بل دائناً له بالانتفاع، فأثره **مؤقت** .

⚠ **الالتباس:** يختلف الحال في الالتباس بحسب طبيعة المعقود عليه:

1. **المال المادي:** لا وجه للالتباس إذا كان المعقود عليه مالاً مادياً (حق ملكية شيء مادي) — لوضوح الفرق بين قصد نقل الملكية وقصد مجرد إلزام المالك بالتمكين من الانتفاع مع بقاء الملكية.
2. **المال المعنوي:** يدق الالتباس إذا كان المعقود عليه مالاً معنوياً — خاصة حقاً شخصياً يخول المنفعة (كالحق في أخذ ثمار العين أو حاصلاتها مدة معينة)، فيختلط البيع بالإيجار، ويصبح التكييف غير هين مع أنه لا مفر منه لاستجلاء الطبيعة وتطبيق الأحكام.

أهمية التكييف: تظهر أهمية التكييف في الآثار المترتبة على كل تكييف:

1. **إن كان بيعاً:** كان قابلاً للإبطال لعدم ملكية البائع، وينتهي حق المشتري بانتهاء المدة المتفق عليها، وكان للبائع حق امتياز على المبيع.
2. **إن كان إيجاراً:** لم يكن قابلاً للإبطال بسبب عدم ملكية المؤجر، وكان قابلاً للتجديد فقط، ولا امتياز للبائع إذا كان المعقود عليه عقاراً، وامتياز البائع يختلف عن امتياز المؤجر في مداه وأحكامه.

1. **الحالة الأولى: النزول عن الحاصلات والثمار في مقابل ثمن نقدي:** اختلف الفقه في تكييف هذه الحالة ونعرض الأراء:

NARA 01105405478

1 **التفرقة بين الثمار والحاصلات:**

- **الحاصلات** (منتجات غير دورية تنتقص من الأصل — كأحجار المحجر وأشجار الغابة) ← بيع لمنقول بحسب المآل.
- **الثمار** (دورية متجددة لا تنقص الأصل) ← إيجار.

الحجة: الإيجار يهدف لتمكين الانتفاع، وجوهره رد الشيء بالحالة التي كان عليها (م 591)، والحاصلات تنقص من الأرض فهي جزء منها ومآلها للزوال يوماً ما.

النقد: لا مانع في العقد الوارد على الثمار أن تتجه نية المالك إلى بيع الثمار ذاتها لا مجرد الالتزام بتمليك الطرف الآخر أخذ الغلة؛ والعقد الوارد على الحاصلات يمكن اعتباره إيجاراً إذا كان أخذها هو الطريق الطبيعي لاستغلال العين.

2 **التفرقة بين ناضجة وغير ناضجة:** إن كان النزول عن ثمار ناضجة معدّة للنقل ← بيع؛ وإن اقترن بالتزام المتنازل إليه بالعمل على إنمائها وإنضاجها وحصرها ← إيجار.

النقد: لا مانع في البيع من أن يلتزم المشتري ببعض الأعمال اللازمة لإنتاج المبيع.

3 **طبيعة الآثار الناشئة:** إن كان من شأنه نقل ملكية حق ثابت في ذمة المتصرف ← بيع؛ وإن اقتصر على إنشاء التزام بتمكين المتصرف إليه من أخذ الثمار ← إيجار

النقد: الآثار نتيجة لاتجاه إرادة العاقدين لا أكثر، والمسألة كلها في معرفة ما اتجهت إليه إرادتهما.

4 **العبرة بقصد المتعاقدين (قوي):** الآثار التي لا شك في اتجاه القصد إليها يمكن الاستدلال بها على التكييف، للاستعانة به على تنظيم الآثار التي لم يثبت اتجاه القصد إليها، وظروف التعاقد وأحكامه الواضحة قرائن قضائية مؤقتة دالة على حقيقة التكييف الذي اتجهت إليه الإرادة — ترجح أحد التكييفين إلى أن يثبت العكس.

مثال: العقد على حق أخذ الحاصلات (غير المتجددة) قرينة على البيع ما لم يثبت من ظرف آخر اتجاه الإرادة للإيجار؛ والعقد على أخذ ثمار الأرض كلها (متجددة) قرينة على الإيجار لا البيع؛ فإذا كان محل العقد نوعاً معيناً من الثمار فقط فالراجح البيع، إلا إذا تعهد المتصرف إليه بإنماء هذه الثمار وإنضاجها على نفقته — فيرجح الإيجار.

2 **الحالة الثانية: البيع الإيجاري:** اتفاق طرفيه على أن يسلم أحدهما شيئاً معيناً للآخر مقابل دفع مبلغ دوري متجدد لمدة معينة، ويعتبران هذا المبلغ أجرة انتفاع، فإذا وفى المتصرف إليه بجميع الأقساط المتفق عليها انتقلت إليه الملكية وانقلب العقد بيعاً واعتبرت الأجرة أقساطاً

للثمن؛ وإذا تخلف عن قسط حل ميعاد استحقاقه رد الشيء لمالكه مع حق المالك في الاحتفاظ بما سبق دفعه من أقساط بوصفها أجرة قبضت نظير الانتفاع طوال المدة.

مثال: تاجر أدوات كهربائية يؤجر لعميله ثلاجة بمائة جنيه شهرياً، وعلى أنه إذا وفى المستأجر كاملة تملكها في نهاية المدة دون دفع شيء آخر.

أهمية التكييف: يظهر أثر التكييف في حماية البائع، ويؤيد ذلك العنصران الآتيان:

1. **بوصفه إيجاراً:** يظل مؤجراً يحتفظ بالملكية ويستطيع استرداد الشيء إذا توقف عن الوفاء أو أفلس قبل الوفاء، دون التزام برد ما تسلمه منها على أساس أنه أجره.
2. **لو اعتبر بيعاً:** ففسخه يلزم المشتري برد المبيع والبائع برد ما تسلمه من أقساط.

تكييفه إيجاراً يجعل يد المستأجر يد أمانة: فإذا تصرف للغير عد مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة.

الخلاف قبل التقنين الحالي: اختلف الفقه في تكييف البيع الإيجاري قبل التقنين الحالي، ويؤيد ذلك الرأيان الآتيان:

1. **الرأي الأول:** إيجار وبيع في آن واحد: إيجار معلق على شرط فاسخ، وبيع معلق على شرط واقف — الشرط: الوفاء بجميع الأقساط، فإذا تحقق الفاسخ بتمام الأقساط انفسخ الإيجار، وتحقق الواقف فوجد البيع منتجاً آثاره مستنداً لوقت الاتفاق، واعتبر من تسلم كأنه اشتراه منذ البداية، وإذا تخلف بتخلف الوفاء تأكد الإيجار وكان البيع كأن لم يكن، واحتفظ المالك بالمبالغ أجرة، **النقد:**
   ❶ تكييف العقد بيعاً وإيجاراً في آن واحد يتنافى مع طبيعة التكييف،
   ❷ يؤدي إلى أن البيع تم بدون ثمن — فالأقساط المدفوعة كانت إيجاراً مقابل الانتفاع، فإذا انقلب إلى بيع كان بلا ثمن، فيكون باطلاً لفقدان ركن أساسي.

الرأي الثاني (الراجح): بيع علق فيه نقل الملكية على شرط واقف (الوفاء بجميع الأقساط) — يتفق مع قصد المتعاقدين الذين قصدا البيع منذ البداية، ولم يكن لوصف العقد إيجاراً أثر سوى كونه وسيلة للحصول على الثمن واستيفاء الأقساط كاملة،
أخذ به المشرع في م 430.

نص المادة 430: تضمنت المادة أربع فقرات تتعلق بالبيع المؤجل الثمن، ويؤيد ذلك الآتي:

1. **الفقرة الأولى – نقل الملكية موقوف على استيفاء الثمن:** **إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله، ولو تم تسليم المبيع،**
2. **الفقرة الثانية – استبقاء جزء تعويضاً عن الفسخ:** **فإذا كان الثمن يدفع أقساطاً جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ البيع إذا لم تُوفَ الأقساط جميعاً، ويخفض التعويض المتفق عليه وفقاً للفقرة الثانية من م 224. ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف...**
3. **الفقرة الثالثة – استناد انتقال الملكية لوقت البيع:** **وإذا وفيت الأقساط جميعاً، فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستنداً إلى وقت البيع،**
4. **الفقرة الرابعة – سريان الأحكام ولو سُمي إيجاراً:** **وتسري أحكام الفقرات السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً،**

المستفاد: حسم الخلاف — بيع بالتقسيط علق فيه انتقال الملكية على الوفاء بكامل الأقساط، ويستند انتقالها عند الوفاء إلى وقت البيع، والتزامات البائع (التسليم، ضمان الاستحقاق، ضمان العيوب الخفية) والتزامات المشتري (تسليم المبيع، تحمل نفقات العقد) منجزة، والتعويض شرط جزائي يستحقه البائع ولو لم يثبت حصول ضرر من الفسخ، ويجوز للقاضي تخفيضه وفقاً لم 224.

الخلاصة: التكييف من خلال مقصد المتعاقدين يتفق مع الشريعة — **العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني** .

٢ الفرق بين البيع والمقاولة:

تعريف المقاولة (م 646): **"عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يضع شيئاً أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر،"** م 647: يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم علمه على أن يقدم رب العمل المادة، ويجوز أن يتعهد بتقديم العمل والمادة معاً، فجواز تقديم العمل والمادة أوجد اشتباهاً — فمن السهل اعتبار المقاول بائعاً للمواد.

ALARA 01054054478

✅ **الراجح (أغلبية الفقه والقضاء):** الأصل في حالة تقديم المادة أن العقد **بيع** ، إلا إذا كانت قيمة المواد أو المهمات ثانوية بالنسبة لعمل المقاول ← **مقاولة** .

1. **الترزي يحيك ثوباً ويورد المواد الأولية البسيطة:** (خيط، أشرطة) ← **مقاولة** — المحل الرئيسي حياكة الثوب، والمواد ثانوية.
2. **الترزي يورد قماش الثوب ذاته:** ← **بيع** لشيء مستقبل — قيمة الأقمشة والمهمات أهم من قيمة العمل.
3. **بناء على أرض رب العمل بأدوات من عند المقاول:** ← **مقاولة** ،المهمات ثانوية بالنسبة للأرض.
4. **تقديم بناء بأدوات من عنده على أرض يقدمها هو:** ← **بيع** ، يغلب عليه وصف البيع.

٣ المبحث الثالث: البيع والوكالة:

📖 **تعريف الوكالة (م 699):** **"عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل،"** محل الوكالة: التزام بعمل؛ ومحل البيع: نقل ملكية شيء أو حق مالي في مقابل ثمن نقدي.

⚠ **صعوبة التفرقة – عقد التوزيع:** يتعهد شخص بتسليم آخر كمية معينة من سلعة ليبعها في مقابل مبلغ معين يؤديه لمنتج السلعة، على أن يلتزم برد ما تبقى دون بيع، فهل الموزع وكيل؟ أم العقد بيع معلق على شرط واقف أو فاسخ (عدم التمكن من البيع خلال مدة محددة)؟

🔑 **أهمية التفرقة:** الوكالة من عقود الأمانة — فإذا بدد الوكيل الأشياء عوقب بخيانة الأمانة؛ والبيع ليس من عقود الأمانة، ولا يعاقب المشتري إذا تصرف فيما سلم إليه مبيعاً.

✅ **الحل – القصد الحقيقي:** العبرة بالقصد الحقيقي للمتعاقدين، ويؤيد ذلك القرائن الآتية:

1. **الاتفاق على نسبة من الثمن:** الاتفاق على أن يأخذ من تسلم الشيء نسبة معينة من الثمن الذي يبيع به ← **وكالة** .
2. **تحديد صاحب الشيء للسعر:** تحديد صاحب الشيء السعر الذي يجب البيع به ← **وكالة** .
3. **احتراف البيع بالوكالة:** احتراف من تسلم الشيء للبيع بالوكالة ← **وكالة** .

٤ **دفع مبلغ محدد مع حق الرد:** دفع مبلغ محدد للمالك بقطع النظر عن الثمن الذي يتمكن من البيع به، مع الاحتفاظ بحق رد الشيء دون دفع المبلغ إذا لم يتمكن من بيعه ← **بيع مقترن بشرط فاسخ** — هو عدم التمكن من البيع للغير.

٤ الفرق بين البيع والهبة:

تعريف الهبة (م 1/486): **"عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض،"** فالهبة تنقل الملكية دون عوض بنية التبرع — **عنصر نفسي** (نية التبرع + قبول) و**عنصر مادي** (نقل المال دون مقابل)، والبيع بعوض، من عقود المعاوضات.

الهبة بعوض (م 2/486): "ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين، فتكون الهبة في تلك الحالة بعوض يجب على الموهوب له أن يؤديه،" فتشبه البيع — المتصرف إليه يلتزم بالعوض ويؤديه كما يلتزم المشتري بالثمن، ويزداد التشابه كلما اقتربت قيمة العوض من ثمن المثل.

التكييف: اختلف الفقه في تكييف الهبة بعوض، ويؤيد ذلك الرأيان الآتيان:

١ **الرأي الأول:** هبة بشرطين: (1) أن يكون العوض أقل من المال الموهوب، (2) نية التبرع، ولا يتنافى التكييف هبة مع وجود العوض — فالمعول نية التبرع، ولا يسوغ القول بأن التصرف بيع في حدود العوض وهبة فيما زاد، فإن كان العوض مساوياً لقيمة المال أو مقارباً ← بيع لا هبة، ولا يستقيم القول بنية التبرع.

٢ **الرأي الثاني:** المعول نية التبرع ولو كان العوض نقدياً كبيراً؛ وإذا لم توجد نية التبرع كان بيعاً ولو كان المقابل أقل قيمة.

الهبة المستترة في صورة عقد آخر (كالبيع): صحيحة، وأعفاها المشرع من شرط الرسمية، وتخضع من حيث الموضوع لأحكام الهبة، ويشترط أن يكون للعقد مظهر للبيع بالفعل — كذكر الثمن في البيع الظاهر، أما إذا حُدد الثمن وذُكر أن البائع أبرأ المشتري منه أو وهبه له، فلا يكون بيعاً بل هبة صريحة، وتكون باطلة إذا لم تفرغ في الشكل المطلوب.

٥ الفرق بين البيع والمقايضة:

📖 **تعريف المقايضة (م 482):** **"عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التبادل ملكية مال ليس من النقود،"** فالمقايضة تتميز عن البيع في أن المقابل فيها ليس من النقود.

⚠ **الالتباس – بداية العقد:** إذا جعل أحد المتعاقدين للآخر الخيار بين بدلين: نقدي وغير نقدي (منزل، سيارة) — لا تعرف الطبيعة عند الإبرام، وتتحدد عندما يختار من له الخيار.

⚠ **الالتباس ابتداءً وانتهاءً:** إذا كان أحد البدلين مكوناً من عنصرين: نقدي وغير نقدي (سيارة جديدة مقابل سيارة قديمة + مبلغ نقدي)، **الحل:** بالعنصر الغالب — فإن كان النقدي غالباً ← بيع؛ وإن كانت السيارة القديمة غالباً ← مقايضة.

ℹ **حالات لا لبس فيها:** توجد حالات لا يثور فيها خلاف في التكييف، ويؤيد ذلك الآتي:

1. **سبيكة ذهبية أو ورقة مالية:** مقايضة — رغم سهولة تحويلها إلى نقد (كبيع سيارة بسبيكة ذهبية وخمس سندات).
2. **إيراد مرتب مدى الحياة:** بيع — ولو كان الثمن محدداً بطريقة احتمالية، ما دام الإيراد من النقود،

ملاحظة: ومع ذلك: الثمن لا يتمثل في الأقساط التي يدفعها المشتري بل في الحق في الإيراد المرتب للبائع — ما يدعو للقول بأنه في حقيقته مقايضة لا بيعاً؛ لكن الرأي استقر في الفقه والقضاء على اعتباره بيعاً.

📖 **الشريعة الإسلامية:** المقايضة صورة من صور البيع.

٦ الفرق بين البيع والوصية:

📖 **الوصية (م 1 من قانون الوصية):** **"تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت،"** تصرف بإرادة منفردة، ليست عقداً؛ ولا تنقل الملكية في الحال بل بعد وفاة الموصي مصراً على وصيته، وقبل الوفاة يحق له الرجوع، ولا يصح أن يكون الأجل هو وفاة البائع، ونقل الحق في الوصية بدون مقابل، بخلاف البيع.

MAPA 01105405478

⚠ **الالتباس – قصداً للتحايل:** على القاعدة الآمرة بعدم جواز الوصية فيما زاد على **الثلث** — فيجعل الموصي تصرفه في صورة بيع لا وصية، فيكون بيعاً صورياً يوارى خلفه وصية حقيقية، ولكل ذي مصلحة التمسك بالتصرف الحقيقي وإثبات الصورية، وتستخلص الحقيقة من الظروف والملابسات والشروط.

ⓘ **قرائن يستأنس بها القضاء:** لاعتبار التصرف وصية لا بيعاً، ويؤيد ذلك القرائن الآتية:

1. **قلة الثمن المذكور:** أو إبراء المشتري من الثمن.
2. **فقر المشتري:** كالبيع لطفل لا يملك شيئاً يدفعه ثمناً.
3. **احتفاظ البائع بحق الانتفاع:** احتفاظ البائع لنفسه بحق الانتفاع بالشيء المبيع وحيازته إلى حين وفاته.
4. **منع المشتري من التصرف:** منع المشتري من التصرف في البيع طوال حياة البائع.

⚠ **تردد المحاكم:** في الأخذ بشرط دون آخر، أو الاكتفاء بشرط، حتى حسم المشرع في م 917 مدني.

📖 **نص المادة 917:** **"إذا تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً لما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك."**

ⓘ **القرينة:** قانونية — تدل على توافر نية الإيصاء، فيُعفى من يدعي أن التصرف وصية من عبء الإثبات، لكنها **بسيطة** يجوز إثبات عكسها؛ ولكل ذي مصلحة أن يثبت أنه بيع بإثبات وجود الثمن وقصد انتقال الملكية حال حياة المتصرف.

✨ **تفسير مسلك القانون الجديد (ترجيح جانب الوصية):** باعث القضاء على التساهل في تفسير التصرف بيعاً أو هبة قد انعدم، فالقضاء كان يرجح البيع أو الهبة على الوصية لما لمسه في القانون السابق من تضييق على الإيصاء للوارث — فكان يعالج عيباً في ذلك القانون ويصحح وصايا لها ما يبررها في ظروف الأسرة، كأن تتم تحت ستار بيوع أو هبات منجزة، أما وقد عدل المشرع وأجاز الوصية للوارث فيما لا يزيد على الثلث، فلم يعد هناك مقتض لتسمية التصرفات بغير أسمائها الحقيقية؛ وما دامت الوصية السافرة للوارث جائزة فلا محل للوصية المستترة.

القرينة القانونية – طبيعتها: هي الشيء الثابت في المسألة، وهي قابلة لإثبات العكس — فيجوز إثبات أن التصرف بيع أو هبة بقرائن في هذا المعنى.

القانون القديم: كان التكييف يتطلب أولاً تقصي ما اتجهت إليه إرادة الطرفين من آثار مع مراعاة الظروف والملابسات — وهذا من سلطة قاضي الموضوع مع التزامه بقواعد الإثبات، فإذا كان النزاع بين وارث المتصرف الذي يتمسك بأن التصرف وصية تلحق به ضرراً لتجاوزها حدود ثلث التركة، جاز له إثبات ذلك بكافة الطرق بما فيها البينة والقرائن — لأن ما يريد إثباته ينطوي على احتيال على القانون من جانب المتصرف.

اختلاف المحاكم في ظل القانون الملغى: بعضها اعتبره بيعاً وبعضها وصية، وهذا الفريق اختلف في الظروف والشروط والقيود والملابسات التي تستفاد منها نية الإيصاء: فاكتفت بعض المحاكم بثبوت حصول التصرف دون مقابل وببقاء العقد في حيازة المتصرف أو عدم تسجيله؛ واستنبط بعضها نية الإيصاء من اتفاق العاقدين على عودة الملكية إلى البائع إذا توفي المشتري قبله، أو من بقاء البائع محتفظاً بمزايا الملكية ومظهرها (الحيازة، التأجير، التقاضي).

أهم القرائن: التصرف دون مقابل + احتفاظ البائع لنفسه بحق الانتفاع إلى حين وفاته، أو اشتراط المنع من التصرف في المبيع حال حياته، واتفقت بعض المحاكم على أحد الشرطين، واشترط البعض اجتماعهما، ورأت أغلبية المحاكم أن اجتماعهما لا يكفي ولا يمنع من اعتبار العقد بيعاً ما لم توجد قرائن أخرى تعزز فكرة الإيصاء — فتدخل المشرع بالمادة 917.

شروط القرينة – م 917: لا تقوم القرينة القانونية إلا بتوافر شروط معينة وهي:

1. **التصرف صادر لأحد الورثة:** وتتوافر الصفة للمتصرف إليه **وقت وفاة المتصرف** لا وقت الانعقاد، فإذا كان وارثاً وقت التصرف ثم أصبح غير وارث وقت الوفاة — لا تقوم القرينة؛ والعكس بالعكس.
2. **احتفاظ المتصرف بأي طريق كان بحيازة العين:** الحيازة واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق — كالاستعمال والاستغلال ودفع الضرائب، ويكفي الحيازة المادية دون الركن المعنوي.
3. **احتفاظ المتصرف لنفسه بحق الانتفاع بالعين طوال حياته:** —

الأثر: يستطيع المتصرف إليه إثبات أن العقد بيع بكافة طرق الإثبات.

أركان عقد البيع:

الفصول الآتية

الرضا	المبيع	الثمن	بيع ملك الغير

تمهيد: ينقسم ما يشترط في البيع إلى أركان وشروط صحة، ويختلف الحكم باختلاف تخلف كل منهما، ويتضح ذلك في العنصرين الآتيين:

1. **الأركان:** الرضا، المحل، السبب — شروط انعقاد، وتخلفها يؤدي إلى **البطلان المطلق**.
2. **شروط الصحة:** الأهلية وسلامة الرضا — وتخلفها يؤدي إلى أن العقد **قابل للإبطال** لمصلحة من شابه العيب.

المحل مزدوج: المحل في البيع مزدوج: **مبيع** و**ثمن**.

خطة البحث: نقتصر في هذا الباب على: الرضا (فصل أول)، المبيع (فصل ثانٍ)، الثمن (فصل ثالث) — والسبب يُحال للنظرية العامة.

الركن الأول: الرضا في عقد البيع:

تعريف العقد (م 89 مدني): **العقد يتم بتبادل إرادتين متطابقتين (إيجاب + قبول مطابق)**.

السكوت قبولاً؟: الأصل أن السكوت ليس قبولاً، ويستثنى من ذلك حالات تدل فيها القرينة عليه، وتفصيل ذلك كالتالي:

1. **الأصل:** لا يعتبر السكوت قبولاً — **لا ينسب لساكت قول** (م 81).
2. **الاستثناء:** قرينة تدل عليه — م 98: **"ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين، واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه"**

MARA 01105405478

3. **الفقه الإسلامي:** سكوت البكر قبول — «"...البكر تستأذن، وإذنها سكوتها"» .

4. **التعاطي:** من العقود ما ينعقد بالتعاطي دون كلام.

أولاً: مضمون الرضا

❶ المطلب الأول: التراضي على العناصر:

◆ **العناصر الجوهرية:** لا ينعقد البيع إلا بالتراضي على العناصر الجوهرية الثلاثة، ويتضح ذلك في العناصر الآتية:

1. **طبيعة العقد:** فإذا قصد أحدهما بيعاً والآخر رهناً أو نكاحاً — **لم ينعقد** .
2. **المبيع:** وإذا قصد البائع منزلاً وقصد المشتري آخر — **لم ينعقد** .
3. **الثمن:** وإذا عرض بائع السيارة بعشرة آلاف وقبل المشتري بخمسة — **لم ينعقد** .

⚠ **مسألة العرض بأعلى:** إذا عرض البائع المبيع بعشرة آلاف وقبل المشتري بخمسة — اختلف الفقه في تكييف ذلك، ويتضح في الرأيين الآتيين:

1. **الرأي الأول:** ينعقد بالأقل — لورود الاتفاق عليه ضمناً (المشتري راضٍ بالأقل من باب أولى).
2. **الرأي الثاني (تفصيل):** ينقسم إلى فرعين، ويتضح ذلك في الفرعين الآتيين:

[1] **إن ظنّ المشتري أنه الثمن الذي عرضه البائع:** ← عقد بالأقل.

[2] **إن علم بالثمن وزاد لاقتناعه بقيمة المبيع فعلاً:** ← الزيادة إيجاب جديد، وسكوت البائع قبول (م 96، 2/9: "ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه").

◆ **العناصر التفصيلية:** لا يتوقف عليها الانعقاد — كـ**مكان تسليم المبيع وميعاد دفع الثمن**، وقد نصت المادة 95 على قاعدتها.

📖 **نص المادة 95:** **"إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم، وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق**

عليها فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة، وأحكام القانون والعرف والعدالة."

✅ **أثرها:** تعتبر هذه المسائل **مكملة** للعقد، أما إذا اتجهت نية الطرفين إلى جعل مسألة تفصيلية جوهرية (كمناقشة تأجيل الثمن أو تقسيطه أو من يتحمل مصاريف التسلم) — **فلا ينعقد إلا بالاتفاق عليها** ، وتقدير ذلك لقاضي الموضوع وفقاً لطبيعة المعاملة والقانون والعرف والعدالة.

ℹ️ **الإيجاب:** الأصل عدم إلزامه قبل القبول، لكن وفاة الموجب أو فقد أهليته بعد صدور القبول **لا يمنع تمام البيع** عند اتصال القبول بعلمه — ما لم يتبين العكس من التعبير أو طبيعة التعامل.

👥 **الإيجاب للجمهور:** إذا وجه الإيجاب للجمهور (كالنشرات والإعلانات) — اختلف الفقه في تكييفه، ويتضح ذلك في الآراء الآتية:

1. **الرأي الأول:** إيجاب صحيح — يلتزم الموجب بالتعاقد مع كل من يتقدم بالقبول أولاً فأول في حدود ما عنده، ولا يتقيد بعد نفاد السلع.
2. **الرأي الثاني:** ليس إيجاباً بل دعوة إلى التفاوض — ما لم تدل دقة البيانات على العكس.
3. **الرأي الثالث (السنهوري – الراجح عندنا):** يفرق بين فرعين، ويتضح ذلك في الفرعين الآتيين:

[1] **عرض في النشرات/الإعلانات/الكتالوجات العامة:** ← دعوة للتعاقد.

[2] **إرسال بعنوان شخصي لقصد توجيه إيجاب:** ← إيجاب كامل، والقبول يتم به البيع.

✅ **عرض السلع في واجهات المحلات:** عرض السلع بأثمانها في واجهات المحلات = **إيجاب صريح** — لا اعتداد بشخصية المتعاقد في عقود المعاوضات.

٢ المطلب الثاني: الأهلية:

🔷 **أهلية الأداء – مناطها التمييز:** تختلف أهلية الأداء باختلاف درجة التمييز، ويتضح ذلك في الحالات الآتية:

MARA 01105405478

1. **عديم التمييز:** (صبي غير مميز < 7 — م 45، مجنون، معتوه — بعد تسجيل الحجر، أو قبله مع شيوع الحالة أو علم الطرف الآخر) ← **البيع باطل** .

2. **الصبي المميز:** (7 — 21) في غير الحدود الجائزة ← **قابل للإبطال** لمصلحته — يصح بإجازة الولي/الوصي/القيم أو إذن المحكمة.

3. **السفيه وذو الغفلة (م 46):** بعد الحجر — أو قبله إذا كان التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ ← **كالصبي المميز**، وإذا أُذن لهما بإدارة أموالهما بعد الحجر ← **كالمأذون في الإدارة**.

البيع من أعمال التصرف: يقتضي **أهلية التصرف** (21 سنة)، ويستثنى من ذلك حالات معينة، ويتضح ذلك في الاستثناءات الآتية:

1. **م 61 ولاية 119/1952:** للقاصر أهلية التصرف فيما يُسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادةً من مال لأغراض نفقته، ويصح التزامه في حدود هذا المال فقط — فبيعه المتعلق بأغراض نفقته صحيح في هذه الحدود، وإلا قابل للإبطال.

2. **م 16: 63** سنة — التصرف فيما يكسبه من عمله (أجر أو غيره) — في حدود الكسب.

3. **م 18: 57** سنة — التصرف في نطاق التجارة المأذون فيها من المحكمة.

4. **م 60:** المأذون بالزواج — في المهر والنفقة، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.

5. **م 18: 112** سنة مع تسلم الأموال للإدارة — أعمال الإدارة صحيحة (كالبيع والشراء في نطاقها — شراء سماد وآلات، بيع ثمار وحاصلات الأرض).

٣ المطلب الثالث: سلامة الإرادة:

تمهيد: البيع يخضع للقواعد العامة في الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال، وقد أورد المشرع حكمين خاصين، ويتضح ذلك في الحكمين الآتيين:

1. **م 419:** العلم الكافي بالمبيع.

2. **م 425-427:** الغبن في عقار ناقص الأهلية.

١ الفرع الأول: العلم بالمبيع علماً كافياً: يقتضي البيع علم المشتري بالمبيع علماً كافياً، وقد نصت المادة 419 على ذلك في فقرتين، ويتضح في الآتي:

1. **الفقرة الأولى – اشتراط العلم الكافي:** **"يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً، ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه،"**

2. **الفقرة الثانية – سقوط الحق بالإقرار:** **"وإذا ذكر عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إذا ثبت تدليس البائع،"**

> **المذكرة الإيضاحية:** يوفق النص بين **خيار الرؤية** في الشريعة و**المبادئ العامة** — التي لا تشترط الرؤية بل التعيين الكافي.

> **خيار الرؤية – الفقه الإسلامي:** خيار الرؤية حق للمشتري عند شراء ما لم يره — إمضاء أو فسخ بعد رؤية المبيع، ويتضح ذلك في عناصره الآتية:

1. **التعريف:** حق للمشتري عند شراء ما لم يره — إمضاء أو فسخ بعد رؤية المبيع.

2. **الدليل:** «"من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه"» (أبو هريرة).

3. **الوقت والسبب:** عند الرؤية لا قبلها، فلو أجاز قبل الرؤية **لم يلزم ولم يسقط**، وإسقاطه قبل ثبوته **لا يصح** — فالإسقاط فرع عن الثبوت.

4. **الشرطان:** يتضح ذلك في الشرطين الآتيين:

1. **مما يتعين بالتعيين:** يمكن رؤيته وتفحصه — لا في الدين كالسلم.

2. **عدم رؤيته سابقاً:** —

5. **ما تتحقق به:** حصول العلم بأي طريق — رؤية، شم، ذوق، لمس.

6. **المسقطات:** يتضح ذلك في المسقطات الآتية:

1. **الإسقاط الصريح أو التصرف بعد الرؤية:** بيع/هبة/وصية/تصرف مادي كشوي اللحم وعجن الدقيق.

2. **الموت:** —

3. **هلاك المعقود عليه:** —

MARA 01054054478

العلم الكافي في القانون – التمييز عن التعيين: يختلف العلم الكافي عن تعيين المبيع في أمرين، ويتضح ذلك في الوجهين الآتيين:

الوجه	المضمون
المقصود	تعيين المبيع: تمييز المبيع عن غيره، / العلم الكافي: معرفة أوصافه الأساسية بما يمكن من التعرف.
الأثر	تعيين المبيع: عدمه ← بطلان مطلق، / العلم الكافي: عدمه ← قابل للإبطال.

مثال: بيع منزل معين بموقعه — تعيين كافٍ، لكن قد يجهل المشتري عدد طوابقه ووحداته ومساحته ← عدم علم كافٍ.

ما يتحقق به العلم: يتحقق العلم الكافي بثلاث طرق، ويتبين ذلك في الطرق الآتية:

1. **المعاينة:** مشاهدة/لمس/ذوق/شم — بنفسه أو نائبه، وقت الإبرام أو قبله؛ أما بعد البيع فلا تحول دون الإبطال، وتكفي ولو لم تحقق معرفة الأوصاف فعلاً — ما دامت وافية بتمكين العلم للرجل المعتاد.
2. **الوصف في العقد:** بيان الأوصاف الأساسية — م 1/419، والوصف الكافي مسألة موضوعية لقاضي الموضوع، وقد تقتضيه الضرورة (كالأعمى، أو المبصر لشيء ليس في المجلس).
3. **الإقرار بالعلم:** م 2/419 — سقوط الحق في الإبطال، سواء طابق الواقع أو خالفه (تنازل ضمني أو عدم اعتداد بالعلم)، بخلاف خيار الرؤية الذي لا يجيز النزول قبل الرؤية، **الاستثناء:** إذا كان الإقرار نتيجة تدليس ← لا يسقط، مثال: إيهامه بأن المبيع شيء آخر غير المذكور.

الجزاء: الإبطال — العقد صحيح منتج آثاره حتى الحكم، فيزول بأثر رجعي، وأساسه: **الغلط** — بخصوصية: (1) يتعلق بوفاء العين المبيعة بالغرض المقصود، (2) يفترضه القانون ويعفي المشتري من إثباته.

سقوط الحق: يسقط الحق في الإبطال بأسباب متعددة، ويتضح ذلك في الأسباب الآتية:

1. **الإجازة:** صريحة ("رضيت"/"أجزت") أو ضمنية (التصرف في العين بالبيع/البناء) — بشرط صدورها **بعد** العلم.

2. **التقادم – م 3: 140** سنوات من وقت العلم بالشيء أو 15 سنة من وقت انعقاد البيع — أيهما أقصر.

3. **تعيب/هلاك/زيادة في المبيع:** استحالة رد المبيع بالحالة التي كان عليها — رأي جانب كبير من الفقه المصري ومتوافق مع خيار الرؤية.

4. **تصرف المشتري قبل العلم:** تصرف يوجب حقاً للغير، **القاعدة:** الإجازة لا تنتج أثرها إلا بعد زوال العيب — لكن لما جعل المشرع ذكر "عالم بالمبيع" مسقطاً للحق ولو لم يعلم فعلاً، فبالقياس من باب أولى يعتبر تصرفه قبل العلم مانعاً من الإبطال.

5. **موت المشتري:** الحنفية: لا يورث الخيار — فيسقط، الجمهور: كل حق متعلق بالمال يورث — فينتقل، **محكمة النقض أخذت بالجمهور** — ينتقل لورثة المشتري.

2 الفرع الثاني: الغبن في بيع عقار مالك ناقص الأهلية: الغبن عدم التعادل بين ما يعطيه المتعاقد وما يحصل عليه — أحد البدلين غير متكافئ مع الآخر في القيمة عند التعاقد، ويتضح ذلك في العناصر الآتية:

الغبن – الفقه الإسلامي: نقص فادح في أحد العوضين — يعطي حق الفسخ (حديث حبان بن منقذ: «"إذا بعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام فإن رضيت وإن سخطت فارددها على صاحبها"»).

القاعدة العامة – م 129: يشترط عنصران، ويتضح ذلك في العنصرين الآتيين:

1. **مادي:** عدم تعادل بين الالتزامات نتيجة استغلال.
2. **معنوي:** طيش بين أو هوى جامح استغله أحدهما وكان دافعاً للتعاقد.

النتيجة: **الغبن وحده لا يصلح للطعن** — بل لابد من اقترانه بالاستغلال.

نص المادة 425: **"إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس للبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل، ويجب**

لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع."

📖 **نص المادة 426:** "أن تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن، إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع، ولا تلحق هذه الدعوى ضرراً بالغير حسن النية إذا كسب حقاً على العقار المبيع."

📖 **نص المادة 427:** "لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم وفق القانون بطريق المزاد العلني."

شروط الطعن: لا يتحقق الطعن بالغبن إلا بتوافر شروط معينة، ويتضح ذلك في الشروط الآتية:

1. **المبيع عقار:** أو حق عيني وارد على عقار (انتفاع، رقبة، حكر)، لا في المنقول مهما بلغت قيمته — إلا بشروط الاستغلال، والتفرقة منتقدة (ارتفاع قيمة بعض المنقولات — كالأجهزة الدقيقة والطبية والحربية — قد يفوق العقارات)، والشريعة لا تفرق بين العقار والمنقول (كلٌّ عين تقابل الدين) — والفقه الإسلامي قائم منذ ألف سنة، استوعب ما أدركه الفقه الفرنسي بعد جهد.

2. **العقار لناقص الأهلية:** صبي مميز، محجور لسفه أو غفلة، وفي حكمه من باب أولى عديم الأهلية، فإن كان البائع كامل الأهلية — لا طعن بالغبن إلا بالاستغلال، وإذا كان ناقص الأهلية هو من باع بنفسه ← له الطعن بالغبن أو الإبطال لنقص أهليته (يختار)، أما عديم الأهلية ← البيع باطل مطلق، وإذا باشر النائب (ولي/وصي/قيم) فلا إبطال لنقص الأهلية — لكن **م 7 ولاية 119/1952** ضيقت سلطتهم: يلزم إذن المحكمة، ولها رفضه إذا كان في البيع غبن فاحش يزيد على خمس قيمة العقار، **ملاحظة:** الغائب، والمحجور عليه لعقوبة جنائية، ومن أُقيم له مساعد قضائي — ليسوا ناقصي الأهلية، فيسري عليهم حكم كاملي الأهلية.

3. **الغبن > الخمس:** من ثمن المثل — بحسب قيمة العقار **وقت البيع** لا وقت الدعوى أو الحكم.

4. **على البائع لا المشتري:** فلا طعن للمشتري إذا زاد الثمن على المثل — لكن له الطعن بالاستغلال، ولا في العقود الاحتمالية (الأصل ترك التقدير للقاضي — الأولى).

5 **ليس بالمزاد العلني:** كبيع أموال المدين جبرياً، وبيع عقار القاصر (المواد 459-462 مرافعات)، والحكمة: القانون رسم إجراءات تكفل أعلى ثمن ← لا محل للطعن بعدها، وإلا لأحجم الناس عن المزاد، أما إذا كان المزاد اختيارياً — فالضمانات غير متحققة ← يجوز الطعن.

الأثر – دعوى تكملة الثمن: للبيع الطعن مطلقاً بتكملة الثمن إلى **4/5 ثمن المثل** ، ترفع من البائع بعد اكتمال أهليته، أو من ورثته، أو من الولي/الوصي/القيم إذا كان ناقص الأهلية هو من باع.

التقادم: 3 سنوات من وقت اكتمال الأهلية أو الوفاة — **مدة تقادم لا سقوط** ← يسري عليها الانقطاع، لكن **لا يرد عليها الوقف** — لأن التقادم ≥ 5 سنوات لا يرد عليه الوقف بسبب عدم الأهلية ولو لم يكن للدائن نائب (م 2/382)، ويجوز التنازل بعد اكتمال الأهلية — لا قبلها، ولا للولي، ولا للمحكمة.

الحكم: القاضي يحكم بتكملة الثمن إلى **4/5 قيمة المبيع لا إلى الثمن كاملاً** ، وفرق الثمن مصون بامتياز البائع بشرط القيد — ومرتبة الامتياز من تاريخ القيد التكميلي، وله طلب الفسخ إن امتنع المشتري طبقاً للقواعد العامة.

حماية الغير حسن النية – م 2/426: **"لا تلحق هذه الدعوى ضرراً بالغير حسن النية إذا كسب حقاً عينياً على العقار المبيع،"** تطبيقاً للقاعدة العامة في م 17 من قانون الشهر العقاري.

أثر الحماية: إذا رتب المشتري حقاً عينياً (رهن، انتفاع، ارتفاق) — **لا يضر الفسخ بصاحب الحق العيني** بشرط حسن نيته وقت الاكتساب — فيعود العقار للبائع محملاً بالحق، وإذا تصرف المشتري بالهبة أو البيع لشخص حسن النية سجّل عقده — **تستقر الملكية له** حتى لو حُكم بالفسخ، والمشتري سيئ النية من تاريخ **شهر دعوى الفسخ** — فيجب على الغير أن يشهر حقه قبل شهر الدعوى.

MARA 01105406478

المطلب الأول: الوعد بالبيع أو الشراء:

نص المادة 101: "الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها، وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد."

نص المادة 102: "إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد."

الصور: يأخذ الوعد بالبيع أو الشراء ثلاث صور، ويتضح ذلك في الصور الآتية:

1. **وعد بالبيع من جانب واحد:** عقد يتضمن وعداً بالبيع لشخص بثمن وشروط، إذا أبدى الموعود رغبته في الشراء في مدة معينة، يلزم الواعد وحده، ليس إيجاباً — فمصدر الالتزام في الإيجاب إرادة منفردة، وفي الوعد عقد الوعد، مثال: من يريد إقامة مصنع — يستأجر الأرض ويحصل على وعد بالبيع، شروطه: تلاقي إيجاب وقبول على ماهية الوعد، تعيين الجوهرية (المبيع والثمن)، المدة صراحة أو ضمناً، أهلية التصرف وقت الوعد.
2. **وعد بالشراء من جانب واحد:** يلزم الواعد بالشراء وحده، إذا أبدى صاحب الشيء رغبته — انعقد البيع منذ تلك اللحظة، يجب تحديد المبيع والثمن والمدة.
3. **وعد متبادل:** كل منهما واعد وموعود له — ملزم للطرفين، قصدا إرجاء الانعقاد لا إبرامه فوراً (وإلا كان بيعاً لا وعداً).

الوعد بالتفضيل: يلتزم الواعد بعرض الشيء على الموعود إن أراد بيعه — لا بالبيع، يجب تعيين الشيء والمدة، والثمن: يجوز أن يحدد على ضوء ما يعرضه الغير.

البيع الابتدائي: عقد بات — يلتزم الطرفان بالبيع والشراء، ولا يبقى إلا تحرير العقد النهائي، ونقل الملكية بالتسجيل.

الوعد: لا يلزم إلا عند إبداء الرغبة.

٢ المطلب الثاني: البيوع الموصوفة:

١ الفرع الأول: البيع بشرط التجربة: نصت المادة 421 على تنظيم البيع بشرط التجربة في فقرتين، ويتضح ذلك في الآتي:

١ **الفقرة الأولى – حق التجربة والرفض:** **"في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه، وعلى البائع أن يمكنه من التجربة، فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة، ففي مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة، وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً."**

٢ **الفقرة الثانية – التكييف:** **"ويعتبر البيع بشرط التجربة بيعاً معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع، إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ."**

الاستفادة الضمنية: من عادات التعامل أو طبيعة الشيء (ملابس جاهزة، سيارات مستعملة، راديوهات وتلفزيونات).

الطبيعة: معلق على **شرط واقف** (قبول المشتري) — تترتب الآثار من وقت التعاقد عند تحققه، إلا إذا تبين أنه معلق على **شرط فاسخ** — فتترتب فوراً، ويزول بزواله بأثر رجعي.

الحكم: على البائع تمكين المشتري من التجربة (التزام إضافي)، والمشتري يلتزم بها في المدة؛ فإن لم يقم مع تمكنه — امتنع تحقق الشرط من جانبه ← يعتبر محققاً بمضي المدة، والبيع نهائي، وانقضاء الميعاد دون تحفظ **قبول**.

حرية القبول/الرفض: تختلف حرية القبول أو الرفض بحسب المقصود من المبيع، ويتضح ذلك في الحالات الآتية:

١ **المبيع لحاجة شخصية (ملابس جاهزة):** حرية مطلقة — لا يجب بيان الأسباب، ولا للبائع إثبات الملاءمة.

MARA 01054054778

2 **المقصود استبيان صلاحية المبيع لغرضه (آلة ميكانيكية):** لا يجوز الرفض إلا ببيان وجه عدم الصلاحية — وإلا خضع لرقابة القضاء (بأهل الخبرة).

3 **الشك في المقصود:** يغلب جانب الحاجة الشخصية ← حرية مطلقة.

2 **الفرع الثاني: بيع المذاق:** نصت المادة 422 على بيع المذاق، ويتضح ذلك في الآتي:

نص المادة 422: **"إذا بيع الشيء بشرط المذاق، كان للمشتري أن يقبل المبيع إن شاء، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف، ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان."**

التكييف: وعد بالبيع — **لا ينعقد إلا وقت الإعلان، ولا أثر رجعي** .

الفروق عن التجربة: يختلف بيع المذاق عن البيع بشرط التجربة في خمسة أوجه، ويتبين ذلك في الأوجه الآتية:

1 **الأثر الرجعي عند القبول:** التجربة: نعم (شرط واقف) — إلا إذا كان فاسخاً، / المذاق: لا — ينعقد من وقت الإعلان.

2 **السكوت في المدة:** التجربة: قبول، / المذاق: رفض — يتحلل الواعد.

3 **هلاك المبيع قبل التجربة/المذاق:** التجربة: على البائع، / المذاق: على البائع.

4 **إفلاس البائع قبل القبول:** التجربة: يستأثر المشتري بالمبيع دون الدائنين (مالك منذ الإبرام)، / المذاق: لا استئثار — يشاركهم.

5 **حجز دائن البائع قبل القبول:** التجربة: لا يسري، / المذاق: يسري في مواجهة المشتري.

ما يترتب على الوعد: التزام الواعد بتمكين الموعود من المذاق (زماناً ومكاناً وكيفية حسب الاتفاق أو العرف)، فإن أخل — حكم بغرامة تهديدية والتعويض إن كان له محل، والقبول للموعود وحده (لذوقه الشخصي)، ويعلن في المدة؛ فإن رفض أو تركها تنقضي دون إعلان — اعتبر سكوته رفضاً.

3 **الفرع الثالث: البيع بالعينة أو النموذج:** نصت المادة 420 على البيع بالعينة في فقرتين،

ويتضح ذلك في الآتي:

1. **الفقرة الأولى – وجوب المطابقة:** **"إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون مطابقاً لها،"**
2. **الفقرة الثانية – تلف العينة:** **"وإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ، كان على المتعاقد بائعاً أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق،"**

الوظيفة: طريق لتعيين المبيع يغني عن الوصف والرؤية.

التكييف: اختلف الفقه في تكييف البيع بالعينة، ويتضح ذلك في الرأيين الآتيين:

1. **الرأي الأول (الراجح عندنا):** بيع بات — يوافق قصد المتعاقدين وطبيعة العقد.
2. **الرأي الثاني:** معلق على شرط فاسخ — المشتري يلتزم من البداية، وينفسخ عند عدم المطابقة.

الأحكام: تتنوع أحكام البيع بالعينة بحسب المسألة، ويتضح ذلك في المسائل الآتية:

1. **المطابقة:** يجب أن تكون تامة — فإن لم يجدها موافقة ← للمشتري رفض التسلم ولو أثبت البائع أن المبيع أفضل نوعاً أو أكثر قيمة (الوفاء بما التزم به أصالة لا بغيره ولو أفضل)، وإن كانت مطابقة ← لا رفض ولو لم تلائم حاجته.
2. **الفرق التافه:** لا يؤثر على صلاحية المبيع — للمشتري قبوله بإنقاص الثمن بنقص الجودة.
3. **عبء الإثبات (عينة موجودة):** من في يده العينة مدعى عليه، والآخر مدعٍ — يثبت عدم المطابقة، إلا إذا كانت على العينة علامات متفق عليها فتكفي لذاتيتها.
4. **العينة هالكة:** م 2/420 — يثبت البائع أو المشتري المطابقة أو عدمها بكافة الطرق (بينة وقرائن)، والخبير استشاري.

أثر عدم المطابقة: يترتب على عدم المطابقة عدة آثار، ويتضح ذلك في الآثار الآتية:

1. **تنفيذ عيني:** تسليم مطابق.

2. **شراؤه من السوق على نفقة البائع:** بعد إذن القضاء أو قبله في الاستعجال (م 205).
3. **فسخ:** رقابة قاضٍ الموضوع (م 2/157).
4. **تعويض:** —
5. **إنقاص الثمن:** إذا قلت قيمة المبيع عن العينة.

4. **الفرع الرابع: البيع بالعربون:** نصت المادة 103 على البيع بالعربون في فقرتين، ويتضح ذلك في الآتي:

1. **الفقرة الأولى – حق العدول:** **"دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في دفع العدول عنه إلا إذا قضي الاتفاق بغير ذلك،"**
2. **الفقرة الثانية – جزاء العدول:** **"فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه رد ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر،"**

معناه: مبلغ يدفعه أحد المتعاقدين وقت العقد — تأكيداً للإبرام (تعجيل جزء من الثمن) أو دليلاً للعدول، فإذا عدل المشتري — فقده؛ وإذا عدل البائع — رد المبلغ ومثله، **وليس تعويضاً عن الضرر بل مقابل للعدول.**

التكييف: اختلف الفقه في تكييف البيع بالعربون، ويتضح ذلك في الرأيين الآتيين:

1. **الرأي الأول:** معلق على شرط واقف (عدم العدول خلال مدة) — تتوقف الآثار، وتترتب بأثر رجعي عند انتهاء المدة دون عدول.
2. **الرأي الثاني:** معلق على شرط فاسخ (العدول) — ينتج آثاره من وقت الانعقاد، لكنه مهدد بالزوال، فإذا تحقق زال بأثر رجعي.

النقد: كلا التكييفين يتعارض مع إلزام من عدل برد ضعف العربون — فالأثر الرجعي يقتضي زوال العقد كأن لم يكن، **فلا موجب للضعف** .

الركن الثاني: المبيع (المعقود عليه):

تعريف المبيع: المبيع: **الحق المالي الذي يرد عليه البيع** — أياً كانت طبيعته (حق عيني كالملكية — الغالب، أو شخصي، أو ذهني)، ومحل التزام البائع هو الحق المالي المراد نقله،

والشيء محل الحق هو المبيع.

شروط المبيع: يشترط في المبيع أربعة شروط، ويتضح ذلك في الشروط الآتية:

1. **الوجود أو قابلية الوجود:** —
2. **التعيين أو قابلية التعيين:** —
3. **قابلية التعامل:** —
4. **ملكية البائع:** —

المبحث الأول: الوجود أو قابلية الوجود:

نص المادة 132: **"إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً،"** والاستحالة **مطلقة** لا نسبية.

حكم الحالات: يختلف الحكم باختلاف نوع المبيع، ويتضح ذلك في الحالات الآتية:

1. **الأعيان المعينة بالذات:** يجب الوجود عند العقد — وإلا بطل، وإذا هلكت قبل البيع ← بطل.
2. **المثليات:** يكفي وجود المثل عند التنفيذ لا الانعقاد — إذ تقوم مقام بعضها في الوفاء.
3. **المستقبل:** م 1/131: **"يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً"** — كبيع الشقق قبل تشطيبها، والمحاصيل قبل الحصاد، وحمل الماشية قبل الولادة.

الفقه الإسلامي: لا يقر بيع المعدوم — «"لا تبع ما ليس عندك"» — وللنهي عن بيع الغرر، ويُستثنى ما ورد النص باستحسانه (السلم، الإجارة، الاستصناع، الجعالة).

مدى المجازفة: يختلف الحكم باختلاف مدى المجازفة في المبيع، ويتضح ذلك في الصور الآتية:

1. **بيع الصياد ضربة الشبكة:** بيع صحيح بات — يدفع المشتري الثمن مهما كانت النتيجة، وجد المبيع أو لم يوجد، وبأي قدر — عقد غرر يجيزه القانون وتحترمه الشريعة (لأن محله على خطر الوجود والعدم).

2. **عدم المجازفة لا في الوجود ولا في الكمية:** (شراء محصول أرض بسعر الإردب عشرة جنيهات) ← بيع معلق على شرط واقف (وجود المبيع).

3. **مجازفة في الكمية فقط:** (بيع محصول الأرض بإجمالي محدد) ← بيع معلق على شرط واقف (وجود المبيع).

📖 **بيع التركة المستقبلية – م 2/131:** **"التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه، إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون،"** يشمل البيع وغيره — على التركة كلها أو جزء أو مال معين بصفته داخلاً فيها، والبطلان **مطلق** — لكل ذي مصلحة، حتى المشتري، وللمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.

٢ المبحث الثاني: التعيين أو قابلية التعيين:

📖 **نص المادة 133:** **"إذا لم يكن محل الالتزام معيناً بذاته، وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً، ويكفي أن يكون المحل معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره، وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر، التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط،"**

◆ **طريقة التعيين:** تختلف طريقة التعيين باختلاف نوع المبيع، ويتضح ذلك في الأنواع الآتية:

1. **معين بالذات (منقول):** ذكر صفاته وخصائصه المميزة.

2. **عقار:** المساحة والحدود والموقع.

3. **منزل:** بالإضافة — عدد الطوابق والموقع.

4. **معين بالنوع (المثليات):** النوع والمقدار (عدد/وزن/كيل/مقاس)، فإن لم يعين المقدار — الأسس التي يتحدد بها مستقبلاً، والجودة: العرف أو الصنف المتوسط (م 2/133).

ℹ **العينة:** العينة طريق للتعيين (سبق).

ALARA 01105405478

٣ المبحث الثالث: قابلية التعامل:

نص المادة 81: "كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية، والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها، هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية،"

نص المادة 135: "إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام والآداب، كان العقد باطلاً،"

فلا يجوز: استناداً لما سبق، لا يجوز بيع:

1. **المال العام:** —
2. **المخدرات:** إلا لأغراض طبية أو بحث علمي.
3. **صوت النائب لمرشح:** —
4. **وظيفة الموظف:** —
5. **التنازل عن الجنسية أو الاسم أو البنوة أو الأبوة:** —
6. **منزل بقصد إدارته للدعارة أو القمار:** —

٤ المبحث الرابع: ملكية البائع – بيع ملك الغير:

الأصل: البيع من غير المالك **باطل مطلقاً** — لتخلف المحل والسبب (سبب التزام المشتري بالثمن هو نقل الملكية، فإذا لم يتحقق فلا سبب).

الاستثناء التشريعي: بيع ملك الغير — **بطلان نسبي** (م 466-468)، والتبرير: الاستحالة **نسبية** (قد يتملك البائع بعد العقد فينقل)، والجزاء المناسب: البطلان النسبي — يزول بإجازة المشتري أو إقرار المالك أو تملك البائع.

نص المادة 466: "إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع، ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار سجل العقد أو لم يسجل،

MNARA 01105405478

وفي كل الأحوال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز للمشتري العقد."

نص المادة 467: "إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري، وكذلك ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد."

نص المادة 468: "إذا حكم للمشتري بإبطال البيع، وكان يجهل أن المبيع مملوك للبائع، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية."

شروط بيع ملك الغير: يشترط لانطباق بيع ملك الغير ثلاثة شروط، ويتضح ذلك في الشروط الآتية:

1. **معين بالذات:** لا في المعين بالنوع — لأن الحق فيه يتعين بالمثل، فلا يوصف بأنه مملوك أو غير مملوك.
2. **غير مملوك للبائع ولا للمشتري:** إن كان مملوكاً للمشتري ← بطلان مطلق (استحالة نقل ملكية إلى من هو مالك له فعلاً).
3. **أن يكون بيعاً:** التعهد عن الغير (الحصول على رضا المالك بالبيع) ليس بيعاً — محله عمل لا نقل ملكية.

حكمه فيما بين المتعاقدين:

حق الإبطال للمشتري وحده: م 466 — لأنه تقرر لمصلحته، يرفعه بدعوى أصلية أو بالدفع، وله رفع الدعوى **قبل** تعرض المالك — لأن البائع قد لا يستطيع الحصول على الملكية، ويثبت له **وإن كان سيئ النية** — لأن م 468 يجعل التعويض لحسن النية، فيفهم منه ثبوت الإبطال لسيئ النية من باب أولى، ويثبت **وإن كان البائع حسن النية**، ولا حق للبائع في طلب الإبطال.

حق التعويض – للمشتري حسن النية فقط: جهل وقت البيع أن المبيع غير مملوك للبائع — م 468، ولو كان البائع حسن النية، فإن كان سيئ النية ← فقط الإبطال واسترداد الثمن.

أساس التعويض: اختلف الفقه في أساس التعويض، ويتضح ذلك في الرأيين الآتيين:

MARA 01105405478

1. **الرأي الأول:** تطبيق تشريعي لقاعدة الخطأ عند تكوين العقد.
2. **الرأي الثاني (الراجح عندنا):** المسؤولية التقصيرية — البيع من غير المالك خطأ، لا سيما مع سوء النية (اغتصاب).

سقوط الحق: يسقط حق المشتري بأسباب متعددة، ويتضح ذلك في الأسباب الآتية:

1. **إقرار المالك – م 1/467:** يسري في حقه وينقلب صحيحاً في حق المشتري، والرأي السائد: الإقرار المسقط للحق هو الصادر **قبل** رفع الدعوى — فبعدها لا يحول دون الحكم (المحكمة تنظر الدعوى بالحالة التي كانت عليها وقت رفعها).
2. **تملك البائع للمبيع بعد العقد:** أياً كان السبب — يزول المانع، بشرط أن يكون **قبل** رفع الدعوى (الرأي السائد).
3. **إجازة المشتري:** صراحة أو ضمناً — بعد علمه، تسقط الحق وتحول العقد إلى صحيح.
4. **التقادم:** 3 سنوات من العلم بعدم ملكية البائع، أو 15 سنة من وقت العقد (الرأي الغالب — لا نص خاص).

ملاحظة: سقوط حق المشتري (بالإجازة أو التقادم) لا أثر له على حقوق المالك — لأن البيع غير سارٍ في حقه على أي حال.

حكمه بالنسبة للمالك الحقيقي:

لا يسري في حقه إلا بإقراره: المالك أجنبي عن البيع — فلا يسري في حقه، سواء حُكم بالإبطال أم لا، وسواء سقط حق المشتري أم لا، فإذا سلم البائع المبيع للمشتري — للمالك دعوى الاستحقاق على المشتري، ويرجع المشتري على البائع بضمان الاستحقاق أو بالفسخ أو بالإبطال.

أثر إقرار المالك – م 1/467: يسري في حقه وينقلب صحيحاً في حق المشتري، **الأثر:** نقل الملكية من تاريخ الإقرار (أو تسجيله إن كان عقاراً)، فالحقوق التي قررها المالك للغير قبل الإقرار (رهن، ارتفاق) — إذا شُهرت قبل تسجيل الإقرار — تنتقل الملكية للمشتري محملة بها.

آثار الإقرار: المالك يحل محل البائع من وقت الإقرار في جميع الحقوق والالتزامات (الرأي الغالب) — فتكون العلاقة بينه وبين المشتري مباشرة، وتبرأ ذمة البائع، فللمالك مطالبة

المشتري بالثمن، ومطالبة البائع بما قبضه، وللمشتري مطالبة المالك المقر بالتسليم والرجوع عليه بضمان التعرض والاستحقاق وضمان العيوب الخفية.

تأصيل أحكام البطلان:

الآراء: اختلف الفقه في تكييف بيع ملك الغير، ويتضح ذلك في الآراء الآتية:

1. **الرأي الأول – ليس باطلاً بل صحيح قابل للفسخ:** البائع لم ينفذ التزامه بنقل الملكية ← للمشتري طلب الفسخ، وبعض الفقهاء بالغ: البيع صحيح طبقاً للقواعد العامة — حتى وصف بعض كبار الفقهاء نص البطلان في القانون الفرنسي بأنه "لغو تشريعي"، وآخرون بأنه "من أشد النصوص غموضاً".

   النقد: يخالف حكم القانون الذي نص على البطلان النسبي — ولو أخذنا بالفسخ لكان نص بيع ملك الغير تزيداً.

2. **الرأي الثاني – باطل مطلق:** لتخلف المحل والسبب،

   النقد: تجاهل أن البائع يلتزم بنقل الملكية — فإذا لم يقم فهو متعاقد تخلف عن تنفيذ التزام رتبه عقد صحيح، لا غير ملتزم لأن العقد باطل، والقواعد لا تقضي بأن عدم التنفيذ يجعل الالتزام بدون محل، والمنطق يؤدي لجعل الإبطال لكل ذي شأن، والنص أعطاه للمشتري وحده.

3. **الرأي الثالث – غلط في الرضا:** المشتري اعتبر ملكية البائع صفة جوهرية دفعته للتعاقد، أو وقع في غلط في شخص البائع (توهم أنه المالك)،

   النقد: يؤدي إلى ألا يكون البيع قابلاً للإبطال إلا مع حسن نية المشتري — بينما النص يعطيه الحق ولو كان سيئ النية، والنص قرر بطلاناً نسبياً خاصاً — مستثنى من القواعد العامة — **المذكرة الإيضاحية:** "أن البطلان هذا خاص إنشاء النص" — وهو المترجح عند جمهور الفقهاء.

الثمن: ركناً للبيع «محل العقد»

تعريف الثمن: الثمن: **ركن رئيسي لا ينعقد البيع بدونه** — محل التزام المشتري الأساسي، ويميز البيع عن الهبة.

شروط الثمن: يشترط في الثمن ثلاثة شروط، ويتضح ذلك في الشروط الآتية:

1. من النقود: —
2. مقدر أو قابل للتقدير: —
3. أن يكون جدياً: —

١ أولاً: من النقود:

القاعدة – م 418: **الثمن نقدي** ، فإن كان عيناً (أرض، حبوب) ← مقايضة، وإن كان مختلطاً ← العنصر الغالب (نقد ← بيع؛ عين ← مقايضة).

٢ ثانياً: مقدر أو قابل للتقدير:

نص المادة 424: **"إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف، أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة، أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما،"** فالتحديد الضمني كافٍ.

نص المادة 423: **"يجوز أن يقتصر الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد،"** فيجوز: على أساس التكلفة، أو سعر السوق، أو الثمن الذي اشترى به البائع، أو التسعيرة الرسمية في تاريخ البيع أو التسليم — بشرط أن تنأى بالعقد عن إثارة النزاع.

ما لا يجوز: "بالثمن المناسب" أو "العادل" — غموض، ولمحض إرادة أحد المتعاقدين — غبن.

التقدير بمفوض: يتفقان على أجنبي، فإن لم يتفقا — **لا ينعقد البيع إلا عند الاتفاق اللاحق** (لا إجبار)، وللقاضي استخدام الغرامة التهديدية، وإذا تعذر الاتفاق — للمتعاقد المضرور التعويض (مسؤولية عقدية عن عقد غير مسمى — يلتزم كلٌّ بالعمل على تعيين المفوض)، ويلتزمان بما يحدده المفوض، لكن لمن تضرر الطعن إذا: (أ) حصل تواطؤ مع الطرف الآخر (كبيع النجش)، (ب) خرج عن الحدود المرسومة، (ج) وقع في خطأ جسيم نتيجة غلط في صفة جوهرية.

قيود على حرية التحديد: قيّد المشرع حرية تحديد الثمن بقيدين، ويتضح ذلك في القيدين الآتيين:

NARA 01054054178

1. **السعر الإلزامي للنقود الورقية:** الأمر العالي 2/9/1914 — فرض سعراً إلزامياً للعملة الورقية للبنك الأهلي، وأبطل شرط الدفع بالذهب أو ما يعادله وقت الوفاء في المعاملات الداخلية، المرسوم بقانون 35/1935 — إبطال شرط الذهب في المعاملات الخارجية، فيوفي المشتري بالنقود الورقية المصرية على أساس قيمة الذهب المشروط **في العقد** لا وقت الوفاء، ولا يبطل البيع كله إلا إذا كان شرط الذهب هو الدافع للتعاقد.

2. **السعر الجبري لبعض السلع:** لا يجوز البيع بسعر يزيد عنه — وغالباً يقترن بإجراء جنائي، **الراجح:** عدم بطلان العقد مراعاةً للمشتري المحتاج — فيقتصر البطلان على ما يجاوز السعر الجبري، فيرد البائع الزيادة ويحتفظ المشتري بالسلعة.

٣ ثالثاً: أن يكون جدياً:

تعريف الجدي: **تنصرف إليه إرادة المتعاقدين إلزاماً للمشتري بدفعه مقابل حقيقي** .

أنواع الثمن غير الجدي: يأخذ الثمن غير الجدي ثلاث صور، ويتضح ذلك في الأنواع الآتية:

1. **صوري:** ذُكر استيفاءً للشكل فقط دون قصد الإلزام، **مطلقة** (لا دفع لأي شيء) أو **نسبية** (يخالف الحقيقي زيادة أو نقصاً)، **الحكم:** لا بيع — هبة لا تتم إلا بورقة رسمية (م 1/488)، والنسبي: ينعقد بالحقيقي لا الصوري، الإثبات: على من يدعي الصورية — إن كان طرفاً ← بالكتابة؛ وإن كان من الغير ← بكافة الطرق.

2. **تافه:** لا يتناسب البتة مع قيمة المبيع (سيارة بمائة ألف بمائة جنيه)، **الحكم:** في حكم المعدوم — لا بيع — هبة مكشوفة لا تصح إلا بورقة رسمية (م 1/488).

3. **بخس:** يقل كثيراً عن القيمة دون أن يصل لحد التافه — غالباً لقبول البائع لظروف اضطرارية أو حاجة أو عدم خبرة، **الحكم:** ثمن جدي — يكفي لانعقاد البيع، ويعطي البائع حق طلب إبطال العقد أو زيادة الثمن أو نقص مقدار المبيع في حالات الاستغلال — م 129، وقد يعطيه حق طلب تكملة الثمن إلى 4/5 ثمن المثل في بيع عقار ناقص الأهلية (م 425).

آثار عقد البيع:

المحاور الآتية

نقل الملكية	التسليم	الضمان	التزامات المشتري

الفصل الأول: التزامات البائع:

المبحث الأول: نقل الملكية:

أهمية نقل الملكية: نقل الملكية جوهر البيع وغايته — لا يتصور العقد إلا إذا ترتب عليه نقلها حالاً أو مآلاً، والنصوص المنظمة له: م 204، 207، 428-430، 932-934.

نص المادة 428: **"يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري، وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً."**

التزام البائع: التزام البائع بمقتضى المادة 428 يأخذ صورتين، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **إيجابي:** القيام بالأعمال الضرورية — كفرز المثليات، والتصديق على الإمضاء، وتقديم المستندات اللازمة للتسجيل في بيع العقار.
2. **سلبي:** الكف عن كل عمل يجعل النقل مستحيلاً أو عسيراً — كبيع العقار مرة ثانية لمشترٍ يسبق في تسجيل عقده.

ملاحظة: قد ينتقل الحق بالعقد ذاته دون عمل — في المنقول المعين بالذات المملوك للبائع (م 204).

المطلب الأول: المنقول المعين بالذات:

نص المادة 204: **"الالتزام بنقل الملكية، أو أي حق عيني آخر، ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل."**

نص المادة 932: **"تنقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد، متى ورد على محل مملوك للمتصرف، طبقاً للمادة 204، مع مراعاة النصوص**

الآتية."

شروط انتقال الملكية: لا تنتقل الملكية بمجرد العقد إلا بتوافر شروط معينة، وتأتي هذه الشروط كما يلي:

1. **منقول معين بالذات:** الحق العيني لا يتصور إلا على شيء معين بالذات، ففي المعين بالنوع (مائة إردب قمح غير معينة) — الإفراز مانع، ولو نُص صراحة على انتقال الملكية من وقت العقد،

   استثناء: بيع جزافي (قمح في مخزن معين) ← تنتقل بمجرد العقد — **"إذا كان البيع جزافياً انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنقل به في الشيء المعين بالذات،"** (يتميز عن البيع العادي للمثليات: محله يتعين بظروف زمانية ومكانية تفرزه عن جنسه).

2. **مملوك للبائع:** م 204، 932 — فاقد الشيء لا يعطيه، (سبق في بيع ملك الغير،)

3. **موجود وقت العقد:** فإن كان مستقبلاً (ثمار حديقة) — لا تنتقل إلا من وقت نضجها.

4. **عدم الاتفاق على إرجاء النقل:** انتقال الملكية حكم مكمل لا آمر — يجوز الاتفاق على خلافه: تعليقها على شرط واقف، أو إضافتها إلى أجل (سيارة بعد شهر).

آثار انتقال الملكية بمجرد العقد: تترتب على انتقال الملكية بمجرد العقد آثار خمسة، وتظهر في الآتي:

1. **الملكية للمشتري:** له حق التصرف فيه بصفته مالكاً.

2. **موقفه من الدائنين:** له طلب التسليم عند إفلاس البائع — لا اعتراض لدائنيه، ولدائني المشتري الحجز عليه تحت يد البائع.

3. **الثمر والنماء:** للمشتري من تاريخ تمام البيع — المنتجات والزيادات المدنية والطبيعية والغلة، ما لم يتفق أو يقضِ العرف بغير ذلك.

4. **التكاليف:** على المشتري من تمام البيع — ما لم يتفق أو يقضِ العرف بغير ذلك.

5. **تبعة الهلاك:** على البائع قبل التسليم — إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري، فعلى المشتري.

٢ المطلب الثاني: المنقول المعين بالنوع:

القاعدة – م 1/205: **"إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه، فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء،"** وم 933 كذلك، وقبل الإفراز — أثر العقد مجرد إنشاء التزامات شخصية (م 428).

المعين بالنوع (المثليات): ما يقوم بعضه مقام بعض في الوفاء، ويقدر بالكيل أو الوزن أو العد أو القياس (م 85) — كخمسين إردباً من القمح، عشرين قنطاراً من القطن.

الإفراز: تحويل المعين بالنوع إلى معين بالذات — تحديد المبيع وتمييزه عن المماثل، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **كيفيته:** بحسب طبيعة المبيع — وزن، عد، كيل، قياس، تجنيب وفصل، أو وضع علامة.
2. **وقته ومكانه:** وقت وجوب التسليم ومكانه — ما لم يتفق على غيره.
3. **انتقال الملكية:** من وقت حصول الإفراز دون أثر رجعي، وينتقل ولو لم يتم التسليم.
4. **حضور المشتري:** لا يشترط لصحة الإفراز — لا نص، وله حق الرفض إذا لم يكن مطابقاً للصنف أو العينة.
5. **تبعة الهلاك:** على البائع رغم الإفراز حتى التسليم.
6. **نفقات الإفراز:** على البائع — مدين بما يلزم لنقل الملكية، والإفراز من ضروراته.

جزاء الامتناع عن الإفراز – م 2/205: للمشتري إلزامه، أو الحصول على شيء من النوع ذاته على نفقة البائع بعد استئذان القاضي أو قبله في الاستعجال، أو المطالبة بقيمة الشيء — دون إخلال بحقه في التعويض.

٣ المطلب الثالث: الحقوق العقارية:

القاعدة: الملكية في العقار تنتقل **بالتسجيل** ، م 204: "... دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل،" وم 934: **"في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى — بين المتعاقدين أو في حق الغير — إلا بمراعاة الأحكام المبينة في قانون الشهر العقاري، ويبين القانون التصرفات والأحكام والسندات الواجبة الشهر، والأحكام المتعلقة به،"**

MIARA 01054054178

م 9 من قانون الشهر العقاري 114/1946: (المعمول به من 1/1/1947) — التصرفات المنشئة لحق عيني أصلي على عقار، أو الناقلة أو المغيرة أو المزيلة له، والأحكام النهائية المثبتة لذلك — يجب شهرها بالتسجيل، وعدم التسجيل ← الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول — لا بين ذوي الشأن ولا في حق الغير، ولا أثر للتصرفات غير المسجلة سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.

المستفاد: التسجيل لا يجعل البيع عقداً شكلياً — فبيع العقار رضائي يتم بالتراضي؛ إنما يلزم التسجيل ليترتب الأثر الناقل للملكية.

مرحلتان: يمر بيع العقار بمرحلتين، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **المرحلة الأولى – العقد الابتدائي (غير المسجل):** لا ينقل الملكية، يترتب عليه التزامات وحقوق شخصية (م 9 شهر عقاري)، البائع يلتزم بنقل الملكية — ومنها كل ما هو ضروري للتسجيل — والتسليم والضمان، والمشتري بالثمن والتسلم، ولكل أن يجبر الآخر — بدعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع.
2. **المرحلة الثانية – آثار العقد بعد التسجيل:** الملكية لا تنتقل إلا بعقد مسجل — بين المتعاقدين وفي حق الغير، وقبل التسجيل — مجرد أمل لا حق، لكن التسجيل بذاته ليس ناقلاً — العقد أساس — فيجب أن يكون صحيحاً صادراً من مالك، وإلا فلا أثر ولو سجل، وكذلك الصوري — العقد غير موجود، فلا أثر له ولو سجل.

1 دعوى صحة التعاقد: تتعلق بالمرحلة الأولى من بيع العقار، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **أساسها:** إجبار المدين على التنفيذ عيناً إن كان ممكناً — م 210: **"في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا سمحت بذلك طبيعة الالتزام،"** وردت في م 145 شهر عقاري 1946 و م 32 سجل عيني 143/1964.
2. **طبيعتها:** دعوى شخصية عقارية — اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها العقار، شخصية: يرفعها المشتري دائناً لا مالكاً، عقارية: محلها عقار، وتهدف لكسب حق عيني.
3. **أطرافها:** المشتري أو ورثته على البائع أو ورثته — ليواجه امتناعه (منكراً أو معترفاً)، ويطلب الحكم بثبوت البيع أو صحته ونفاذه.

4 **أثرها:** بتسجيل الحكم تنتقل الملكية للمشتري — دون حاجة لتدخل البائع.

5 **نطاقها:** موضوعية — تنصب على حقيقة البيع: صحته ومداه ونفاذه، الحكم مقرر لكل ما ورد عليه الرضا، دون حاجة للورقة الأولى، وعلى القاضي التحقق من عدم وجود سبب بطلان أو عدم تنفيذ.

شرطا نجاح المشتري: لا تنجح دعوى صحة التعاقد إلا بتوافر شرطين، وتفصيل ذلك في الآتي:

1 **إمكان التنفيذ:** فإن كان البائع قد تصرف وسجل المتصرف إليه عقده وانتقلت الملكية — لا إمكان، فترفض الدعوى، ويرجع بالتعويض.

2 **وفاء المشتري:** بالثمن أو إيداعه خزينة المحكمة بعد عرض حقيقي — لأن العقد تبادلي، والقاعدة: البائع وحده يحتج بعدم الدفع، لا غيره.

تسجيل صحيفة الدعوى: نصت م 2/15 شهر عقاري على وجوب تسجيل صحيفة الدعوى — لتفادي تصرف البائع في الفترة بين رفع الدعوى والحكم (تصرف نافذ في مواجهة المشتري ما دام الأول مالكاً)، ونصت م 2/17 على أن: حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية **ابتداءً من تاريخ تسجيل الدعوى**.

الإجراء: تسجيل صحيفة افتتاح الدعوى بعد إعلانها وقيدها بالجدول، فإذا صدر الحكم — التأشير بمضمونه على هامش تسجيل الصحيفة، وأثر التأشير: حق المشتري حجة على كل من ترتب له حق عيني من تاريخ تسجيل الصحيفة، **ملاحظة:** الملكية لا تنتقل بتسجيل الصحيفة — بل من وقت التأشير بالحكم، فلا شفعة له قبل ذلك.

2 **دعوى صحة التوقيع:** إذا كان العقد في ورقة عرفية وامتنع البائع عن التصديق على توقيعه أمام الموظف المختص — يرفع عليه دعوى صحة التوقيع، والحكم يقوم مقام التصديق، ويسجل العقد مرفقاً به الحكم.

الفروق بين الدعويين: تختلف دعوى صحة التعاقد عن دعوى صحة التوقيع في أربعة أوجه، وتأتي هذه الأوجه كما يلي:

1. **الطبيعة:** صحة التعاقد: موضوعية، / صحة التوقيع: تحفظية — التثبت من صحة التوقيع فقط.

2. **نطاق القاضي:** صحة التعاقد: يتعرض للعقد — صحته ونفاذه، / صحة التوقيع: لا يتعرض للموضوع — ويمكن للبائع الطعن بالإبطال أو الفسخ.

3. **شرط الالتجاء:** صحة التعاقد: —، / صحة التوقيع: لا بد من محرر عرفي — لا في العقد الشفوي.

4. **تسجيل الصحيفة:** صحة التعاقد: لها حماية بأثر رجعي — من تسجيل الصحيفة، / صحة التوقيع: لا تسجل، وتسجيل العقد مع الحكم لا أثر رجعي له — فإذا تصرف البائع أثناء الدعوى وسجل المتصرف إليه قبل تسجيل المشتري الأول عقده — فضل الثاني، فتفتقد حماية صحة التعاقد — ولهذا غلبت الأخيرة في التعامل.

طبيعة التسجيل: إشكال: المشرع يجعل له دوراً فعالاً في نقل الملكية مع أنه ليس ركناً شكلياً، لم يقدم الفقه إجابة واضحة تبرر الارتباط كركن، واكتفى بما يفيد أنه **شرط لنفاذ العقد**، يترتب على تخلفه عدم سريانه.

لا أثر رجعي للتسجيل: الملكية تنتقل بالتسجيل (أو من تسجيل الحكم بصحة العقد ونفاذه) — لا من وقت العقد، (الرأي السائد فقهاً وقضاءً)

التنازع بين مشتريين بعقدين مسجلين: الراجح: الملكية لمن سجل أولاً، فهل الأفضلية مطلقة؟ اختلف الفقه في ذلك على رأيين، وتفصيلهما في الآتي:

1. **الرأي الأول:** الأسبقية المطلقة للتسجيل — حتى مع علم المشتري الثاني بالبيع الأول أو تواطئه مع البائع، العبرة بالتسجيل مع صحة العقد — ووضع حد للمنازعات حول حسن النية، ويؤدي إلى استقرار الملكية العقارية — ويمشى مع نظام السجلات العينية.

MARA 01105405418

2 **الرأي الثاني:** لا أسبقية مطلقة — بتقييدين:

❶ **حسن نية المشتري الثاني** — عدم علمه بسبق البيع (يكفي العلم البسيط دون تواطؤ)،

❷ **عدم التواطؤ** — العلم وحده لا أثر له، وإنما التواطؤ على الإضرار، وأساسه: الغش يبطل كل التصرفات — فالعقد المسجل الناتج عن غش باطل ولا يصحح التسجيل، والغش عمل غير مشروع يلزم فاعله بالتعويض، وخير تعويض عدم الاعتداد بالتسجيل.

✅ **اتجاه القضاء المصري:** الأسبقية المطلقة — حتى مع تواطؤ المشتري الثاني، **ونرجحه:** الأجدى، تقوية لأثر التسجيل، اتفاقاً مع قصد المشرع، واستقراراً للملكية، ومعيار حسن النية/ التواطؤ غير منضبط ويسهل التلاعب فيه — على حساب مبدأ الاعتداد بالتسجيل.

٢ المبحث الثاني: التسليم:

ℹ **أهمية التسليم:** تمكين المشتري من الانتفاع، وفي المنقول المعين بالنوع — لا تنتقل الملكية إلا بالإفراز، وهو يتم عادة بالتسليم، وفي المنقولات المادية — يحمي المشتري ملكيته من قاعدة "الحيازة في المنقول سند الحائز"، والنصوص: م 431-438.

١ المطلب الأول: مضمون التسليم:

1 **الفرع الأول: المعنى والكيفية:** نصت المادة 435 على تعريف التسليم وكيفيته في فقرتين، وتفصيل ذلك في الآتي:

1 **الفقرة الأولى – تعريف التسليم:** **"يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته إذا كان البائع قد أعلمه بذلك، ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع،"**

2 **الفقرة الثانية – التسليم الحكمي:** **"ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين، إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع، أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع بسبب آخر غير الملكية،"**

◆ **التسليم:** إجراء يؤدي إلى تمكين المشتري من المبيع بحيث يمارس سلطاته عليه كمالك دون مانع، ويكون على نوعين، وبيانهما في الآتي:

1. **فعلي:** وضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع دون عائق — بأي وسيلة، ولا يتم الالتزام إن وُجد عائق — من البائع (استمرار زراعة الأرض، استعمال السيارة) أو من غيره، ولا يكفي الوضع — بل يلزم **علم المشتري** بإخطاره (أي طرق، ولا يلزم إعلان رسمي)، وإذا تم — تبرأ ذمة البائع ولو لم يتسلم المشتري (فالتسلم على المشتري).

2. **حكمي:** اتفاق على تغيير صفة الحيازة، المبيع تحت يد المشتري (إجارة/إعارة) — يشترى — يكفي تغيير نيته من مستأجر إلى مالك، أو يبقى في حيازة البائع بعد البيع بصفة أخرى (مستأجر/مستعير من المشتري) — التسليم حكمي.

2 الفرع الثاني: النطاق: نصت المادة 432 على نطاق التسليم، وتفصيل ذلك في الآتي:

نص المادة 432: **"يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع، وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء، وذلك طبقاً لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين."**

الملحقات: ما أعد بصفة دائمة ليكون تابعاً للأصل، بحيث لو فصل عنه لم يؤد الغرض المقصود من الشراء.

أمثلة الملحقات: تختلف الملحقات باختلاف المبيع، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **عقار:** مفاتيح، مستندات الملكية، عقود التأمين، الحقوق والدعاوى المرتبطة (حقوق الارتفاق، دعوى الضمان ضد المهندس والمقاول)، الأفران والمغاسل،
ما لا يعد من الملحقات: المرايا غير المثبتة، النجف المعلق.

2. **أرض:** البناء المقام عليها.

3. **أرض زراعية:** حقوق الارتفاق، العقارات بالتخصيص (المواشي، الآلات الزراعية).

4. **بستان:** الأشجار المغروسة، الثمار غير الناضجة،
ما لا يعد من الملحقات: الثمار الناضجة.

5. **مصنع:** المخازن، السيارات المخصصة للنقل.

6. **حيوان:** صغاره الرضع، الصوف ولو مهيأ للجز.

ملاحظة: أمثلة البيان لا الحصر (المذكرة الإيضاحية)، وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من تمام البيع، وعليه تكاليفه من هذا الوقت — ما لم يتفق أو يقضِ العرف (م 2/458).

3 الفرع الثالث: حالة المبيع وقت التسليم: أوجبت المادة 431 أن يكون التسليم بالحالة التي كان عليها وقت البيع، وهذا يلقي التزاماً آخر يسبق التسليم — المحافظة، تطبيقاً لم 206.

نص المادة 206: **"الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء، والمحافظة عليه حتى التسليم،"** ويسري على المبيع وملحقاته.

تقدير الحالة: مسألة واقع لقاضي الموضوع دون رقابة النقض.

المحافظة: تختلف المحافظة باختلاف نوع المبيع، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **معين بالذات:** المحافظة عليه، فإذا بنى البائع في الأرض المبيعة — مثلاً — كالبناء في ملك الغير بسوء نية: للمشتري طلب الإزالة، أو استبقاؤه بتعويض.
2. **معين بالنوع:** م 1/133: **"إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر التزم البائع بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط،"** فيسلم ما يقضي به الاتفاق، فالعرف أو الظروف، فالصنف المتوسط.

القدر – م 434: البائع ضامن للقدر المتفق عليه، والعجز/الزيادة — **"إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة، فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن، أو في طلب فسخ العقد، وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منها بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً،"** (تقادم سنة).

٢ المطلب الثاني: الأحكام:

1 الفرع الأول: الزمان والمكان والنفقات: تتنوع أحكام التسليم بحسب الزمان والمكان والنفقات، وتفصيل ذلك في الآتي:

MEARA 01105405478

1. **الزمان:** لا نصوص خاصة — القواعد العامة، في الوقت المتفق عليه؛ فإن لم يكن — بوقت انعقاد العقد (م 346)، والعرف قد يمنح مهلة (تجاري)، والتأجيل قد يكون ضمنياً (المبيع في مخازن بعيدة) — فيعطى البائع مهلة معقولة.

2. **المكان:** م 436: **"يكون التسليم في المكان المتفق عليه، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف: المعين بالذات — مكان وجوده وقت الإبرام، المعين بالنوع — موطن البائع أو مركز إدارة أعماله إن كان متعلقاً بها (الدين مطلوب لا محمول)، وإذا اتفق على تصدير المبيع — لا يتم التسليم إلا إذا وصل إلى المشتري (المكان المتفق على إرساله فيه)،"**

3. **النفقات:** على البائع — مدين بالالتزام (م 348) — ما لم يتفق، وفي المعين بالنوع: نفقات الإفراز على البائع، وبصفة عامة: نفقات النقل إلى مكان التسليم على البائع، وفي المنقول واجب التصدير: الشحن على البائع، أما النقل من مكان إلى آخر يريده المشتري، ورسوم المرور — فعلى المشتري ما لم يتفق أو يقضِ العرف بغيره.

2 الفرع الثاني: حق الحبس: نصت المادة 459 على أسباب ثبوته، والمادة 460 على هلاك المبيع المحبوس، وتفصيل ذلك في الآتي:

نص المادة 459: "إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال — للبائع حبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق، ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة، ما لم يمنحه أجلاً بعد البيع، ولو لم يحل الأجل المشترط — إذا سقط حق المشتري في الأجل طبقاً لم 273"

نص المادة 460: "إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع،"

الحالات: إذا لم يدفع المشتري ما هو مستحق من الثمن — تطبيقاً للحبس (م 246) والدفع بعدم التنفيذ (م 161)، **مخالفة للقواعد العامة:** م 459 أعطى البائع الحبس ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة — مع أن م 1/246 تتيح للمدين إجبار الحابس بالتأمين الكافي، **الحكمة:** كل ما يهم البائع حصوله على الثمن — فإذا لم يتم، استعمل حقه في الحبس، ويجب على البائع إثبات أنه لم يستوف كاملاً، والحق غير قابل للتجزئة — وله حبس المبيع بأكمله حتى

يستوفى الثمن كله، في حدود عدم التعسف — فلا يجوز التمسك به إذا لم يبقَ إلا جزء بسيط لا يبرر الاستعمال أو الاستمرار.

سقوطه: يسقط حق الحبس بأسباب متعددة، وتأتي هذه الأسباب كما يلي:

1. **الاستيفاء أو التنازل:** —
2. **خروج المبيع باختياره:** كسكوته عند رؤية المشتري يأخذ المبيع وهو قادر على منعه، أما الخروج خلسة أو بغير إرادته — فلا يسقط — وله الاسترداد في 30 يوماً من وقت العلم، وقبل انقضاء سنة من الخروج (م 248).
3. **حوالة البائع حقه في الثمن:** ينتقل الثمن للمحال له بضماناته — ومنها الحبس، أما حوالة المشتري البائع على أحد (حوالة دين) — لا تعد نزولاً — وله الحبس حتى يستوفى من المحال أو المحال عليه.
4. **منح أجل جديد بعد البيع:** تنازل ضمني — م 1/459. بخلاف المهلة الميسرة من القاضي — لا تسقط الحق.
5. **هلاك المبيع المحبوس:** يتحمل المشتري التبعة — يظل ملتزماً بالثمن ما لم يكن الهلاك بفعل البائع (م 460)، **استثناء** من م 437 (تبعة الهلاك قبل التسليم على البائع)، **الحكمة:** مرده إلى تقصير المشتري في الوفاء.

أحكامه: الحق في استيفاء الثمن كله — لا يتجزأ، فلا يجوز للمشتري بعد دفع جزء أن يطالب بجزء يقابله من المبيع — ولو كان قابلاً للتجزئة — ما دام بيع بصفقة واحدة، ويحتج به في مواجهة الغير — فإذا باع المشتري وأراد المشتري الثاني التسلم من البائع الأول — له الحبس حتى يستوفى، ويشمل الأصل والنماء والثمار بعد البيع — مع مراعاة أن ثمار الحبس ملك المشتري، وعلى البائع تقديم حساب الغلة، والالتزام بالمحافظة وفقاً لأحكام رهن الحيازة.

3 الفرع الثالث: تبعة الهلاك قبل التسليم: لا تثور إلا في المعين بالذات، أما المعين بالنوع — فقبل الإفراز لا ذاتية محددة، ويقدم البائع مثلاً ("المثليات لا تهلك")، وبعد الإفراز — يسري حكم المعين بالذات، والهلاك بسبب أجنبي (م 159)، أو بتقصير البائع (مسؤول مدني — فسخ ورد الثمن والتعويض)، أو بفعل المشتري (مسؤول — يدفع الثمن).

نص المادة 437 – الهلاك الكلي: **"إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسليم المبيع،"**

المقصود: زوال الشيء بمقوماته الطبيعية، **تبعة الهلاك مرتبطة بالتسليم القانوني** (لا الفعلي) — بوضع المبيع تحت يد المشتري مع علمه — فلو هلك بعد ذلك فعليه، ولو لم يستول مادياً، وتبعة الهلاك قبل التسليم على البائع — ينفسخ بقوة القانون — ويرد المشتري الثمن، (يتفق مع اتجاه الفقه الإسلامي،)

نص المادة 438 – الهلاك الجزئي: **"إذا نقصت القيمة لتلف — للمشتري: (أ) الفسخ إن كان النقص جسيماً (لو طرأ قبل العقد لما تم البيع)، (ب) البقاء مع إنقاص الثمن،"** تقدير الجسامة موضوعي — يتقرر بحكم القاضي — بخلاف الكلي (بقوة القانون).

حالات تحمل المشتري التبعة قبل التسليم: يتحمل المشتري تبعة الهلاك قبل التسليم في خمس حالات، وتأتي هذه الحالات كما يلي:

1. **الاتفاق:** القاعدة ليست آمرة — يجوز الاتفاق على تحمل المشتري.
2. **الإعذار:** إذا أعذر المشتري للتسلم في الأجل وامتنع — م 437.
3. **تحت يد البائع الحابس:** م 460 — لعدم وفاء المشتري بالثمن.
4. **وضع اليد بغير إذن أو حكم:** ليس له الاحتجاج بعدم التسليم — والمخطئ لا يستفيد من خطئه.
5. **القانون التجاري – م 94:** **"البضائع التي تخرج من مخزن البائع أو المرسل يكون خطرها في الطريق على من يملكها، ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك،"** — ترتبط التبعة بنقل الملكية — ولو لم يتسلم.

٣ المبحث الثالث: الضمان:

مضمون الضمان: ضمان بقاء ملكية المبيع والانتفاع به كاملاً دون منازعة، فيمتنع البائع عن كل فعل يعكر حيازة المشتري، ويدفع تعرض الغير، ويعوضه عن الاستحقاق، ويضمن العيوب الخفية، **لا يشترط التسجيل** — فالتزام شخصي ينشأ من العقد.

النطاق: لا يقتصر الضمان على البيع — يشمل عقود المعاوضات الناقلة (المقايضة م 485، القرض م 540، الشركة م 511)، والعقود الكاشفة (القسمة م 844)، والإيجار (م 571-587، م 638)، والهبة بعوض أو تكليف — على قدر العوض والتكليف (م 494-495)، وقد نظم المشرع أحكام الضمان في البيع تفصيلاً تقديراً لأهميته، واكتفى لغيره بالإحالة مع بيان الاختلاف عند اللزوم.

المطلب الأول: ضمان التعرض والاستحقاق:

الفرع الأول: ضمان التعرض الشخصي: المبدأ: لا يجوز للبائع أن يتعرض للمشتري قانوناً أو مادياً — "من عليه الضمان لا يجوز له التعرض" — فمن باب أولى أن يمتنع هو.

نص المادة 439: **"يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه، سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي، يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري، ويكون البائع ملزماً بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل عليه من البائع نفسه،"**

الطبيعة: طبيعي — من عقود المعاوضات، م 1/446: **"إذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسئولاً عن أي استحقاق ينشأ عن فعله، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضى بغير ذلك،"**

أمثلة: يظهر التعرض في صورتين، وتفصيلهما في الآتي:

1. **تعرض قانوني:** استعمال حق ادعاه البائع يؤدي لنزع المبيع — كأن يمتلكه بعد البيع (ميراث، شراء من المالك، تقادم مكسب)، أو رفع دعوى على المشتري للاسترداد قبل التسجيل — فالضمان والاسترداد لا يجتمعان.
2. **تعرض مادي:** اغتصاب العين؛ بيع محل تجاري ثم فتح متجر مجاور بنفس التجارة (منافسة غير مشروعة)؛ التصرف في العقار لمشترٍ ثانٍ ومبادرة التسجيل — تعرض غير مباشر.

ما لا يعد تعرضاً: المطالبة بحق قانوني للمطالبة بهدم البيع — كالتنفيذ الجبري على المبيع استيفاءً للثمن، أو طلب الحكم بالبطلان المطلق أو الإبطال أو الفسخ والاسترداد.

خصائصه: لضمان التعرض الشخصي ثلاث خصائص، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **عدم القابلية للانقسام:** لو باع عدة أشخاص مالاً على الشيوع دون تقسيم المسؤولية — التزام غير منقسم لكل منهم — يسأل عن المبيع بأكمله لا في حدود نصيبه، ولا يقسم بالانتقال للورثة.
2. **التأبيد:** لا يجوز التعرض في أي وقت ولو بعد 15 سنة، ودعوى الضمان — تسقط كغيرها بمرور 15 سنة من وقت حصول التعرض، ولو وضع البائع يده على المبيع (تعرض) وسكت المشتري 15 سنة — انقلب سبباً مشروعاً للتملك لا يحول دونه ضمان البائع.
3. **عدم جواز الإعفاء:** م 1/447 — إبطال شرط إعفاء البائع من ضمان تعرضه الشخصي — كالإعفاء من الغش أو الخطأ الجسيم، لكن **الإعفاء الجزئي** صحيح: كقصر الضمان على عمل معين يكون البائع غير مسؤول عنه (بائع المتجر يحتفظ بحق فتح محل لبعض السلع) — لافتراض أن المشتري أدخله في تقديره عند الثمن، ويجوز **تشديد** الضمان (كمنع المنافسة في سلع أخرى يريدها المشتري).

الجزاء: وقف التعرض (إغلاق المحل)، والتعويض، والغرامة التهديدية، وفي التعرض القانوني — للمشتري الدفع بالضمان، أو الفسخ (رقابة القاضي) مع التعويض.

2 الفرع الثاني: ضمان التعرض من الغير: الطبيعة: التزام إيجابي — بتحقيق نتيجة (لا بذل عناية)، فإذا لم ينجح البائع في دفع التعرض — دفع التعويض (ضمان الاستحقاق).

شروطه: لا يتحقق ضمان التعرض من الغير إلا بتوافر ثلاثة شروط، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **تعرض قانوني:** ادعاء الغير حقاً على المبيع (ملكية، انتفاع، ارتفاق)، أما التعرض المادي (اغتصاب، سرقة) — لا يسأل عنه البائع بعد تسليم المبيع، ويدفعه المشتري قانوناً، وقبل التسليم — على البائع (وإلا أخل بالتزامه).

2. **استناد التعرض إلى سبب سابق على البيع أو راجع إلى فعل البائع:** كأن يستند الغير إلى ملكية سابقة، أو حق ارتفاق/انتفاع/سكنى/حكر/رهن سابق، أو وضع يد مكتمل بالتقادم المكسب قبل البيع، أما الصادر بعد البيع — لا يضمنه إلا إذا كان بفعل البائع (كبيع العقار ثانياً وتسجيل الثاني) — فيضمن، فإن كان بفعل المشتري (إهمال قطع التقادم) — فلا، وكذلك بالقوة القاهرة (نزع الملكية للمنفعة العامة) — المخاطر بعد البيع على المشتري.

3. **أن يكون حالاً:** موقف إيجابي من الغير — دعوى يرفعها على المشتري مطالباً بحق — أو يدفع الغير بأن له حقاً، مجرد الخشية — لا، (ومع ذلك — للوقاية: حبس الثمن م 2/457، أو الفسخ بالقواعد العامة، أو الطعن بيعاً لملك الغير م 466.)

أحكامه – التنفيذ العيني: نصت المادة 440 على أحكام التنفيذ العيني لضمان التعرض من الغير، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **إخطار البائع:** إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق وأخطر بها البائع — كان عليه وفقاً لقانون المرافعات أن يتدخل إلى جانب المشتري أو يحل محله، فإن تدخل ورفضت الدعوى — نفذ التزامه عيناً، وإن حكم للمدعي — أخل — فيضمن الاستحقاق، وإن لم يتدخل رغم الإخطار — المشتري يدافع وحده — فإن حكم بالاستحقاق — ضمن، إلا إذا ثبت أن الحكم نتيجة **تدليس** من المشتري أو **خطأ جسيم** منه.

2. **الإخطار:** لا شكل خاص — إنذار رسمي، خطاب مسجل أو غير مسجل، شفوي (عبء الإثبات على المشتري)، وللمشتري إدخال البائع في الدعوى (م 117 مرافعات).

3. **عدم الإخطار:** إذا لم يخطر وسار وحده وخسر — يظل له الرجوع بالضمان، لكن للبائع التخلص بإثبات أن تدخله كان يؤدي لرفض الدعوى.

4. **الصلح والاعتراف – م 441:** يثبت حق المشتري في الضمان ولو اعترف — وهو حسن النية — للأجنبي بحقه، أو تصالح معه دون انتظار حكم — متى أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه للحلول محله فلم يفعل — ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن على حق.

MIARA 01105403478

5 **توقي الاستحقاق – م 442:** إذا توقاه المشتري بدفع مبلغ أو أداء شيء — للبائع التخلص من نتائج الضمان برد المبلغ أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية والمصروفات، (تقتصر على التوقي قبل الحكم — فإن صدر الحكم ثم اتفق المشتري مع المستحق على ترك العين بمقابل — لا تخلص — ويرجع بضمان الاستحقاق،)

ضمان الاستحقاق: الاستحقاق الكلي: حرمان المشتري كاملاً من الحق المبيع (باع ما لا يملك، حكم للمالك، أو بدون حكم — كتنفيذ دائن مرتهن على العقار م 1/80، أو حكم بإبطال البيع أو فسخ سند ملكية البائع).

عناصر التعويض – م 443: يتكون التعويض عن الاستحقاق الكلي من عناصر متعددة، وتفصيل ذلك في الآتي:

1 **قيمة المبيع وقت الاستحقاق + الفوائد القانونية:** القيمة وقت رفع دعوى الاستحقاق (الحكم يستند لوقت الرفع) — سواء أكثر أو أقل من الثمن (فلسنا في دعوى إبطال/فسخ — بل ضمان — التعويض على أساس الحرمان)، والفوائد القانونية من وقت الاستحقاق — **خروجاً** على م 226 (من وقت المطالبة) — لحرمانه من المبيع من وقت الاستحقاق، (الفوائد زيادة في غير مقابل — رباً تحرمه الشريعة — فالقيمة دين ثابت من وقت الاستحقاق — وما زاد عليها في مقابل الزمن،)

2 **قيمة الثمار التي أُلزم بردها للمستحق:** ما قبضه وهو سيئ النية (م 979)، فإذا كان يعلم بالحق قبل الدعوى — يرد من وقت العلم — وله الرجوع على البائع، أما ثمار ما بعد رفع الدعوى — لا رجوع (لأنه سيئ النية بعد الدعوى — م 2/966) — استعاض عنها بالفوائد القانونية.

3 **المصروفات:** تتنوع المصروفات إلى ثلاثة أنواع، وتفصيلها في الآتي:

1 **ضرورية:** لحفظ المبيع وصيانته — يرجع بها على **المستحق** لا البائع (م 1/680)، سواء حسن النية أو سيئه.

2. **نافعة:** تزيد القيمة (بناء، غراس) — أحكام الالتصاق: **حسن النية** — يخير المستحق بين قيمة المصروفات (مواد وأجرة) أو ما زاد في الثمن (م 925) — فيختار الأقل — وللمشتري الرجوع على البائع بالفرق، **سيئ النية** — للمستحق طلب الإزالة خلال سنة من العلم، أو الاستبقاء مقابل قيمة مستحقة الإزالة، أو ما زاد في الأرض (م 924) — والمشتري يرجع بالفرق.

3. **كمالية:** زينة وزخرفة — لا تجب على المستحق (م 3/980) — وله نزع منشآته إلا إذا اختار المستحق الاستبقاء بقيمة مستحقة الإزالة، وللمشتري الرجوع على البائع بها **فقط** إذا كان سيئ النية — أي يعلم سبب الاستحقاق وقت البيع (م 443).

4. **مصروفات دعوى الضمان والاستحقاق:** عدا ما كان يستطيع اتقاءه لو أخطر البائع (م 440).

5. **تعويض الخسارة والكسب:** كل ما لا تشمله الحالات السابقة — كمصاريف تحرير العقد والسمسرة ورسوم التسجيل — وفقاً للمسؤولية العقدية، (ما لم يكن الرجوع مبنياً على الفسخ أو الإبطال).

📖 **نص المادة 444 – الاستحقاق الجزئي:** **"إذا استحق بعض المبيع أو وُجد مثقلاً بتكاليف، وكانت خسارة المشتري بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد — له المطالبة بالمبالغ السابقة، على أن يرد المبيع وما أفاد منه، فإذا اختار استيفاء المبيع، أو كانت الخسارة لم تبلغ ذلك القدر — ليس له إلا التعويض عما أصابه بسبب الاستحقاق."**

◆ **حالتا الاستحقاق الجزئي:** يختلف حكم الاستحقاق الجزئي باختلاف جسامة الخسارة، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **الخسارة الجسيمة:** (تقدير لقاضي الموضوع دون رقابة النقض) — كاستحقاق جزء من أرض لمشروع، أو ثبوت انتفاع بالسكنى على منزل للسكنى، **الخيار:** (أ) رد المبيع وما أفاد منه ومطالبة البائع بالتعويض كما في الكلي (م 443)، (ب) استبقاء المبيع والتعويض عن الاستحقاق الجزئي.

2. **غير الجسيمة:** استبقاء المبيع والتعويض عن الجزء المستحق — شاملاً الخسارة والكسب (م 221).

الاتفاق على تعديل الضمان: القواعد **مكملة** لا آمرة — يجوز الزيادة أو النقص، م 1/445 — اتفاق صريح على الزيادة أو النقص أو الإسقاط، فإذا لم يوجد اتفاق — سرت النصوص (م 349 وما بعدها)، **م 2/445:** قرينة قانونية — البائع اشترط عدم الضمان فيما يتعلق بحق الارتفاق المرتب على العين المبيعة إذا كان **ظاهراً** أو **أبان عنه** للمشتري، **م 3/445:** إذا اشترط البائع إعفاءه كله أو بعضه وكان قد **تعمد إخفاء** حق لأجنبي — الشرط **باطل** — ولا يعفي من شيء.

ملاحظة: إذا صح الإعفاء — لا يعفي البائع بأي حال من المسؤولية عن استحقاق ينشأ **من فعله** (م 1/446)، أما إذا نشأ عن فعل الغير — يعفيه من التعويضات، لكنه لا يعفيه من دفع قيمة المبيع وقت الاستحقاق — إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق، أو أنه اشترى ساقط الخيار (مخاطراً بنتائج الاستحقاق).

٢ المطلب الثاني: ضمان العيوب الخفية:

تمهيد: لا يقتصر الضمان على التعرض والاستحقاق — بل يشمل العيوب الخفية التي تجعل المبيع غير صالح لتحقيق غاية المشتري، النصوص: م 447-455. جعل المشرع للمشتري دعوى خاصة، لا يتركه للقواعد العامة.

1 الفرع الأول: شروط العيب الموجب للضمان: نصت المادة 447 على قاعدة ضمان العيب، والمادة 448 على استثناء العيب المتسامح فيه، وتفصيل ذلك في الآتي:

نص المادة 447: **"يكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، وإذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته، أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد، أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده، ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه، لو أنه فحص البيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من العيب، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه،"**

نص المادة 448: **"لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه،"**

شروط العيب الموجب للضمان: يشترط في العيب الموجب للضمان ثلاثة شروط، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **قديم:** موجود وقت التسليم — كإصابة الحيوان بجرثومة في يد البائع، أو السوس في الخشب قبل التسليم وظهوره بعده، فالبائع لا يضمن إلا ما كان موجوداً وقت العقد أو طرأ حتى التسليم، أما ما حدث بعد التسليم — فعلى المشتري أو على المسؤول عن إحداثه.
2. **مؤثر:** ينقص القيمة أو النفع بحسب الغاية المقصودة (من العقد أو طبيعة الشيء أو الغرض)، تقدير الجسامة لقاضي الموضوع — بمعايير موضوعية لا شخصية، م 448: لا يضمن العيب المتسامح فيه عرفاً — لأن التسامح دليل على يسار النقص أو عدم تأثيره (كقليل الأتربة في القمح، أو نسبة المواد الغريبة في السمسم في حدود المتفق عليه).
3. **خفي:** لا يتبينه الرجل العادي أو لا يكشفه غير خبير أو لا يظهر إلا بالتجربة، المعيار موضوعي (قدرة الرجل العادي لا المشتري)، وفي الأشياء التي تتطلب خبرة (منزل — مهندس معماري، آلة بخارية — خبير) — لا يعد خفياً إلا إذا عجز الرجل العادي عن اكتشافه، فإذا قعد المشتري عن الاستعانة بالخبراء واكتفى بفحصه الشخصي مع نقص خبرته — فلا ضمان.

الاستثناءان من العيوب الظاهرة – م 1/447: يستثنى من قاعدة عدم ضمان العيوب الظاهرة حالتان، وتفصيلهما في الآتي:

1. **أن يؤكد البائع خلو المبيع من العيب:** يعتمد المشتري ولا يفحص — فيظل الضمان.
2. **أن يتعمد البائع إخفاء العيب غشاً:** كإخفاء كسر في الموتور، وبشرط إخطاره خلال مدة معقولة، وإلا اعتبر قابلاً للمبيع.

الإخطار بالعيب: تتعلق بالإخطار بالعيب أحكام متعددة، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **الوجوب:** إذا كان العيب مما لا يمكن كشفه بالفحص المعتاد ثم كشفه — يجب إخطار البائع بمجرد ظهوره، وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه، ويجب المبادرة بالتحقق متى تسلم، فإذا بدا عيب يوجب الضمان — المبادرة بالإخطار.

2. **المدة:** مسألة موضوعية لقاضي الموضوع.
3. **الشكل:** لا شكل معين — محضر، مسجل، عادي، شفوي — بشرط إمكان الإثبات.
4. **العبء:** على المشتري — بكافة الطرق بما فيها البينة والقرائن.
5. **التسليم:** الفعلي لا الحكمي — الحيازة والاستيلاء المادي.

2 الفرع الثاني: الحقوق المقررة للمشتري: أحالت المادة 450 إلى المادة 444 (الاستحقاق الجزئي)، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **خسارة جسيمة:** (لو علمها لما أتم العقد) — الحكم بتعويض الاستحقاق الكلي — يرد المبيع وما استفاده، أو يستبقيه مع التعويض.
2. **غير جسيمة:** لا فسخ — لكن تعويض عيني (إصلاح البائع إن قبل)، أو نقدي — والخيار للمحكمة.

3 الفرع الثالث: هلاك المبيع وأثره: نصت المادة 415 على بقاء دعوى الضمان رغم هلاك المبيع، وتفصيل ذلك في الآتي:

نص المادة 415: **"تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان،"** فالهلاك لا يسقط الحق — بأي سبب: العيب ذاته، أجنبي، فعل المشتري، (مع اختلاف الحقوق،)

الهلاك بسبب العيب نفسه: (تهدم منزل، موت حيوان مريض) — تعويض كامل دون رد إذا كان كلياً، وإذا جزئياً — يرد ما بقي.

مدة دعوى ضمان العيب – م 1/452: **سنة** من تاريخ التسليم الفعلي، القصر — لاستقرار الصفقة والتعامل، التسليم المعتبر بدء التقادم — الفعلي — لأنه يهيئ فرصة الفحص، **يجوز الاتفاق على مدة أطول** — م 1/452. أما **الأقصر** — الراجح عدم الجواز — لأن الإطالة استثناء لا يتوسع فيه.

ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة – م 455: إذا ضمن البائع الصلاحية مدة معلومة ثم ظهر خلل — على المشتري إخطار البائع في **شهر** من ظهوره، ورفع الدعوى في **ستة أشهر** من الإخطار، وإلا سقط حقه — ما لم يتفق على غير ذلك، (كثير في الآلات الدقيقة

— الراديو، الساعات، السيارات، آلات التصوير، وقد يتفق على زيادة خمس سنوات أو نقص ستة أشهر.)

الفصل الثاني: التزامات المشتري:

المبحث الأول: دفع الثمن:

تمهيد: دفع الثمن مقابل التزام البائع بنقل الملكية — في الأهمية، الثمن يعينه المتعاقدان — في العقد أو بعد ذلك تبعاً للأسس، وعلى المشتري نفقات دفع الثمن (إرساله إلى البائع في مكان الوفاء — م 38)، وتلحقه الفوائد القانونية — م 1/458 (مع مراعاة تحريم الفوائد الربوية شرعاً).

الفوائد القانونية: تستحق الفوائد القانونية في حالتين، وتفصيلهما في الآتي:

1. **مع الإعذار:** الثمن مستحق + إعذار المشتري للوفاء — يستحق من وقت الإعذار، (**مخالف للقواعد** — من وقت المطالبة القضائية.)
2. **مع قابلية المبيع للثمر:** البائع سلّم المبيع + المبيع قابل للثمر أو الإيراد + الثمن مستحق — من وقت تسليم المبيع، **الحكمة:** تجنب جمع المشتري بين فائدة المبيع (الثمار/الإيرادات) وفائدة الثمن، (الفوائد على الديون رباً محرماً شرعاً.)

نص المادة 456 – مكان الوفاء: **"الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سُلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف بغير ذلك، فإذا لم يكن مستحقاً وقت التسليم — الوفاء في موطن المشتري وقت الاستحقاق."**

حالتا مكان الوفاء: تختلف قاعدة مكان الوفاء باختلاف وقت استحقاق الثمن، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **مستحق وقت التسليم:** المكان الذي سُلم فيه المبيع — **مخالف** للقاعدة العامة (م 1/347 — موطن المدين، أو مركز الأعمال) — لأن العقد ينفذ جملة واحدة، فيدفع الثمن وقت التسليم.
2. **غير مستحق وقت التسلم:** القاعدة العامة — موطن المشتري وقت الوفاء، أو مركز أعماله إذا تعلق الالتزام بها (م 1/347).

الجزاء: إجباره على الوفاء — بحبس المبيع إن لم يسلمه، وأولوية في الاستيفاء من المبيع على دائني المشتري الآخرين — امتياز (م 145، 147)، وطلب الفسخ إن لم يدفع — م 2/157. هذا الفسخ — **في بيع المنقول** — يقع **بقوة القانون** دون حكم ودون إعذار — **مخالفة للقواعد** — مراعاةً لأن عروض التجارة كثيراً ما تنقلب أسعارها وتتلف بسرعة فلا تتحمل طول الإجراءات.

شروط الفسخ بقوة القانون – م 461: لا يقع الفسخ بقوة القانون إلا بتوافر ثلاثة شروط، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **المبيع منقول:** كالسلع والبضائع.
2. **اتفاق على ميعاد واحد لدفع الثمن وتسلم المبيع:** (يتحدد بالاتفاق أو العرف) — فإذا اختلف ميعاد التسليم عن ميعاد دفع الثمن — لا يسري — يرجع للقواعد العامة.
3. **إخلال المشتري بالدفع في موعده:** ليس تمسكاً بحق الحبس بسبب عدم تسليم البائع.

طبيعة الحق: للبائع وحده — فله التغاضي وطلب الوفاء بعد الموعد إن وجد مصلحته، ولا يجوز للمشتري التمسك بالفسخ — فهو المقصر، لا يستفيد من تقصيره، وليس أمراً — يجوز الاتفاق على خلافه.

٢ المبحث الثاني: المصروفات:

نص المادة 462: **"نفقات عقد البيع ورسوم الدمغة والتسجيل وغير ذلك من المصروفات تكون على المشتري ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك."**

تقنين لما جرى عليه العمل: تحمل المشتري مصاريف إعداد العقد وأتعاب المحامي والكاتب العمومي، ورسوم التصديق على التوقيعات، والتسجيل، وغيرها مما يتصل بالتحرير والتسجيل، وغالباً تدفع مصلحة المشتري للقيام بالسرعة، وقد يقضي العرف بالاقتسام — فيرجع البائع بما دفع عن المشتري، وتكاليف المبيع على المشتري من وقت البيع — وله ثماره من هذا الوقت (الغرم بالغنم).

٣ المبحث الثالث: تسلم المبيع:

تمهيد: تسلم المبيع مقابل التزام البائع بالتسليم، يتحقق بحيازة المشتري والاستيلاء.

MARA 01105405478

نص المادة 463: إذا كان المبيع منقولاً موجوداً بموطن البائع دون اتفاق أو عرف — يتسلمه المشتري في موطن البائع، وإذا لم يتقدم — مخلاً، والزمان — زمان التسليم — إلا باتفاق.

نص المادة 464 – نفقات التسلم: على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق — فيتحمل نقل المبيع من مكان وجوب التسليم/التسلم إلى المكان الذي يقصده.

الجزاء عند إخلال المشتري: إذا أخل المشتري بالتسلم، تترتب على ذلك عدة جزاءات، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **إجباره على التنفيذ عيناً:** —
2. **الفسخ:** —
3. **م 336 – بعد الإعذار:** إذن القاضي بإيداع المبيع على ذمته ونفقته في مكان آخر إن كان منقولاً، أو وضعه تحت الحراسة إن كان عقاراً.
4. **إذا كان مما يتسارع للتلف أو يقتضي نفقات مرتفعة:** بيعه بالمزاد العلني بعد استئذان القاضي وإيداع الثمن خزانة المحكمة.
5. **الفسخ مع التعويض عن الضرر:** —

ملاحظة: بعد الإعذار — إذا لم يتسلم وهلك — التبعة عليه.

MNARA 01105405478

العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

• المذكـرة الأساسيـة •

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

- تأصيل تحليلي
- تطبيقات قضائية
- صياغة أكاديمية

مـدنـي (عقد الإيجار)

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثالثة

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

الأحكام العامة لعقد الإيجار:

المحاور الآتية

الأحكام العامة	انعقاد الإيجار	آثار الإيجار	أسباب انتهاءه

الأحكام العامة لعقد الإيجار:

١ ماهية عقد الإيجار | ٢ تمييزه عن غيره من العقود

١ الفصل الأول: ماهية عقد الإيجار:

التعريف من نص المادة 558 مدني: **"عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم."**

1. **التزام المؤجر: إيجابي لا سلبي:** يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع، لا مجرد ترك العين، وهوالإلتزام الذي يميز الإيجار، فالإيجار يرد على المنفعة، والبيع على العين.
2. **مدة معينة:** يتفق عليها الطرفان، فإن غفلا تولى القانون تحديدها.
3. **الأجرة: عنصر أساسي** يميز العقد، وتدفع وفق الاتفاق، فإن أغفل الطرفان تحديدها وجب دفعها بالطريقة التي يحددها القانون.
4. **محل العقد:** شيء من الأشياء؛ فإن ورد على الأشخاص أو الخدمات فلا يسمى إيجاراً بل عقد عمل أو استصناع، (وكان القانون المدني القديم يفرق بين إجارة الأشياء وإجارة الخدمات والأشخاص).

– خصائص عقد الإيجار

١ عقد رضائي:

القاعدة: يتم بمجرد الإيجاب والقبول، لا يشترط لانعقاده شكل خاص، ويجوز للمتعاقدين الخروج على الرضائية بالاتفاق على شكل معين (رسمي أو عرفي)، فلا ينشأ العقد إلا بالإفراغ في

الشكل المتفق عليه — لأن الرضائية في الإيجار ليست من النظام العام، فيجوز الخروج عليها باتفاق صريح.

العقد رضائي: يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة، إلا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة في حدودها ودون مجاوزة لنطاقها.

سلطة محكمة الموضوع: تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود المتعاقدين، بشرط ألا تخرج عما تحتمله العبارات أو تجاوز المعنى الظاهر.

التفسير المغاير: إذا أرادت حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها وجب أن تبين في حكمها الأسباب المقبولة المبررة للعدول، وكيف أفادت العبارات المعنى الذي أخذت به — ليتضح لمحكمة النقض أنها اعتمدت اعتبارات معقولة.

1. **ق 178 لسنة 1952:** (الإصلاح الزراعي) — م 36: عقد الإيجار يكون مكتوباً.
2. **ق 49 لسنة 1977:** (إيجار الأماكن): ضرورة إبرام عقود الإيجار كتابةً، ويلتزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة بأن يثبت في العقد تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى أو الوحدة وفقاً للمادة السابعة منه.

طبيعة شرط الكتابة: بيد أن شرط الكتابة في قوانين إيجار الأماكن **للإثبات لا للانعقاد** ؛ إذ قصدت إلزام الملاك بتحرير عقود يبين فيها الأجرة الإجمالية وبعض البيانات، لتكون هناك رقابة قانونية فاعلة على اتباع أحكام قواعد إيجار الأماكن الآمرة، وحتى لا يقع المستأجرون فريسة للاستغلال والتهديد بالطرد في أي وقت.

2 عقد ملزم للجانبين وعقد معاوضة:

عقد ملزم للجانبين: يرتب التزامات في جانب كل من طرفيه، فهو من العقود التبادلية: الالتزامات ترتبط بحيث يصبح كل التزام على طرف سبباً لالتزام الطرف الآخر، فإذا بطل أو انقضى التزام أحدهما لأي سبب، بطل أو انقضى التزام الآخر تبعاً له، وإذا تخلف أحدهما عن التنفيذ كان للآخر أن يدفع بعدم التنفيذ أو يطلب الفسخ.

عقد معاوضة: يحصل كل من طرفيه على مقابل لما التزم به: المؤجر على الأجرة، والمستأجر على المنفعة، وهي تميزه عن العارية حيث ينتفع المستعير دون مقابل.

3 يرد على المنفعة لا على الملكية:

القاعدة: محل الإيجار الانتفاع بشيء معين متمثل في العين المؤجرة ولمدة محددة، أما محل الملكية فتملك كامل وسلطات كاملة على المبيع دون قيد زمني.

المحكمة الدستورية العليا: أكدت أهمية هذه التفرقة واعتمادها أساساً للقضاء بعدم دستورية أي نص لا يحترمها وما يترتب عليها من آثار،
وقضاؤها مطرد على أن صون الدستور للملكية الخاصة مؤداه: ألا يجرد المشرع الملكية من لوازمها، ولا يفصل عنها أجزاءها، ولا ينقص من أصلها أو يعدل من طبيعتها أو يزيلها، ولا يقيد مباشرة الحقوق المتفرعة عنها في غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية — وكان ضمان وظيفتها مفترضاً ألا ترهق القيود المفروضة عليها، ولا أن يكون من شأنها حرمان أصحابها من تقدير صور الانتفاع، فصون الملكية وإعاقتها لا يجتمعان؛ وهدمها بقيود ترهقها ينحل عصفاً بها منافياً للحق فيها.

تتمة القضاء الدستوري: وقضاؤها جرى كذلك على أن الملكية لا تعتبر حقاً مطلقاً وليس لها من الحماية ما يجوز الانتفاع المشروع بعناصرها؛ ومن ثم جاز تحميلها ببعض القيود التي يقتضيها صون وظيفتها الاجتماعية — التي لا يجوز أن يتذرع المشرع بها ليجرد الملكية من ثمارها أو منتجاتها أو ملحقاتها.

4 عقد مدة:

القاعدة: الزمن عنصر أساسي؛ فلا يتصور انتفاع بالعين إلا خلال فترة (يوم، شهر، سنة)، ولابد أن تكون المدة مؤقتة؛ فالتأبيد يؤدي إلى فصل المنفعة عن الملكية وهو غير جائز قانوناً.

1. **الفسخ:** ليس له أثر رجعي.
2. **عدم التمكين:** عدم تمكين المستأجر من الانتفاع بسبب لا يد له فيه يعفيه من الأجرة عن المدة المستقبلة؛ لأن الأجرة مقابل المنفعة.

5 يرد على الأشياء غير القابلة للاستهلاك:

القاعدة: لا يرد على الأشياء القابلة للاستهلاك؛ لأن تأجيرها يعني التصرف فيها، إذ تهلك بمجرد استعمالها — كالمواد الغذائية والنقود.

MARA 01054058478

6 الأصل فيه أنه من أعمال الإدارة:

بالنسبة للمؤجر: يدير ملكه، لا يتصرف فيه؛ يمنح ثمار الشيء ويحتفظ بأصله.

بالنسبة للمستأجر: من أعمال التصرف، وقد يكون إدارة على سبيل الاستثناء.

الأثر القانوني: بناءً عليه: **أهلية الإدارة للإيجار، وأهلية التصرف للاستئجار** .

2 الفصل الثاني: تمييز عقد الإيجار عن غيره من العقود:

– أولاً: الإيجار والبيع:

الوجه	البيع	الإيجار
التكييف	تصرف — ينقل الملكية أو يلتزم البائع بجعل المشتري مالكاً.	إدارة — لا يلزم المؤجر إلا استعمال العين والانتفاع بها مقابل الأجرة.
حرية الاستعمال	للمشتري أن يستعمل المبيع كما يراه مناسباً.	ملزم باستعمال العين وفق ما أعدت له أو حسب الاتفاق.
الضمان	لا يضمن البائع إلا العيوب الموجودة وقت البيع.	يضمن المؤجر العيوب التي تظهر أثناء مدة الإيجار.
الهلاك	تبعة هلاك المبيع على المشتري.	تبعة هلاك العين المؤجرة على المؤجر.
الامتياز	يخضع لقواعد مختلفة.	يخضع لقواعد مختلفة.

الحالة الأولى: النزول عن الثمار أو المنتجات: **الثمار** (منفعة متجددة) ← إيجار،

المنتجات (غير دورية وتنتقص من أصل الشيء) ← بيع،

وقد يرد العقد على الثمار ولا يسمى إيجاراً: كبيع صاحب الأرض المحصول الناتج عنها وهو ما يزال في الأرض، والراجح — ونحن معه — أن القاضي يكيف العقد بحسب نية المتعاقدين مستعيناً بقرائن الحال، وله مطلق الحرية في التقدير دون رقابة محكمة النقض.

الحالة الثانية: البيع الإيجاري: عقد يتفق فيه المؤجر والمستأجر على أنه إذا استمر المستأجر في دفع الأقساط في مواعيدها ولمدة محددة تحول العقد إلى بيع، واعتبرت الأجرة أقساطاً للثمن؛ وإذا تخلف عن قسط وجب رد الشيء لمالكه دون استرداد ما دفعه — لأنه

أجرة انتفاع، ويلجأ إليهما المتعاقدان عند عجز المشتري عن دفع الثمن دفعةً واحدة، فيؤجل الثمن ويشترط البائع دفعه أقساطاً دورية، ثم يوصف العقد إيجاراً يتحول إلى بيع عند الوفاء بكل الأقساط، ولا شك أن هذا الوصف يحقق حماية أكثر للبائع، فلا يمكن للمتعاقد الآخر التصرف في الشيء قبل الوفاء بكل الأقساط وإلا كان مبدداً ووقعت عليه العقوبة الجنائية.

رأي: إيجار وبيع في آن واحد، إيجار معلق على شرط فاسخ، وبيع معلق على شرط واقف.

الرأي الثاني (الراجح): بيع بالتقسيط، عُلقت الملكية فيه على شرط واقف هو الوفاء بكل الأقساط — فيكون بيعاً ولو وصف إيجاراً، ونقد الأول من ناحيتين: (أ) وصف العقد بيعاً وإيجاراً معاً غير مقنع؛ فالعقد إما بيع وإما إيجار، (ب) التكييف بهما يجعل البيع يتم بلا ثمن؛ لأن انتقال الملكية متوقف على دفع أجرة أقساطاً لا على دفع ثمن، والثمن عنصر جوهري في البيع لا يمكن إغفاله.

تأكيد القانون المدني: وقد أكد القانون المدني المصري الحالي هذا الرأي، فنصت ← **430/1** : "إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع."

ثانياً: الإيجار والعمل:

نص المادة 674 عمل: عقد العمل "هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر."

الوجه	عقد العمل	عقد الإيجار
المقصود	حصول رب العمل على خدمات العامل.	حصول المستأجر على منفعة الشيء.
المحل	الإنسان.	منفعة الشيء.

حالة يصعب فيها التمييز: اتفاق شركة مركبات مع سائق على أن تقدم له مركبة يستغلها نظير أجر معين للشركة ويحتفظ بباقي الأرباح.

المعيار: التبعية، فإن كان السائق خاضعاً لإشراف الشركة ورقابتها وتوجيهها — مواعيد العمل وخط السير أثناء الاستغلال — فالعقد عمل؛ وإن انتفت الرقابة واستقل في الاستغلال

فهو مستأجر، والعقد إيجار، واستقر الفقه والقضاء على ضرورة التبعية؛ لأنها السمة المميزة لعقد العمل.

1. **الآثار العملية (عمل):** تطبيق قواعد إصابات العمل بين الشركة والسائق، فيستطيع التعويض دون إثبات خطأ في جانبها — على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه.
2. **الآثار العملية (إيجار):** يلتزم السائق برد السيارة بالحالة التي تسلمها، ويكون مسئولاً أمام الغير عن الأضرار التي تسببها السيارة ما لم يكن الحادث بسبب أجنبي لا يد له فيه.

ثالثاً: الإيجار والمقاولة:

نص المادة 646 مدني: المقاولة "عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر."

الفرق: الفرق واضح: محل المقاولة نتيجة معينة بغض النظر عما يتطلبه الحصول عليها من زمن يطول أو يقصر، أما في الإيجار فالانتفاع هو النتيجة المقصودة، ولا تتحقق إلا من خلال العنصر الزمني، لكن الواقع العملي يقدم اتفاقات تختلط فيها عناصر العقدين — بأن يستفيد أحد المتعاقدين من عمل الآخر ومن شيء مملوك له في آن واحد:

الصورة	التكييف
اشتراك التليفون	الراجح: مقاولة — يرد على عمل هو توصيل المشترك بغيره من المشتركين، وهذا الغرض الوحيد من الاشتراك.
دار العرض والمتفرج	الراجح: مقاولة — الغرض عرض الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، والمقعد وسيلة لتحقيقه لا غاية.
إعلانات على السطح أو الحائط	بحسب مضمون التزام المالك: إن اقتصر على تمكين صاحب المتجر من الإعلان — إيجار؛ وإن التزم بالأعمال اللازمة لإجراء الإعلان — مقاولة.

رابعاً: الإيجار والوديعة:

نص المادة 718 مدني: "الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيء من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عيناً."

الفرق: الإيجار يمنح المستأجر مكنة الانتفاع؛ والوديعة تهدف إلى مجرد المحافظة ثم الرد دون استعمال.

مثال الجراج: اتفاق مالك سيارة مع صاحب جراج عمومي على وضع سيارته لحفظها وتنظيفها في أوقات عدم استعمالها لقاء مقابل:

إيجار: إن كان صاحب السيارة هو الذي يضعها على مسئوليته بعد تخصيص مكان معين، ويأخذ مفاتيحها، دون التزام الجراج بالحفظ،

وديعة مأجورة: إن كان صاحب الجراج هو الملتزم بالمحافظة والحراسة (الغالب).

الوجه	الإيجار	الوديعة
الحيازة	منقولات العين المؤجرة في حيازة المستأجر.	—
طريق الدائنين	حجز تنفيذي تحت يد المدين — يحتاج سند تنفيذي، وتنبيه بالوفاء، وإعلان بالحجز.	حجز ما للمدين لدى الغير — تحفظي، لا يحتاج سنداً ولا تنبيهاً ولا إعلاناً.
هلاك الأشياء	المالك لا يسأل عن ضياع منقولات المستأجر أو هلاكها متى كان سبب الهلاك عيباً خفياً في العقار.	المودع لديه مسئول حتى يثبت السبب الأجنبي.

تطبيق الحجز التحفظي: وإلزام الدائنين بالحجز التنفيذي إرهاق وضياع للغرض؛ إذ يجب أن يكون لديهم سند تنفيذي، وأن يسبق الحجز تنبيه بالدفع — بما يتيح للمدين الإخفاء، مع مراعاة أن تأجير الخزائن الحديدية من البنك يتعذر معه حجز ما للمدين لدى الغير؛ لأن هذا الحجز يتطلب تقريراً من البنك بما في ذمته، وهو متعذر في نظام الإيداع — فيتعين على الدائنين الحجز التنفيذي.

الراجح: **العقد إيجار لا وديعة** .

مثال الخزائن الحديدية: استئجار عملاء البنك خزانة داخل البنك لوضع نقودهم ومتلكاتهم الثمينة مقابل أجر، اختلف الفقه والقضاء على أربعة آراء:

الرأي	الأسانيد والملاحظات

إيجار	البنك يمكّن العميل من الانتفاع بالخزانة مقابل أجرة (مقوم من مقومات الإيجار)؛ البنك لا يتلقى شيئاً بل يسمح بوضع ما يشاء دون التزام بردها، فلا رقابة على ما يوضع أو يُخرج؛ التزام الحفظ والحراسة لا يتناقض مع الإيجار، (منتقد: يغلب الالتزام الثانوي — التمكين — على الأصلي — الحفظ والحراسة).
وديعة	الحفظ التزام جوهري لا ثانوي، والعقد الذي يكون فيه الحفظ أساسياً وديعة؛ القول بانعدام الرقابة مردود — فالوديعة تتحقق ولو لم يتلقَّ المودع لديه الأشياء يداً بيد؛ عدم الرد لا يقدح — يكفي التزام الحفظ وتمكين المودع من الاسترداد في أي وقت؛ عدم علم البنك بالأشياء ليس شرطاً — فكثيراً ما توضع في مظروف أو صندوق مغلق فيلتزم بعدم محاولة معرفة ما بداخله؛ القول بأن الوديعة من عقود التبرعات لا قيمة له في القانون المصري — إذ يجيز أن تكون بأجر.
عقد مركب	الخزانة إيجار، والأشياء المودعة وديعة — يطبق حكم كل شق؛ وعند التعارض تغلب الوديعة؛ لأن تحقيق الأمان والمحافظة هدف أساسي من العقد.

الراجح لدينا: ونحن نميل إلى ترجيح **الوديعة** : (1) الأقرب إلى قصد المتعاقدين، (2) يحقق مصلحة العميل على الوجه الأكمل — خاصة انعقاد مسئولية البنك عن هلاك الأشياء أو ضياعها.

خامساً: الإيجار والعارية:

نص المادة 635 مدني: "العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة، أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال."

وجه الاتفاق	وجه الاختلاف
كلاهما يرد على منفعة الشيء فيخول صاحبه للغير مكنة استعماله.	وجود مقابل للانتفاع (المستأجر يدفع، المستعير لا يدفع).
كلاهما لابد فيه من الالتزام بالمحافظة على الشيء.	الإيجار معاوضة والعارية تبرع.
كلاهما من العقود الزمنية.	الأحكام الخاصة بكل منهما مختلفة.
كلاهما لا يرد على شيء قابل للاستهلاك.	—

1. **التمكين:** المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر؛ المعير يتفضل على المستعير بمنفعة الشيء.
2. **العناية:** المستأجر يبذل عناية الرجل المعتاد؛ المستعير يبذل عناية الرجل الحريص.
3. **الهلاك:** تبعة هلاك العين المؤجرة على المؤجر؛ وتبعة هلاك المعار على المستعير — حتى لو نشأ عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة، ولو كان في وسعه تحاشيه باستعمال شيء من ملكه الخاص، أو كان بيده إنقاذ شيء مملوك له والشيء المعار فاختار إنقاذ ما يملكه.

مثال ١: أعطت الحكومة لإحدى الجمعيات منفعة بعض الأراضي المملوكة لها بغرض الإفادة منها لإقامة مدرسة أو مستشفى نظير أجرة تافهة ← **عارية** رغم تسميته إيجاراً.

مثال ٢: باع شخص لآخر منزلاً واحتفظ لنفسه بحق السكنى سنة بعد البيع دون أجرة يدفعها للمشتري، رأيان:

الأول: إيجار — لأن قيمة الأجرة أخذت في الاعتبار عند تقدير الثمن فأنقص منه بمقدار مقابل السكنى،

الثاني: عارية — لأن المالك الجديد يلزم بصيانة العين والمحافظة عليها وعناية المعتاد؛ ولن يسأل عن هلاك العين؛ وللبائع بوصفه مستأجراً أن يتمسك بالامتداد القانوني لعقد الإيجار طبقاً لقانون إيجار الأماكن.

أساس التفرقة: وجود مقابل للانتفاع من عدمه، فبوجود المقابل يكون إيجاراً ولو وصف عارية؛ وبعدمه عارية ولو وصف إيجاراً، وفي المثال: للقاضي سلطة تقديرية في التكييف، يستعين بقصد المتعاقدين والظروف والثمن، فإن تبين أن الطرفين قصدا الإيجار كان إيجاراً وإلا فعارية؛ وإن تبين أن الثمن تافه أمكنه تكييفه عارية.

سادساً: الإيجار والقرض:

نص المادة 538 مدني: "القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيء مثلي في مقداره ونوعه وصفته."

التشابه والاختلاف: يوجد تشابه — خاصة إذا نص في القرض على مقابل، ويختلفان:

MNARA 01054054178

الوجه	القرض	الإيجار
الملكية	ينقل ملكية الشيء للمقترض.	لا ينقل الملكية.
الرد	المقترض ملزم برد شيء مماثل.	المستأجر غير ملزم برد الشيء.
المحل	ملكية الشيء.	المنفعة.
الاستهلاك	يرد على أشياء قابلة للاستهلاك.	لا يجوز أن يرد على قابل للاستهلاك.
الهلاك	على المقترض.	على المؤجر.

مثال الأرض الزراعية: تأجير أرض زراعية وما فيها من أشياء تستهلك، فرضان:

الأول: الأشياء المستهلكة ملحقة بالأرض ← إيجار؛ لأن الملحق عقار بالتخصيص، فيشمله عقد الإيجار الوارد على العقار الأصلي.

الثاني: غير ملحقة وغير ضرورية ← قرض لا إيجار، فيلتزم المستأجر بردها عند نهاية المدة، فإن هلكت بالاستعمال رد مثلها أو قيمتها.

الراجح: ونرى مع بعض الفقهاء: الرجوع إلى نية المتعاقدين، فإن اتجهت إلى ترك الأشياء للمستأجر كملحقات للأرض شملها الإيجار وانطبق حكم الإيجار بالتخصيص؛ وإن اتجهت إلى العكس واستعمل المستأجر الأشياء كان العقد بالنسبة لها قرضاً، يردها عند نهاية المدة، فإن هلكت رد مثلها في المقدار والنوع والصفة.

سابعاً: الإيجار والوكالة:

نص المادة 699 مدني: الوكالة "عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل."

الفرق: فالوكيل يقوم بعمل قانوني إما باسم موكله ولحسابه، وإما باسمه ولحساب موكله — وهو ما يعرف بالنيابة في التعاقد، فيكون ملزماً بنقل الحقوق التي اكتسبها للموكل.

مثال الاقتسام: اتفاق مالك عقار مع شخص على أن يؤجر العقار مقابل اقتسام الأجرة بنسبة معينة — فيثور التساؤل عن موقف المالك: مؤجر أم موكل؟

MNARA 01105405478

المعيار: نية المتعاقدين، فإن اتجهت نية كل منهما إلى أن التأجير لحساب المالك فالعقد إيجار؛ وإن لم تتضح النية فتُرجع إلى بنود العقد لمحاولة خلع وصف صحيح: فإن اتفق على أن يحصل المالك على مبلغ معين ويحصل الشخص على الباقي — إيجار صادر من المالك؛ وإن اتفق على أن يحصل كل منهما على نسبة معينة من الأجرة — وكالة.

ثامناً: الإيجار وحق الانتفاع:

تعريف حق الانتفاع: حق عيني يخول صاحبه سلطة استعمال واستغلال شيء مملوك لآخر مقابل المحافظة عليه ورده إلى صاحبه عند نهاية مدة الانتفاع، وهناك تشابه كبير — فكلاهما انتفاع بمال الغير لمدة — لكن يختلفان:

الوجه	حق الانتفاع	الإيجار
الطبيعة	حق عيني على الشيء.	حق شخصي في ذمة المؤجر.
المصدر	مصادر وأسباب متعددة.	العقد وحده.
الانتهاء	ينتهي حتماً بموت المنتفع.	ينتقل إلى الورثة، إلا إذا كانت شخصية المستأجر محل اعتبار.
المقابل	بمقابل وبدون مقابل.	لابد فيه من المقابل.

1. **إيجار لمدة حياة المستأجر:** رغم التشابه في المدة، فالإيجار لا يخول حقاً عينياً مهما طالت مدته، وحق الانتفاع يخوله طالت أم قصرت.
2. **حق الحكر:** يخول صاحبه حقاً عينياً على الشيء المحكر وينتقل إلى الورثة، فهل هو إيجار أم انتفاع؟ الرجوع إلى نية المتعاقدين: فإن اتجهت إلى إعطاء سلطة على الشيء للإفادة منه دون وساطة صاحبه — انتفاع؛ وإن ظهر أن قصدهما لم يكن استفادة الشخص من الشيء بواسطة صاحبه — إيجار، وللقاضي سلطة تقديرية في التكييف، يستعين بالملابسات والظروف والقرائن التي ترجح أحد الوصفين.

MARA 01054054178

الباب الثاني: انعقاد الإيجار:

١ أركان الإيجار (الرضا، المحل، المدة)	٢ الرضا في عقد الإيجار
٣ المحل (الشيء والأجرة)	٤ المدة في عقد الإيجار

الفصل الأول: الرضا في عقد الإيجار:

١ المبحث الأول: شروط انعقاد الرضا:

– الشرط الأول تطابق الإيجاب والقبول:

عقد الإيجار: عقد رضائي يتم بمجرد توافق الإيجاب والقبول على أن يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، لم يشترط القانون شكلاً خاصاً؛ يكفي التعبير بما يدل دلالة واضحة — صريحاً أو ضمنياً (كتابة، إشارة، موقف واضح).

التجديد الضمني: أهم تطبيقات التعبير الضمني: عقد محدد المدة تنتهي مدته ويبقى المستأجر منتفعاً بعلم المؤجر ودون اعتراض — فيعد تعبيراً ضمنياً عن رغبة الطرفين في التجديد بشروطه لمدة غير معينة.

الكتابة في قانون إيجار الأماكن: م 24 أوجبت على المؤجر كتابة العقد إذا ورد الإيجار على مكان خاضع للقانون — والكتابة **شرط إثبات لا انعقاد** ، فلا تخلفها يبطل العقد.

1. **طبيعة العقد:** فإذا قصد أحدهما التأجير والآخر الانتفاع بلا مقابل أو الشراء، لم ينعقد.
2. **الشيء المؤجر:** فإذا قصد المؤجر منزلاً وقصد المستأجر آخر، لم ينعقد.
3. **المدة:** فإذا أراد المؤجر سنتين وأراد المستأجر خمساً، لم ينعقد.

عدم لزوم الاتفاق على المدة أو الأجرة: القانون يتولى التحديد عند سكوتهما.

الرضائية ليست من النظام العام: من القواعد المكملة؛ فيجوز الاتفاق على إفراغ العقد في الشكل الرسمي، وفي هذه الحالة يصبح الشكل ركناً يبطل العقد بدونه.

MARA 01105405478

الصورية: فإذا كان صورياً جاز الطعن فيه من كل ذي مصلحة؛ إذ لا وجود قانونياً للصورية.

الوعد بالتأجير: يشترط أن يكون التراضي باتاً لا محتملاً للتفاوض أو المساومة، فإذا اتفق شخص مع مالك على أن يؤجره وحدة سكنية بعد الانتهاء من البناء، فهذا وعد بالتأجير لا يلزم إلا بتوافر شروط **م 101 مدني** .

1. **شرط واقف:** محمد يؤجر أحمد شقته إذا انتقل إلى قريته — ينفذ الإيجار متى انتقل.
2. **شرط فاسخ:** خالد المؤجر مع عمر المستأجر على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه إذا أخل بالأجرة — يزول العقد بتحققه.
3. **أجل:** مصطفى المؤجر مع يوسف المستأجر على بدء النفاذ بعد ستة أشهر — العقد موجود لكن لا ينفذ إلا بعد الأجل.

خلو الرضا من العيوب: يلزم سلامته من الغلط والتدليس والإكراه، وإلا كان العقد قابلاً للإبطال لمصلحة من وقع فيه.

1. **المزارعة:** الغلط في شخص المزارع يجعل العقد قابلاً للإبطال؛ لأن شخصيته محلاً.

الشرط الثاني وجود طرفي عقد الإيجار:

1. **القاعدة:** لا مانع من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤجرين أو مستأجرين، سواء أكان المستأجرون من الأقارب المنصوص عليهم في **م 29 من 49/1977** أم غيرهم، ما دام الأمر يحكمه انصراف نية المتعاقدين إلى ذلك عند التعاقد.
2. **الأثر القانوني:** إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نياتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد، اعتبر كل منهم مستأجراً للعين.
3. **تحرير العقد باسم واحد:** لا يغير من ذلك تحرير العقد باسم واحد دون الباقين — إذ تفرض بعض الظروف الأدبية أو الاجتماعية ذلك — وتكون علاقة الإيجار في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعاً، ويكون لهم كافة الحقوق والالتزامات دون إخلال بمبدأ نسبية أثر العقد.
4. **الإثبات:** يجوز للمستأجر وحده إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات؛ لأن الكتابة ليست شرطاً للانعقاد.

من له حق التأجير:

مالك الشيء: مالك الشيء له التصرف، فمن باب أولى التأجير، ويشترط أن يكون بالغاً رشيداً؛ فإن كان قاصراً وجب مراعاة الإجراءات القانونية، وله التأجير في أي وقت ولو في مرض موته، ويكون الإيجار صحيحاً نافذاً في مواجهة الورثة.

المحاباة في الأجرة: إذا استطاع الورثة إثبات أن الأجرة ليست أجرة المثل، اعتبر التصرف **وصية مضافة إلى ما بعد الموت** تسري عليها أحكام الوصية.

1. **حق الورثة:** يحق لهم — سواء أكان المستأجر وارثاً أم غير وارث — مطالبة المستأجر برد ما زاد من المحاباة في الأجرة على **ثلث التركة** إلا إذا أجازوا التصرف.
2. **شرط تصور المحاباة:** من النادر أن تتجاوز المحاباة الثلث، وحتى يمكن تصور ذلك يجب أن يكون الإيجار لمدة طويلة، وأن تكون العين المؤجرة هي كل التركة أو أهم شيء فيها — ما لم يستطع المستأجر إثبات أن الإيجار حقيقي بلا محاباة.

1 حكم الإيجار الصادر من البائع أو المشتري قبل التسجيل:

1. **صحة الإيجار:** الإيجار صحيح؛ لأن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل، وينفذ في مواجهة المشتري الذي لم يسجل.
2. **علة الصحة:** البيع يرتب التزامات منها نقل الملكية الذي قد يتراخى حتى ينفذه البائع ويسلم العين، فيلتزم البائع بتسليم العين للمستأجر، وليس للمشتري إلا المطالبة بفسخ البيع أو التعويض.
3. **الحكمة:** لا يجوز للبائع مطالبة المستأجر بالإخلاء قبل انتهاء المدة؛ لأنه ملزم تجاهه بضمان عدم التعرض.

تسجيل المشتري قبل المستأجر: فإن سجل المشتري قبل تسجيل المستأجر لتاريخ الإيجار، كان له طلب تسليم العين لأنه مالك؛ ومع ذلك لا يجوز للبائع مطالبة المستأجر بالإخلاء إلا بعد التنبيه في المواعيد المقررة في **م 563 مدني** .

الإيجار ثابت التاريخ وسابق للتصرف: إذا كان الإيجار ثابت التاريخ وسابقاً على التصرف الناقل للملكية، ظل المستأجر في العين حتى انتهاء الإيجار، ويلتزم البائع بتعويضه ما لم يتفق

على غير ذلك، ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد تقاضي التعويض من المؤجر أو من المشتري نيابةً عنه، أو بعد الحصول على تأمين كافٍ.

المشتري: يرى بعض الفقهاء أن الإيجار صحيح ونافذ في حقه وفي حق البائع الذي ما زال مالكاً؛ لأن المشتري له حق حيازة العين والانتفاع بها كالمستأجر من الباطن، وإن كان الإيجار الصادر منه إيجاراً من غير مالك.

2 حكم الإيجار الصادر ممن زالت ملكيته بأثر رجعي:

القاعدة والنص: زوال الملكية بأثر رجعي يعني أن المؤجر لم يكن مالكاً وقت التأجير، فلا يلتزم المالك الأصلي به؛ لأنه إيجار ملك الغير، لكن خروجاً على قاعدة الأثر الرجعي، واستناداً إلى أن الإيجار عمل من أعمال الإدارة، يبقى الإيجار نافذاً — **م 2/269 مدني** (أعمال الإدارة الصادرة من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط)، و **م 2/270** ("ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه").

1. **الأصل:** الإيجار الصادر من المالك أثناء التعليق صحيح وسارٍ، فلا يمتنع المالك تحت شرط واقف عن تنفيذه، إذ ليس له على العين حق يتعارض مع حق المستأجر.
2. **تحقق الشرط:** إذا تحقق الشرط زالت ملكية المؤجر بأثر رجعي، واعتبر من كان مالكاً تحت شرط واقف أنه كان المالك وقت الانعقاد — وهو ما كان يترتب عليه إمكانية إخراج المستأجر.
3. **الاستثناء:** لكن المشرع استثنى من الأثر الرجعي أعمال الإدارة الصادرة من الدائن، فتبقى نافذة رغم تحقق الشرط طالما صدرت بحسن نية ولم تتجاوز مدة الإيجار وقتها **ثلاث سنوات** .

التطبيق: الإيجار الصادر من المالك تحت شرط فاسخ يكون نافذاً في حق من ظهر أنه المالك إذا تحقق الشرط، ويسري على كل إيجار يصدر من مالك زالت ملكيته بأثر رجعي — كالمشتري الذي أبطل عقده أو فسخ، والموهوب له عند رجوع الواهب في الهبة، ويشترط ألا يكون الإيجار قد صدر بقصد الإضرار بمن ظهر أنه المالك، والعبرة بحسن نية المستأجر بصرف النظر عن نية المؤجر، ويستدل على حسن النية بالمدة أو بقيمة الأجرة.

الرأي الأول: الإيجار لا ينفذ إلا في حدود ثلاث سنوات — أخذت به المذكرة الإيضاحية.

الرأي الثاني: لا ينطبق نص المادة هنا؛ لأن المؤجر كان مالكاً وقت التأجير، والمادة تتكلم عمن يملك حق إدارة ملك الغير، وحجتهم **م 1/270** : "إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله إنما يكون من الوقت الذي تحقق فيه الشرط."

السبب: حفظاً لحق المستأجر الذي تعامل مع مالك حقيقي بحسن نية — حماية تقتضيها الثقة المشروعة لاستقرار المعاملات.

حق المالك الأصلي: حق من آلت إليه الملكية بأثر رجعي — والمنطق القانوني يقضي بأن المالك الأصلي أولى بالحماية.

رأينا (التوفيق): حماية المالك الأصلي تقتضي تقييد الإيجار بالمدة المنصوص عليها؛ وحماية المستأجر تقتضي نفاذ الإيجار في مواجهة من آلت إليه الملكية، بشرط ثبات تاريخه.

3 حكم الإيجار الصادر ممن اتُّخذت ضده إجراءات نزع الملكية:

نص م 408 مرافعات: **"مع مراعاة القوانين الأخرى في شأن إيجار العقارات تنفذ عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه في حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة 417 ومن حكم بإيقاع البيع عليه... أما عقود الإيجار غير الثابتة قبل التنبيه فلا تنفذ في حق من ذكروا، إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة."**

1. **الفرض الأول – ثابت التاريخ قبل التسجيل:** صحيح ونافذ في مواجهة الحاجزين والدائنين ومن حكم بإيقاع البيع عليه، أياً كانت المدة أو الأجرة، ويشترط عدم تواطؤ المؤجر والمستأجر.
2. **الفرض الثاني – غير ثابت التاريخ:** لا ينفذ في حق من ذكروا إلا إذا كان من **أعمال الإدارة الحسنة** — بأن تكون الأجرة أجرة المثل أو أقل بدرجة جرى العرف على التسامح فيها، والمدة لا تتجاوز المألوف.

4 حكم الإيجار الصادر من صاحب حق الانتفاع:

القاعدة: حق الانتفاع يخول صاحبه استعمال شيء مملوك للغير واستغلاله مع المحافظة عليه ورده عند نهاية المدة، فللمنتفع أن ينتفع بنفسه أو يؤجر للغير.

نص م 560 مدني: "الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة، على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة."

1. **المدة المباحة:** لو كان الأجل خمس سنوات، جاز للمنتفع التأجير لأية مدة بشرط ألا يتجاوز الإيجار مدة حق الانتفاع.
2. **الوفاة قبل انقضاء الإيجار:** فإذا مات المنتفع قبل انقضاء الإيجار، انقضى الإيجار تبعاً لانقضاء حق الانتفاع (المنقضي بموت المنتفع)، لكن المشرع أجاز استمرار الإيجار إذا أجازه مالك الرقبة.
3. **الإجازة:** الصادرة من الشخص الذي تقرر الإبطال لمصلحته، فيصبح العقد صحيحاً ويستمر بين المستأجر ومالك الرقبة حتى انتهاء مدته.
4. **عدم الإجازة:** إذا لم يجز، انتهى الإيجار من وقت وفاة المنتفع مع مراعاة مواعيد التنبيه بالإخلاء.

المذكرة الإيضاحية: "من الحقوق العينية التي تؤجر حق الانتفاع، وينقضي الإيجار بانقضاء هذا الحق كما ينقضي بهلاك العين المؤجرة، إلا أن مالك الرقبة قد يجيز الإيجار عن المدة التي تلي انقضاء حق المنتفع، فإذا لم يجز أمكنه أن يطلب من المستأجر الإخلاء بعد إعطائه الميعاد المنصوص عليه في المادة 761 أو الميعاد المناسب لنقل المحصول."

حالة خاصة: إذا أجر المنتفع حقه إلى مالك الرقبة ثم مات قبل انقضاء الإيجار، يستمر الإيجار — باعتبار المستأجر مالكاً لا مستأجراً؛ لأن الإيجار ينقضي باتحاد الذمة، وقد اجتمعت في مالك الرقبة صفتا المستأجر والمؤجر.

5 حكم الإيجار الصادر من الدائن المرتهن رهناً حيازياً:

القاعدة: الرهن الحيازي عقد يخول الدائن المرتهن حقاً عينياً تبعياً ضماناً لدين، ويخوله سلطة حبس الشيء حتى يستوفي حقه، ويترتب عليه أن للمرتهن استثمار المال المرهون بما يحقق مصلحته، ويخصم من المبلغ المضمون ما حصل عليه من الاستغلال وما استفاد من استعمال الشيء، فيستطيع المرتهن تأجير العين المرهونة.

1. **الرأي الأول:** نائب عن الراهن.

2 **الرأي الثاني:** وكيل عن الراهن.

3 **الرأي الثالث:** بموجب حقه الأصيل في استغلال العين المرهونة، (أخذت به المذكرة الإيضاحية: "الحق في أخذ الغلة وخصمها هو عنصر من عناصر الحق، فالدائن المرتهن يستولي على الغلة أصيلاً عن نفسه لا نائباً عن الراهن،")

✅ **نرجح الثالث:** لأن استثمار الشيء لا ينصرف إلى مصلحة المدين فحسب بل إلى مصلحة الدائن أيضاً، ووجود ارتباط وثيق بين سلطة الإدارة المخولة للمرتهن وحقه في الانتفاع، فيجوز له التأجير لمدة لا تتجاوز **ثلاث سنوات** طالما كان الرهن قائماً، فإن كانت مدة الرهن أقل، كانت سلطته مقيدة بها.

❌ **الرأي الأول:** الإيجار ينقضي بانقضاء مدة الرهن — كما لو أجر لسنتين والرهن لسنة.

✅ **الرأي الثاني:** لا ينقضي؛ لأن امتداد الإيجار لحماية المستأجر، والتأجير تم وفقاً لسلطة الإدارة، ولا مجال للخروج على **م 559** وقد انقضى الرهن.

✅ **ونرى:** أنه لا يمكن القول بالامتداد على إطلاقه، إعمالاً للارتباط بين حق المرتهن وسلطته في الإدارة، ومع ذلك يمكن القول بالامتداد بشرط **حسن نية المستأجر** — أي لم يكن يعلم بأن مدة الرهن سنتان وقد أجر ثلاثاً — فيمتد رغم انقضاء الرهن، حمايةً للأوضاع الظاهرة.

⚖️ **تأجير المرتهن إلى المدين الراهن:** من حقه، إلا أن هذا الوضع يخل بوظيفة انتقال الحيازة في نفاذ الرهن في حق الغير.

📖 **نص م 1100:** "إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن، كل هذا دون إخلال بحقوق الغير،"

✅ **التطبيق:** الإيجار الصادر من المرتهن إلى المدين الراهن صحيح دون أن يبطل الرهن، بل يبقى قائماً طالما يستطيع المرتهن إثبات أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن.

🏠 **إن كان المرهون منقولاً:** فرجوعه إلى الراهن ولو بطريق الإيجار يجعله غير سارٍ في حق الغير؛ لأن بقاء الحيازة للدائن شرط أساسي للنفاذ.

MARA 01105405478

إن كان عقاراً: أجازت م 1115 الإيجار وجعلت سريانه يدور مع القيد وجوداً وعدماً: "يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير، فإذا اتفق على الإيجار في عقد الرهن وجب ذكر ذلك في القيد ذاته، أما إذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به في هامش القيد إلا أن هذا التأشير لا يكون ضرورياً إذا جدد الإيجار تجديداً ضمنياً." (والمرتهن رهناً رسمياً لا يجوز له إيجار العقار المرهون؛ لأنه ليس له حق الانتفاع به ولا حيازته.)

6 حكم الإيجار الصادر من المالك مع المنازعة في صفة التأجير:

بإجماع الشركاء: لا خلاف في صحة ونفاذ إيجار المال الشائع كله أو جزء منه إلى أحد منهم أو إلى الغير طالما وافق جميع الشركاء، بصرف النظر عن نتيجة القسمة، مع التسليم بمضمون الأثر الرجعي للقسمة — أن من اختص بالشيء يكون مالكاً له منذ بدء الشيوع، فيكون قد أجر ما يملك؛ لأن شركاءه رضوا بالتأجير منذ البداية.

القاعدة عن أغلبية الشركاء: الإيجار وفقاً للقواعد العامة عمل من أعمال الإدارة، أما في ظل القوانين الخاصة فتصرف.

1. **التكييف ← إدارة:** م 828 — صحيح ونافذ في مواجهة الأقلية، ما لم يقصد الإضرار بحقوقها وإلا كان لها اللجوء للقضاء للإبطال.
2. **التكييف ← تصرف:** م 1/829 — لمالكي ثلاثة أرباع المال الشائع تأجير المال كله أو جزء منه إذا استندوا إلى أسباب قوية، على أن يعلنوا قرارهم إلى الأقلية، ولها الاعتراض في خلال شهرين من الإعلان باللجوء إلى القضاء، وللمحكمة الموازنة بين المصالح: فإن تعارضت أمكنها إلغاء الإيجار أو إقراره مع إلزام الأغلبية بضمانات للأقلية عند التنفيذ، وإن رأت الإيجار ضاراً بمصلحة الأقلية حكمت بإلغائه.

قبل القسمة (الشريك منفرداً): الإيجار صحيح بين طرفيه، لكنه غير نافذ في مواجهة باقي الشركاء، فللشريك غير المؤجر طلب إبطال العقد بحجة عدم نفاذه، وللمستأجر طلب الفسخ مع التعويض إن كان له وجه، وله طلب الإبطال للغلط الذي وقع فيه إذا كان يعتقد وقت الاتفاق أن المؤجر مالك ولا ينازعه أحد.

بعد القسمة والنص: إذا وقع الجزء المؤجر في نصيب الشريك المؤجر تأكد الإيجار نهائياً، وأصبح كل ملزماً بالوفاء بالتزاماته، وإن لم يقع، تعذر تسليم العين، فهل ينتقل الإيجار إلى جزء آخر

آلت إلى المؤجر؟ **م 2/826** : "إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع، ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف إليه بطريق القسمة، وللمتصرف إليه، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة، الحق في إبطال التصرف،"

✗ **الرأي الأول:** لا ينتقل؛ فالمقصود بالتصرف هو الناقل للملكية لا الإيجار.

✓ **الرأي الراجح:** ينتقل إعمالاً للنص وتطبيقاً للحلول العيني؛ فالمقصود مطلق العقد.

⚠ **في حال تعذرت القسمة:** يباع المال بالمزاد، فإن رسا على الشريك المؤجر، استقر الإيجار نهائياً وتعين عليه تنفيذ التزاماته، وإن رسا على شريك آخر أو أجنبي، نفذ الإيجار في مواجهته بشرط أن يكون ثابت التاريخ وسابقاً على التصرف الناقل للملكية، إعمالاً **لم 604 مدني** .

7 حكم إيجار ملك الغير:

ℹ **الصورتان:** أن يكون المؤجر بلا حق على المال ولا حق في إدارته؛ أو أن يظهر بصورة المالك ثم يتضح غير ذلك.

✗ **الرأي الأول (فرنسي):** قابل للإبطال، قياساً على بيع ملك الغير؛ فالعلة واحدة.

✓ **الرأي الثاني:** صحيح لا قابل للإبطال، بل يتوقف على إجازة المالك الحقيقي؛ لأن القابلية للإبطال قاصرة على أحد طرفي العقد، والمالك الحقيقي من الغير، ولا يقاس على بيع ملك الغير؛ لأنه وردت فيه نصوص خاصة.

1 **المؤجر والمالك الحقيقي:** لا توجد علاقة؛ فالمالك ليس طرفاً ولا خلفاً، فللمالك الرجوع على المؤجر بالتعويض عما أصابه من ضرر ترتب على إيجار ملكه بدون إذنه — عملاً غير مشروع يستوجب قواعد المسؤولية التقصيرية.

ANARA 01105405478

2 **المؤجر والمستأجر – سيئا النية:** للمستأجر طلب الفسخ لأن المؤجر لا يستطيع تنفيذ التزامه، وهل له التعويض؟

- **الأول:** لا تعويض؛ لأنه يعلم أن العين غير مملوكة للمؤجر ومع ذلك أقدم.
- **الثاني:** تعويض؛ لأن المؤجر كان سيئ النية.
- **الثالث:** تعويض بصرف النظر عن حسن أو سوء نية المؤجر؛ لأن سوء نية المستأجر لا يؤثر على مقدار الضرر، وسوء نية المؤجر لا ينفي الخطأ في جانبه.

3 **المؤجر والمستأجر – حسنا النية:** الإيجار صحيح ونافذ بين طرفيه وقابل للإبطال لمصلحة المستأجر؛ لأنه وقع في غلط جوهري دفعه للتعاقد، ولا يقاس على بيع ملك الغير — مع وجود العلة — قياس مع الفارق؛ لأن الإيجار يرتب التزامات شخصية والبيع التزامات عينية، والقول بالبطلان محل نظر؛ لأن الاستحالة نسبية لا مطلقة (فالمؤجر قد يتملك العين فينفذ التزامه)، ولأن بيع ملك الغير قابل للإبطال بنص — وهو استثناء لا يقاس عليه، وللمستأجر المطالبة بتعويض.

4 **المؤجر والمستأجر – المستأجر سيئ النية وحده:** له طلب الفسخ مع التعويض (عند بعض الفقه)، ولا يكون له طلب الإبطال.

5 **المستأجر والمالك الحقيقي:** المالك من الغير، فالإيجار غير نافذ في مواجهته، فيحق له مطالبة المستأجر بالإخلاء ورد العين إن تسلمها، وليس للمؤجر مطالبة المستأجر برد ما قبضه من ثمار إلا إذا كان المستأجر سيئ النية؛ فإن كان حسن النية فلا، وللمالك التصرف في العين بأي صورة، ولا يتمسك المستأجر في مواجهته بـ **م 604** ؛ لأن النص يفترض الإجارة من مالك حقيقي، ولو أجر المالك لمستأجر آخر، فضل هذا على المستأجر من غير مالك، ولا محل لتطبيق **م 1/573** : "إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش، فإذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العقار المؤجر أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره، فإنه هو الذي يفضل."

الصورة الثانية – الوارث الظاهر (التعريف): كل من ظهر أمام الناس بمظهر الوارث وتُعومل على هذا الأساس ثم يتضح غير ذلك.

القاعدة العامة: يطبق عليه أحكام إيجار ملك الغير، فيكون غير نافذ في مواجهة الوارث الحقيقي.

الاستثناء: المسلم به في فرنسا ومصر أنه ينفذ إذا كان المستأجر حسن النية، حمايةً للأوضاع الظاهرة واستقراراً للمعاملات.

الأساس الأول: القياس على نفاذ الإيجار من المالك تحت شرط فاسخ.

الأساس الثاني: قاعدة "الغلط الشائع يولد حقاً" للأسباب الآتية:

1. **الحماية:** دور القانون حماية من يتعاملون بحسن نية؛ فمن تعامل مع شخص على أنه الوارث اعتماداً على الاعتقاد الشائع، كان معذوراً.
2. **المشرع:** أخذ بهذا الحل في الوفاء بحسن نية — **م 333** : "إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء، أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته."
3. **الاستقرار:** حماية الأوضاع الظاهرة واستقرار المعاملات تقتضي النفاذ.

نرجح الأخير (الغلط الشائع): للأسباب الثلاثة السابقة.

1. **حسن نية المستأجر:** ألا يعلم وقت الإبرام أن العين غير مملوكة، ولا يتطلب حسن نية المؤجر.
2. **من أعمال الإدارة:** فلا يعمل **م 559** ؛ لأن الوارث الظاهر لا يملك حق الإدارة، ونفاذ الإيجار كان بسبب حسن نية المستأجر.
3. **تاريخ ثابت:** سابق على ظهور الوارث الحقيقي؛ لأن هذا من الغير الذين لا يحتج عليهم بالتصرف إلا إذا كان ثابت التاريخ.

2 المبحث الثاني: شروط صحة الرضا:

– الشرط الثاني الأهلية والولاية:

الأهلية: هي صلاحية الشخص للقيام بالأعمال القانونية والقضائية، فلو توافرت لحظة الإبرام نشأ العقد صحيحاً واستمر حتى نهاية مدته، ولا أثر لما يحدث لها أثناء سريانه.

MARA 01105405478

1 أهلية المؤجر:

الرأي الغالب: الإيجار عمل من أعمال الإدارة، فيكفي أهلية الإدارة، فمن بلغ الرشد غير مصاب بعارض كان من حقه تأجير أمواله أياً كانت المدة ولو زادت على **تسع سنوات** — مع وجوب التسجيل لنفاذ الإيجار في مواجهة الغير عند تجاوز هذه المدة.

1. **العديمون:** الصبي غير المميز (دون السابعة)، والمجنون، والمعتوه: لا يجوز لهم التأجير وإلا كان باطلاً باطلاً مطلقاً.
2. **الجنون والعته:** إذا كان سبب انعدام التمييز الجنون أو العته، فلا بطلان إلا إذا صدر بعد تسجيل قرار الحجر؛ وقبله لا يبطل إلا إذا كانت الحالة شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها.
3. **ناقص الأهلية:** إذا لم يبلغ الرشد أو بلغ وحُجر عليه لسفه أو غفلة، كان ناقص الأهلية، فإيجاره قابل للإبطال لمصلحته.

الصبي المميز (م 112 مدني): "إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها، أو تسلمها بحكم القانون، كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون،"

الحالة الأولى – 16 سنة (م 63 الولاية): "إذا بلغ الصبي السادسة عشرة من عمره وكان يكسب من عمله أصبح أهلاً للتصرف بشرط ألا يتعدى التزامه حدود المال الذي يكسبه من مهنته أو صناعته،" فمن بلغ 16 واكتسب شيئاً صالحاً للتأجير كان من حقه تأجيره لأي مدة.

1. **م 54 الولاية:** "للولي أن يأذن للقاصر الذي بلغ سن الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، ويكون ذلك بإشهاد لدى الموثق، وله أن يسحب هذا الإذن أو يحد منه بإشهاد آخر، مع مراعاة حكم المادة 1027 من قانون المرافعات،"
2. **م 55 الولاية:** "يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضي سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض،"

ALARA 01054054178

3 **م 56 الولاية:** "للقاصر المأذون أن يباشر أعمال الإدارة... ولكن لا يجوز له أن يؤجر الأراضي الزراعية والمباني لمدة تزيد على سنة إلا بإذن خاص من المحكمة أو من الوصي فيما يملكه من ذلك.."

المستخلص: القاصر الذي بلغ 18 له حق إدارة الأموال المسلمة إليه، وتسلمها يخوله إدارتها لا التصرف فيها، والإيجار من أعمال الإدارة، ولا يقيد حقه إلا بقيد: ألا يؤجر المباني أو الأراضي الزراعية المسلمة إليه لأكثر من سنة، أو ثلاث بإذن الولي، أو أكثر من ثلاث بإذن المحكمة، وتسري الأحكام على السفيه وذي الغفلة إذا أذن لهما في تسلم أموالهما.

ملاحظة قانونية: إذا تم التأجير خلافاً للمدد، جاز للقاصر بعد الرشد وللمحجور عليه بعد فك الحجر وللغائب بعد عودته أن ينقص العقد إلى المدة القانونية، فالعقد صحيح نافذ ما لم يطالب بالإنقاص من تقرر الإبطال لمصلحته، ولا يجوز للولي أو الوصي أو الوكيل عن الغائب أو القيم التمسك بالبطلان — بل يتمسك به من تقرر الإبطال لمصلحته.

2 أهلية المستأجر:

1 **الرأي الأول (تصرف):** يلزم أهلية التصرف؛ لأن المستأجر يقتطع جزءاً من ثروته نقداً أو عيناً أو جهداً — إخراج للمال من الذمة المالية، فهو تصرف بعوض كالشراء.

2 **الرأي الثاني (إدارة):** معيار التفرقة: الأصل أم الثمار، وغالباً يدفع المستأجر الأجرة من الثمار، (منتقد: دفع الأجرة إخراج من الذمة بصرف النظر عن مصدر المال، وقد لا يكون له دخل غير أصل رأس ماله،)

3 **الرأي الثالث (تفصيل):** إدارة: إن استأجر لإدارة شؤونه المألوفة (كاستئجار منزل للسكن)، أو تابعاً لضرورات الإدارة (كاستئجار مكان لمهنة)، وتصرف إذا كان مستقلاً (كاستئجار أرض بقصد زراعتها).

ونؤيد الغالبية: الاستئجار تصرف بصرف النظر عن مصدر الأجرة، فيلزم أهلية التصرف في الأجرة — وهي تثبت للبالغ الرشيد الذي لم يحكم باستمرار الولاية أو الوصاية ولم يُحجر عليه بعد الرشد، فيكون إيجار الصبي غير المميز باطلاً باطلاً مطلقاً، والمميز قابلاً للإبطال لمصلحته متى أذنت المحكمة الحسبية له بإدارة أمواله.

3 الولاية في التأجير والاستئجار:

تعريف الولاية: صلاحية الشخص للقيام بالأعمال القانونية والقضائية المتعلقة بغيره ولحسابه، تستند إلى نصوص، وتثبت للولي، والوصي، والقيم، ووكيل الغائب، وسنديك التفليسة، وناظر الوقف.

نص م 2 الولاية (الولي): "لا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذه الحقوق فيما يتعلق بماله هو."

الأثر (الولي): فللولي تأجير مال القاصر لأية مدة ولو زادت على ثلاث سنوات، ولا يخضع لـ م 559 — لأنه لا يملك سلطة الإدارة فحسب بل التصرف.

م 10 الولاية (الجد): "لا يجوز للولي بغير إذن المحكمة تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد سن الرشد بسنة." غير أن الجد يتقيد بثلاث سنوات؛ لأنه لا يملك سلطة التصرف إلا بإذن المحكمة.

الوصي والقيم: لا يملكان إلا سلطة الإدارة، فتطبق عليهما م 559 : لا تأجير لأكثر من ثلاث سنوات إلا بإذن المحكمة، ولا تأجير عقار القاصر لأكثر من ثلاث في الأراضي الزراعية ولا أكثر من سنة في المباني.

1. **م 39/7:** إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأرض الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني.
2. **م 39/8:** إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة.
3. **م 39/15:** إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجه ولأحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه.

المستخلص: لا تأجير لأكثر من ثلاث سنوات إلا بإذن المحكمة، ولا تأجير لأكثر من ثلاث في الأراضي الزراعية، ولا تأجير لأكثر من سنة بعد الرشد أو رفع الحجر، وعلى فرض المخالفة، يتعين إنقاص الإيجار إلى المدة القانونية، ولا تأجير لأنفسهما أو لزوجهما أو لأحد أقاربهما حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون نائباً عنه — أياً كانت طبيعة المال أو مدة التأجير — إلا بإذن المحكمة وتعيين وصي خاص يتعاقد معه.

الأثر القانوني: فإذا لم يتوافر الشرطان كان الإيجار غير نافذ في مواجهة المشمول بالوصاية أو القوامة، ووجب على المحكمة تعيين وصي أو قيم ليسترد المال من تحت يد المستأجر، وما يسري عليهما يسري على الوكيل عن الغائب.

سنديك التفليسة: نائب قانوني عن التاجر المفلس ورفعت يده عن الإدارة، ونائب عن جماعة الدائنين، ويشترط لنفاذ إيجاره في مواجهة من يرسو عليه المزاد أن يكون هذا قد أُخطر بذلك عند التقدم للمزاد، فإن كان لا يعلم، كان الإيجار غير نافذ في حقه، ولا يبقى للمستأجر إلا الرجوع على السنديك المهمل.

ناظر الوقف: من سلطته تأجير الأموال الموقوفة، ويشترط ألا تزيد المدة على ثلاث سنوات إذا تعدد المستحقون، أما إذا كان الناظر هو المستحق، جاز له الإيجار لمدة تتجاوز الحد.

ولاية الاستئجار القانونية: سلطة الشخص في الاستئجار نيابةً عن غيره، وأصحابها: الولي (الأب، الجد الصحيح)، والوصي، والقيم، والوكيل عن الغائب.

الأب: لأنه يملك سلطة التصرف فمن باب أولى الإدارة — يستأجر للقاصر سواء أكان الإيجار إدارة أم تصرفاً.

الجد والوصي والقيم والوكيل: لا يستأجرون لحساب من يمثلونهم؛ لأنهم لا يملكون إلا الإدارة، والاستئجار تصرف، فيحتاجون إذن المحكمة.

الشرط الثاني سلامة الإرادة من العيوب:

القاعدة: الرضا يخضع للقواعد العامة، ولكي ينتج أثره لابد أن يكون سليماً من العيوب: الغلط، التدليس، الإكراه، الغبن (الاستغلال)، فإذا شابه عيب أصبح العقد قابلاً للإبطال لمصلحة من شاب رضاه العيب، ونكتفي بالغلط.

الغلط: وهم يقع فيه المتعاقد ويدفعه إلى قبول العقد، وقد يكون في شخص المستأجر أو في الأجرة، ونظمته المواد 120-124 مدني.

الغلط في شخص المستأجر: الأصل ألا يؤثر في صحة العقد إلا إذا كانت الشخصية محل اعتبار — لأن الإيجار من عقود المعاوضة، ويستوي لدى المؤجر أن يؤجر لشخص أو لآخر، لكن في

المزارعة، الغلط في شخصية المزارع — إذا كانت محل اعتبار — يجعل العقد قابلاً للإبطال؛ لأن المزارعة تقوم على فكرة الشركة في المحصول.

1. **م 1/121:** "يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط."
2. **م 2/121 (أ):** "إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين، أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية."
3. **م 2/121 (ب):** "إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد."

الغلط في صفة جوهرية: الأصل عدم التأثير، ولكن إذا كانت الصفة أو المهنة هي الدافع إلى التعاقد، أصبح العقد قابلاً للإبطال — كمن يؤجر شقة في منزل تسكنه عائلات لشخص اعتقد واهماً أنه متزوج فإذا هو أعزب.

تطبيق قضائي: عقد الإيجار مع أعزب لا يكون قابلاً للإبطال إلا إذا تبين من الظروف أن المؤجر ما كان ليتعاقد معه لو علم بحقيقته — فقد يكون ذا سمعة طيبة ومركز لائق أو على وشك الزواج، فيصعب القول بأن الغلط جوهري.

محكمة نانت الفرنسية: قضت بأن السمعة الأدبية للمستأجر يمكن أن تكون سبباً للإبطال؛ فالمستأجرة العاهرة يكون عقد إيجارها قابلاً للإبطال ولو لم تمارس حرفتها في المكان المؤجر، إذا كانت السمعة محل اعتبار، فإذا مارستها في العين، كان للمؤجر طلب الإبطال أو الفسخ لاستعمال العين في غير ما أعدت له.

الغلط في اليسار أو عدد الأسرة: لا يجوز للمؤجر طلب الإبطال إلا إذا اقترن بظرف آخر — كاستعمال طرق احتيالية لإيقاع المؤجر في غلط، فهذا تدليس يجيز الإبطال.

الغلط في العين المؤجرة: إذا انصب على العين، كان العقد باطلاً لعدم تطابق الإرادتين على المحل، وإذا كان في صفة من صفاتها، كان قابلاً للإبطال — كأن يؤجر أرضاً للزراعة فيتبين أنها أرض بناء.

المحل هنا: هو الشيء المؤجر، والأجرة، والمدة.

1 المبحث الأول: الشيء المؤجر

المقصود: الحق المقرر للشخص على شيء — مملوكاً للمؤجر ملكية تامة أو ناقصة، ويستوي أن يكون حقاً عينياً أو شخصياً، فالإيجار يرد على الحق المتفرع عن الملكية (حق الانتفاع) والحق الشخصي (كأن يؤجر المستأجر حقه إلى مستأجر من الباطن).

مادي:

- **عقار:** أرض زراعية للزراعة، مباني للسكنى، أرض فضاء لملعب أو معرض،
- **منقول:** آلات زراعة وصناعة، وسائل نقل، أماكن مفروشة، آلات موسيقية، ملابس، ماشية، أفلام سينمائية، وقد نظم المشرع إيجار المنقولات في **المواد 622-623 مدني** .

معنوي: حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية والتجارية (حق المؤلف، الاسم التجاري) — يجوز تأجيرها إذا خدمت الاستغلال الصناعي والتجاري، وبشرط ألا يترتب عليها منافسة غير مشروعة، ويرى بعض الفقهاء أن للمؤلف تأجير مؤلفه لشخص لمدة معينة يحق له خلالها الانتفاع به — ببيع طبعة من طبعاته، ويكيف العقد إيجاراً طالما اتجهت نية الطرفين إلى إعطاء المستأجر حقاً شخصياً.

شروط الشيء المؤجر:

1. **موجود أو قابل للوجود:** إن لم يكن موجوداً وقت العقد أو ممكناً في المستقبل، بطل لانعدام المحل، مثال: تأجير منزل لم يُبنَ أصلاً، أو انهدم قبل العقد، أما إذا هلك بعد العقد: فإن كان كلياً فُسخ لاستحالة تنفيذ التزام المؤجر بالتسليم؛ وإن كان جزئياً كان للمستأجر طلب إنقاص الأجرة بقدر ما هلك، إلا إذا تبين أنه ما كان ليتعاقد إلا بسببه فيبطل العقد كله — **م 143** : "إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للأبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير هذا الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال فيبطل العقد كله."

2 **معين أو قابل للتعيين:** طريقة التعيين بحسب الطبيعة: المعين بالذات (كالأرض الزراعية) بذكر المساحة والحدود واسم الحوض والبلدة؛ السكن بذكر اسم الشارع ورقم العقار واسم الحي أو المنطقة، المعين بالنوع (كالسيارة) بذكر رقمها والموديل وسنة الصنع.

3 **مما يصح التعامل فيه:** إن خرج عن دائرة التعامل وقع العقد باطلاً، والخروج إما بطبيعته (الشمس، الهواء، الماء — لاستحالة الاستئثار بها فلا تملك ولا تؤجر)، أو بنص القانون (الأملاك العامة — مخصصة للمنفعة العامة، وما تسمح به الدولة لبعض الأشخاص من استغلالها ترخيص لا إيجار؛ لأن العلاقة الإيجارية تحكمها قواعد القانون المدني وقانون إيجار الأماكن بحماية المستأجر وحق البقاء، وتتعارض مع سلطة الدولة في الإنهاء في أي وقت للمصلحة العامة).

4 **غير قابل للاستهلاك:** م 1/84 : "الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له في استهلاكها، أو إنفاقها،" م 2/84 : "فيعتبر قابلاً للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع،" الحكمة: المستأجر ملزم برد العين، ولا يمكنه ذلك إذا هلكت بالاستعمال، **الاستثناء:** إذا لم يكن من شأن الشيء أن يهلك بالانتفاع — كاستئجار حبوب ونقود لوضعها في معرض ثم ردها، ويرى بعض الفقهاء جواز تأجيرها في حالتين: تخصيصها لغرض غير الاستهلاك (كالعرض)؛ أو تأجيرها تبعاً لا استقلالاً (كأن يؤجر صاحب مصنع مصنعه بما فيه الآلات على أن يعوض المستأجر ما يبلى منها، أو صاحب أرض زراعية أرضه وما يلحقها من روافع للري)، ويجب على المستأجر في هذه الحالة رد مثلها أو قيمتها عند نهاية الإيجار إن استهلكت.

2 المبحث الثاني: الأجرة:

الماهية (م 558): ذكرت "أجر معلوم"، وحاول الفقهاء تعريفها: "المال الذي يلتزم المستأجر بإعطائه للمؤجر مقابل الانتفاع"، أو "ما على المستأجر أداؤه مقابل انتفاعه".

الراجح عندنا: الأجرة الأداء الواجب على المستأجر للمؤجر مقابل انتفاعه بالعين، والتعريف الأخير أرجح؛ لأنه ليس بلازم أن تكون الأجرة مالاً — بل يمكن أن تكون عملاً أو امتناعاً عن عمل أو التزاماً بإعطاء شيء ذي قيمة مالية.

النوعية (م 561): "يجوز أن تكون الأجرة نقوداً، كما يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى،"

نقوداً: (الغالب).

امتناعاً عن عمل: التزاماً بالامتناع عن عمل لصالح المؤجر (كالامتناع عن فتح محل).

عملاً: كالترافع عنه إن كان المستأجر محامياً.

شيء معين: إعطاء شيء معين بذاته أو معين بنوعه.

طبيعتها: والأجرة محل التزام المستأجر من أركان العقد، تميزه عن العارية، ومع أنها ركن، فليس بالضرورة الاتفاق على تحديدها — بل لو سكت الطرفان صح العقد وتكفل القانون بها.

شروط الأجرة:

1. **ممكنة الوفاء:** ممكنة الوجود أو موجودة بالفعل — محل اتفاق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، فإن كانت نقوداً أو مثلياً آخر فهي ممكنة، وإن كانت معيناً بالذات وجب أن يكون موجوداً أو قابلاً للوجود (كنتاج الماشية قبل ولادتها)، وإن كانت عملاً وجب ألا يكون مستحيلاً استحالة مطلقة، فإن كانت غير موجودة ولا قابلة للوجود، لم يكن العقد إيجاراً بل عارية أو حق انتفاع بلا مقابل.

2. **معينة أو قابلة للتعيين:** **الفقه القانوني:** لا يشترط العلم بالأجرة؛ فلو عقد الإيجار بلا ذكر أجرة لم يكن باطلاً بل صحيحاً، ويتدخل القاضي بناءً على طلب أحد الطرفين لتحديد الأجرة وفقاً للقانون أو أجرة المثل. **الفقه الإسلامي:** يشترط العلم بالأجرة وإلا كانت الإجارة فاسدة للجهالة — لأن الجهالة في بدل المعقود عليه تؤدي إلى المنازعة في عقود المعاوضات، **م 464 مجلة الأحكام العدلية** : "بدل الأجرة يكون معلوماً بتعيين مقداره إن كان نقداً كثمن البيع، وإن لم يكن نقداً فيلزم بيان مقدار بدل الإجارة ووصفه إن كان من العروض أو المكيلات أو الموزونات أو العدديات المتقاربة."

3. **مشروعة:** غير مخالفة للقانون العام والآداب، مثال: لا يجوز تأجير شقة في مقابل أقراص مخدرة، ولا أن تكون الأجرة معاشرة غير مشروعة مع من تسكن، فإذا كانت كمية من المخدرات كان العقد باطلاً باطلاً مطلقاً لعدم مشروعية المحل.

4. **جدية:** حقيقية لا صورية، تنصرف إليها إرادة المتعاقدين، فإن ذكرت ونية الطرفين عدم التزام المستأجر بها، كانت صورية وتحول من إيجار إلى عارية.

1. **الصورية:** إذا سمى المتعاقدان أجرة لا يقصدان أن يدفعها المستأجر، كان العقد باطلاً باعتباره إيجاراً.

2. **التوافه:** إذا سميا أجرة تكاد تكون في حكم العدم — كتأجير أرض لجمعية خيرية بأجرة تافهة — فالعقد في حقيقته عارية أو هبة حق انتفاع في صورة إيجار.

3. **البخس:** ليس بالضرورة أن تكون الأجرة متناسبة مع المنفعة، فيمكن أن تكون بخسة ويصح الإيجار غير قابل للطعن بالغبن إلا إذا استغل أحد المتعاقدين طيشاً بيناً أو هوى جامحاً في الآخر، ولا يجوز للمؤجر رفع دعوى تكملة الأجرة إلا في إيجار الوقف.

مقارنة بالبيع والتوافه المطلق: يجوز للبائع رفع دعوى تكملة الثمن إذا وقع غبن يزيد على الخمس (م 425 مدني) بشرط ألا يكون البيع بالمزاد العلني، أما التوافه المطلق: إذا كانت الأجرة تافهة بحيث لا تتناسب البتة مع قيمة المنفعة، أصبح الإيجار في حكم العدم وتحول العقد إلى عارية، ويتساوى هذا مع الاتفاق على عدم دفع أجرة مقابل الانتفاع — فيكون العقد باطلاً لفقد ركن من أركانه.

تحديد الأجرة (م 562): "إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة، وجب اعتبار أجرة المثل." فالتقدير إما باتفاق، وإما بقاعدة مكملة، ونتناول: التحديد بواسطة المتعاقدين، وبواسطة القانون.

بواسطة المتعاقدين:

الصور: غالباً يحدد المؤجر والمستأجر الأجرة عند الإبرام.

1. **تحديد المقدار:** يختلف التحديد بحسب ما إذا كانت نقوداً أو مثلياً آخر أو عملاً أو امتناعاً أو إعطاء شيء.

2. **تحديد الأسس:** قد يكتفيان بتحديد الأسس (جزء محدد من المحصول، أو نسبة معينة من الغلة كالثلث أو الربع أو النصف في إيجار الأرض الزراعية)، ويجوز الاتفاق على أجرة تختلف باختلاف الظروف، كأجرة معينة لمحصول وأخرى لمحصول آخر.

3. **تفويض الغير:** يجوز تفويض شخص آخر في التحديد؛ فإن امتنع أو عجز، لم ينعقد العقد لانعدام ركن الأجرة، ولا تتدخل المحكمة إلا إذا اتضح من إرادة الطرفين أنهما قصدا بتفويض الغير الأخذ بأجرة المثل.

MARA 01105405478

الرأي الأول: ترك التحديد للمؤجر وحده — يجوز؛ لعدم ما يمنع من تعليق وجود الالتزام على شرط إرادي محض للدائن.

الرأي الثاني (الراجح عندنا): لا يجوز؛ حتى لا يتعسف بالمستأجر ويكون تحت رحمته — إلا إذا اتفقا على حد أقصى أو أدنى، فالصحيح.

الرأي الثالث: تركها بمثابة عدم تقدير، والأجرة أجرة المثل.

بواسطة القانون (أجرة المثل):

التعريف: أجرة مثل الشيء المؤجر وقت التأجير ولنفس المنفعة المتفق على تأجيرها.

1. **الحالة الأولى:** عدم الاتفاق على مقدار الأجرة.
2. **الحالة الثانية:** عدم الاتفاق على كيفية التحديد.
3. **الحالة الثالثة:** تعذر إثبات مقدارها.

كيفية التقدير: في هذه الحالات يقدر القاضي أجرة المثل مستعيناً بأهل الخبرة وما يقدم من مستندات — كعقود إيجار عن نفس الشيء عن مدة سابقة أو تالية، أو عقود عن أعيان مماثلة في الخدمات والملحقات والموقع.

وفقاً لقانون إيجار الأماكن:

التمهيد: تفاقم أزمة المساكن أدى إلى استغلال الملاك، فتدخل المشرع لتحقيق توازن بفرض حد أقصى حمايةً للمستأجرين، وتوالت التشريعات التي قيدت الأجرة بحسب تاريخ الإنشاء أو الترخيص، فانقسمت الأماكن إلى ثمانية أقسام منها:

أولاً: الأماكن المنشأة قبل 1/1/1944 والعقود المبرمة منذ 1/5/1941:

م 4 من القانون 121/1947: لا تزيد الأجرة على أجرة شهر إبريل 1941 (أو أجرة المثل لهذا الشهر إن لم تكن مؤجرة فيه)، مضافاً إليها النسب الآتية:

- **محال تجارية/صناعية/عامة:** 45% (حتى 5 ج)؛ 60% (ما زاد).
- **عيادات أطباء ومكاتب محامين ومهندسين:** 30% (لأصحاب المهن غير التجارية).

MARA 01054054178

محاكم ومدارس وأندية ومستشفيات: 25% (وسائر الأماكن الحكومية أو العلمية).

أماكن أخرى: 10% (حتى 4 ج شهرياً)؛ 12% (حتى 10 ج)؛ 14% (ما زاد).

المؤجرة مفروشة: 70%.

عناصر التحديد: يدخل في الأجرة كل شرط أو التزام جديد لم يكن في عقود ما قبل 1/5/1941 أو لم يجر العرف بفرضه (كثمن المياه) — يقوَّم في إبريل 1941 ويخصم، ويضاف ما يقابل التزامات جديدة على المؤجر لم يكن ملتزماً بها في إبريل 1941 (كالصيانة في العقود بعد 15/10/1949 وفقاً لم 567 مدني)، ويضاف ما يقابل الإصلاحات والتحسينات بعد هذا الشهر وقبل انتفاع المستأجر الحالي.

الإسكندرية: الخيار للمؤجر بين أغسطس 1939 (الشهر السابق لإعلان الحرب) أو إبريل 1941 أو أجرة المثل، لانخفاض أجرتها بغارات الحرب العالمية الثانية.

أماكن الحكومة وفروعها: أغسطس 1944؛ ومجالس المديريات — أغسطس 1943؛ ومجالس البلدية والقروية — يوليو 1945 أو أجرة المثل، مضافاً إليها النسب المقررة مراعاةً لصالح المؤجرين.

التحديثات: تستنزل الضرائب المعفاة وفقاً للقانون 169/1961 من 1/1/1962. وتزاد أجرة غير السكن وفقاً للقانونين 136/1981 و6/1997.

1. **شرط التطبيق الأول:** المنشأة قبل 1/1/1944 — العبرة بتمام الإنشاء لا بالتأجير.
2. **شرط التطبيق الثاني:** خاضعة للقانون 121/1947 — بعقد صحيح في عواصم المحافظات أو المدن والقرى المقررة بقرار وزير الإسكان.
3. **شرط التطبيق الثالث:** العقد مبرم منذ 1/5/1941 أو بعده.

أساس الحد الأقصى: الأجرة الفعلية في إبريل 1941. فإن لم تكن العين مؤجرة فيه، أو تعذر إثبات أجرتها، أو بُنيت بعده، فالأساس أجرة المثل في هذا التاريخ بافتراض أنها كانت موجودة ومؤجرة لنفس الغرض، وتندب المحكمة خبيراً — ورأيه استشاري.

عقود ما قبل 1/5/1941 السارية: لا زيادة إلا بعد انتهاء المدة، من تاريخ المطالبة.

عقود 1/5/1941 وما بعدها: من أول الشهر التالي للإخطار ولو لم تنته المدة، والحق جوازي، وللمستأجر الخيار بين قبول الزيادة وفسخ العقد (الفقرة 4 من المادة 4).

ثانياً: الأماكن المنشأة منذ 1/1/1944 إلى 18/9/1952:

المرسوم بقانون 199/1952: أضاف ثلاث فقرات للمادة 5 من القانون 121/1947:

1. **الفقرة الأولى:** تخفض بنسبة 15% الأجور الحالية للأماكن المنشأة بعد 1/1/1944، ابتداءً من الأجرة المستحقة عن أكتوبر 1952.
2. **الفقرة الثانية:** الأجرة للأماكن المذكورة — إذا لم يسبق تأجيرها — على أساس أجرة المثل عند العمل بالقانون مخفضة بنسبة 10%.
3. **الفقرة الثالثة:** لا يسري التخفيض على: المباني التي بدأ إنشاؤها بعد العمل بالقانون؛ وعقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات.

الحد الأقصى: الأجرة التي كانت مؤجرة بها وقت صدور المرسوم أو أجرة المثل في هذا الوقت مخفضة بنسبة 15%، ويسري التخفيض لكل مستأجر — سواء كان مستأجراً وقت الصدور أو استأجر بعده.

1. **شرط التطبيق الأول:** خاضعة للقانون 121/1947.
2. **شرط التطبيق الثاني:** من الأماكن التي بدأ إنشاؤها قبل 1/1/1944 واستمر بعدها، أو بدأ إنشاؤها في 1/1/1944 أو بعدها وقبل 18/9/1952 أو بعده — مشغولةً أو لا.
3. **شرط التطبيق الثالث:** ألا يكون الإيجار لمدة تزيد على عشر سنوات.

العلة: أن المالك بنى في ظروف الغلاء، فإذا أُجر لأكثر من عشر سنوات كان قد عوَّل عند البناء على الأجرة المتفق عليها وأراد ضمانها طوال المدة؛ أما من بنى في الغلاء ولم يؤجر طويلاً فقد قبل التعرض لتقلبات الظروف والنظم.

1. **خطوة ١:** تخفض الأجرة الحقيقية السارية في شهر الأساس (18/9/1952) بنسبة 15% من أكتوبر 1952. ويؤخذ بأجرة المثل إن تعذر إثبات الحقيقية، ثم تخفض 15%.
2. **خطوة ٢:** تخفض الأجرة السابقة بقدر قيمة الضرائب المعفاة طبقاً للقانون 169/1961 اعتباراً من 1/1/1962، ثم 20% من 1/3/1965 تطبيقاً للقانون 7/1965.

3 **خطوة ٣:** تعاد الضريبة على الأماكن المنشأة أو المستعملة لغير السكن عملاً بالقانون 46/1968 من 1/1/1968. وتزاد الأجرة عند تغيير الاستعمال وفقاً للقانون 49/1977 و136/1981 و6/1997.

المقصود بالأجرة: الأجرة التي يرد عليها التخفيض: الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على العمل بالقانون 169/1961 (عمل به 15/11/1961)، أو الأجرة في العقد — أيهما أقل، وإن لم يكن المكان قد أُجر، فالتخفيض على أساس أجرة المثل عند العمل بالقانون.

الإضافة والخصم: يضاف في كل هذه الأماكن إلى أجرة شهر الأساس مقابل ما التزم به المؤجر من التزامات مستحدثة أو ما حصل عليه المستأجر من مزايا، وينقص قيمة ما فُرض على المستأجر أو حُرم منه بفعل المؤجر أو بقوة قاهرة طالما كانت داخلة في أجرة شهر الأساس.

ثالثاً: الأماكن التي أُنشئت في 18/9/1952 وحتى 12/6/1958:

القانون 55/1958 (م 4): "تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التي أُنشئت منذ 18/9/1952 وذلك ابتداءً من الأجرة المستحقة عن شهر يوليو 1958."

المستفاد: المباني التي بدأ إنشاؤها بعد 18/9/1952 لا تسري عليها المادة 4 من القانون 121/1947 ولا تخفيض 15% المقرر بالمرسوم 199/1952، فبقيت أجرتها حرة حتى القانون 55/1958. "وتعتبر الأماكن منشأة في التاريخ المشار إليه إذا كان البناء قد انتهى فيها وأُعدت للسكنى فعلاً في 18/9/1952 أو بعده،" وبذلك دخلت المباني التي بدأ إنشاؤها قبل 18/9/1952 ولم تتم إلا بعده في نطاق تطبيق القانونين 199/1952 و55/1958.

- **الرأي الأول:** المباني التي بدأ إنشاؤها قبل 18/9/1952 ولم تكتمل إلا بعده — القانون 199/1952 (تخفيض 15%).
- **الرأي الثاني:** القانون 55/1958 — العبرة بتمام الإنشاء في 18/9/1952.
- **الرأي الثالث (الراجح):** تخفيض 15% حتى آخر يونيو 1958، ثم 20% من أول يوليو 1958، دون جمع بين التخفيضين، (أخذت به محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر في 28/3/1981، وأيده كثير من شراح القانون،)

1 **خطوة ١:** تخفيض الأجرة بنسبة 20%، والمقصود بالأجرة الحالية وفقاً للقانون 55/1958: الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على العمل به، أو الأجرة في العقد — أيهما أقل، وإن لم يكن قد أُجر، فالتخفيض على أساس أجرة المثل عند العمل بالقانون.

2 **خطوة ٢:** يطبق القانون 169/1961 (تخفيض بقدر الإعفاء الضريبي)، والقانون 7/1965 (تخفيض الحد الأقصى بنسبة 20% من 1/3/1965).

3 **خطوة ٣:** تعاد الضريبة على الأماكن المنشأة أو المستعملة لغير السكن من 1/7/1968 وفقاً للقانون 46/1968، وتزاد عند تغيير الاستعمال وفقاً للقانون 49/1977 و136/1981 و6/1997 — **م 7 من 6/1997** : "تزاد أجرة الأماكن الموضحة لغير أغراض السكن بنسبة 20% لأماكن الفرع الثاني، وبنسبة 10% لأماكن الفرع الثالث وذلك من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية وقت الإنشاء."

⚠ **استثناء:** لا يسري التخفيض على المباني التي بدأ إنشاؤها بعد العمل بالقانون، ولا على عقود الإيجار لمدة تزيد على عشر سنوات.

3 المبحث الثالث: المدة في عقد الإيجار:

🕐 **القاعدة:** المدة عنصر جوهري؛ لا يتصور انتفاع بلا فترة، سواء حددها الطرفان أو القانون.

🤝 **تحديدها بواسطة الطرفين:** قد يتفقان على المدة ويذكران بدايتها ونهايتها؛ وقد يرجئان التحديد لاتفاق لاحق — فيكون الإيجار متوقفاً عليه، فإن لم ينعقد حددت المدة طبقاً للقانون؛ وقد يعهدان لشخص أجنبي بتحديدها، فإن رفض أو امتنع حددت المدة أيضاً بالقانون.

⚖ **تحديدها بواسطة القانون:** (1) عدم الاتفاق على مدة، (2) الاتفاق على مدة غير محدودة، (3) الاتفاق على المدة وتعذر إثباتها.

📖 **م 563 مدني:** "إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها:"

أراضٍ زراعية وبور: الفترة ستة أشهر أو أكثر: ثلاثة أشهر قبل انتهائها؛ وإذا كانت أقل: قبل نصفها الأخير — مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف.

منازل وحوانيت ومكاتب ومتاجر ومصانع ومخازن: الفترة أربعة أشهر أو أكثر: شهرين قبل انتهائها؛ وإذا كانت أقل: قبل نصفها الأخير.

مساكن وغرف مؤثثة وأي شيء غير ما تقدم: الفترة شهرين أو أكثر: شهر قبل نهايتها؛ وإذا كانت أقل: قبل نصفها الأخير.

م 18 من القانون 136/1981: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:"

1. **أسباب الهدم:** الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقاً للأحكام المنظمة بالقوانين السارية.
2. **عدم الوفاء بالأجرة:** عدم وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بإعلان على يد محضر، (ولا يُحكم بالإخلاء إذا أدى المستأجر قبل إقفال باب المرافعة الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر بسبب التأخير إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح إذا سدد الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، بشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر، فإذا تكرر الامتناع أو التأخر دون مبررات تقدرها المحكمة حُكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.)
3. **التنازل أو التأجير من الباطن:** ثبوت تنازل المستأجر عن المكان أو تأجيره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائياً — دون إخلال بحالات القانون للمستأجر بالتأجير مفروشاً أو التنازل أو التأجير من الباطن أو الترك لذوي القربى وفقاً **لم 29 من 49/1977** .
4. **الاستعمال المقلق:** ثبوت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب، (ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها، لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة، وتلغى المادة 31 من القانون 49/1977 اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 136/1981.)

حد أقصى للمدة؟: كان في المشروع التمهيدي نص يقيّدها بثلاثين عاماً، حُذف في مجلس النواب دون ذكر سبب، فجاء التقنين خالياً من نص يحدد المدة، ومع ذلك توجد نصوص لا تجيز الإيجار لأكثر من ثلاث سنوات إذا كان المؤجر يملك حق الإدارة فقط، ولما لم يكن هناك نص قاطع، اختلف الفقهاء في شأن من يملك التصرف والإدارة معاً:

الرأي الأول: لا تزيد على ستين سنة قياساً على حق الحكر.

الرأي الثاني (الراجح عندنا): الحد الأقصى متروك للقاضي يفصل حسب الظروف، ولا يتقيد بنص الحكر، فله أن يعتبر الإيجار مؤقتاً ولو زاد على ستين سنة ما دامت الظروف تثبت أنه ليس مؤبداً.

١- **الإيجار حق شخصي:** الإيجار يعطي المستأجر حقاً شخصياً، والحكر يخول حقاً عينياً.

٢- **لا تغيير ولا تبديل:** المستأجر لا يستطيع التغيير والتبديل، والمحكر له ذلك.

٣- **طبيعة الأرض:** الحكر غالباً على أرض خربة، والإيجار على أرض صالحة.

الراجح: القاضي له سلطة تقديرية بحسب ظروف كل حالة؛ لأنه يرجع إليه دائماً في حالة غياب النص أو عدم وضوحه، ليفصل في ضوء القواعد العامة ومبادئ العدالة والعرف.

MARA 01105405478

الباب الثالث: آثار الإيجار:

١ التزامات المؤجر | ٢ التزامات المستأجر

الفصل الأول: التزامات المؤجر:

الإحالة التشريعية: نظم المشرع هذه الالتزامات بالإحالة على تسليم المبيع.

1. **م 566:** "يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها."
2. **م 564:** "يلتزم المؤجر بأن يسلم العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة العين."
3. **م 565:** (1) إذا سلمت العين في حالة لا تصلح للانتفاع أو نقص الانتفاع نقصاً كبيراً، جاز للمستأجر طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة بقدر النقص مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى، (2) فإذا كانت العين في حالة تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم، جاز له طلب الفسخ ولو نزل عن حقه.

١ الإلتزام الأول ← الالتزام بتسليم العين المؤجرة:

– تسليم العين وملحقاتها:

تسليم العين: يلتزم المؤجر بتسليم العين وفقاً للاتفاق، ولا يجوز تسليم غيرها إلا بقبول المستأجر — وفي هذه الحالة نكون بصدد التزام جديد بتغيير المحل.

1. **معين بالذات:** (كالأرض الزراعية) ببيان الحدود والمساحة والموقع والحوض والقطعة.
2. **معين بالنوع:** بتسليم نفس النوع والمقدار ودرجة الجودة المتفق عليها؛ فإن لم يتفق على الجودة رجع إلى العرف ويسلم شيئاً من صنف متوسط.

الزيادة اليسيرة: (عرف التسامح) — لا تؤثر على صحة العقد.

MARA 01105405478

الزيادة الكبيرة – تقدير الأجرة جملةً: لا يلتزم المستأجر بزيادة الأجرة — الغالب أن إرادة الطرفين اتجهت لبقائها كما هي.

الزيادة الكبيرة – بحسب الوحدة: إن كانت العين قابلة للتبعيض: للمؤجر استرداد الزيادة، وإن كانت غير قابلة: يلتزم المستأجر بزيادة الأجرة بنسبة ما زاد، إلا إذا بلغت الزيادة حداً جسيماً لو علم بها المستأجر قبل العقد ما أقدم — فله طلب الفسخ.

النقص: يسير (عرف التسامح) — لا مشكلة، جسيم (لو علم به المستأجر ما أقدم على التعاقد) — له طلب الإبطال، وتقدير اليسير والجسيم لقاضي الموضوع بحسب الظروف.

حق المستأجر: إنقاص الأجرة بنسبة ما نقص مع مراعاة حقه في التعويض عما أصابه من ضرر — وليس مجرد حرمانه من الانتفاع بالجزء الناقص.

رفع الدعوى: خلال **سنة** من تاريخ التسليم الفعلي لا من تاريخ الإيجار.

الطبيعة القانونية: الأحكام المنظمة للعجز والزيادة **مكملة**، يجوز الاتفاق على خلافها — بما في ذلك الإعفاء من المسؤولية، ولا يلزم شكل معين (صريح أو ضمني) بشرط وضوح الدلالة على انصراف نية المستأجر للتنازل.

الملحقات: ما يتبع الأصل ويعد بصفة دائمة لخدمته دون أن يكون جزءاً فيه أو من ثماره أو منتجاته، وتحدد باتفاق المتعاقدين أو عرف الجهة أو طبيعة الأشياء أو القاضي عند النزاع.

منزل: المفاتيح، الأبواب، النوافذ، الحديقة، الفناء، أجهزة الكهرباء والمياه والغاز والتكييف، المصعد الكهربائي.

شقة مفروشة: كل ما يوجد فيها.

الحالة التي يجب أن تسلم بها العين:

م 564: توجب تسليمها في حالة تصلح للغرض، وعلى المؤجر إجراء الإصلاحات الضورية والتأجيرية معاً — حتى تؤدي العين غرضها.

منزل: طلاء الجدران، إصلاح النوافذ والأبواب والزجاج والأسلاك.

أرض زراعية: إصلاح المساقي والمصارف وإزالة كل ما يعوق الانتفاع.

MARA 01054058478

الطبيعة: قواعد مكملة، يجوز الاتفاق على خلافها — إلا **م 13 من القانون 49/1977** : "يلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال في المواعيد المتفق عليها وإلا جاز للمستأجر بعد إعذار المالك استكمال الأعمال الناقصة بترخيص من قاضي الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة،" وهي **قاعدة آمرة** — الحكمة: منع تحايل المؤجر للحصول على أجرة تزيد على القانونية، فلو اتفق المؤجر مع المستأجر على مخالفتها كان الاتفاق باطلاً، وللمستأجر رغم الاتفاق أن يخصم تكاليف ما أنفقه.

كيفية التسليم:

م 1/435: "يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستولي عليه استيلاءً مادياً ما دام البائع قد أعلمه بذلك، ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع،"

1. **فعلي:** وضع العين تحت تصرف المستأجر ولو لم يستول عليها مادياً ما دام المؤجر أعلمه، مثال: تسليم مفاتيح المنزل وإخلاؤه.
2. **حكمي:** تصرف قانوني بتراضي المتعاقدين على تغيير صفة الحيازة، مثال: أن تكون العين تحت يد المستأجر كوديعة أو عارية أو رهن حيازي، فيتفقا على تحويل صفته إلى مستأجر.

محضر الجرد والتسليم: مفيد في الشقة المفروشة — تحديد المنقولات وحالتها، فبدونه يلتزم المستأجر بردها بحالة حسنة حتى لو كانت في بدء الإيجار سيئة (لأن المفترض أنه تسلمها حسنة)، وقد يكون تحرير المحضر شرطاً عند التسليم؛ فإذا رفض المؤجر كان للمستأجر طلب الفسخ مع التعويض.

النفقات عند عدم الاتفاق: إن كان المحضر لازماً لإتمام التسليم فنفقاته على المؤجر لأنه الملتزم به وتحرير المحضر من متطلباته، أما إن كان التسليم لا يحتاج إلى محضر فنفقاته على من يطلبه من الطرفين.

زمان ومكان ونفقات التسليم:

الزمان: لا نص خاص، والمرجع **م 1/346** : "يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً في ذمة المدين ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك،" فيتفقان على وقت معين؛ فإن لم

يتفقا أو اختلفا ولم يثبتا الاتفاق رجع إلى عرف الجهة وطبيعة الشيء؛ فإن تعذر — التسليم فور انعقاد العقد.

الأرض الزراعية: سنة زراعية تبدأ سبتمبر.

المنزل/الشقة: الشهر التالي للإبرام (عقد يناير 2009 ← تسليم فبراير 2009).

المكان: م 1/347 : "إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك."

النفقات: على المؤجر — لأنه المسؤول عن التسليم — بما فيها ما يقتضيه نقل الشيء إلى مكان التسليم (كمقاس الأرض وتحديدها)، أما إن أراد المستأجر التسلم في مكان آخر فالنقل عليه، كما يلتزم المستأجر بنفقات تقدير الشيء ومطابقته للمواصفات.

جزاء الإخلال بالتسليم:

الحالتان: تسليم معيب؛ عدم تسليم أصلاً.

أولاً: التسليم المعيب: لا يبرئ ذمة المؤجر، وللمستأجر ثلاثة حقوق:

التنفيذ العيني: إصلاح الخلل، م 1/568 : "إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة في المادة السابقة، جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصماً من الأجرة.." م 2/568 : "يجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أن يقوم بإجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر، سواء كان العيب موجوداً وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك إذا لم يقم المؤجر بعد إعذاره بتنفيذ هذا الالتزام في ميعاد مناسب، على أن يستوفي المستأجر ما أنفقه خصماً من الأجرة." شرطان: الإعذار، ومضي وقت مناسب بعده، وله الرجوع بما أنفقه أو الخصم.

MARA 01105405478

الفسخ: حالتان قضائي إلزامي:

- شرط صريح بانفساخ العقد تلقائياً عند إخلال المؤجر بالتسليم بعد إعذاره — ما لم يتفق على الإعفاء من الإعذار،
- **م 2/565** : "إذا كانت العين المؤجرة في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ولو كان قد سبق له أن نزل عن هذا الحق،"

وفي غير ذلك: سلطة تقديرية، فإن رأى ضرراً كبيراً لا يجبره الإصلاح حكم بالفسخ؛ وإن رأى ما تبقى قليل الأهمية بالنسبة لما تم فلا فسخ.

إنقاص الأجرة: بنسبة ما أصابه من ضرر لا بقدر ما نقص من الشيء — تطبيقاً **لم 1/565** .

ثانياً: عدم التسليم: إخلال واضح، فإن كانت الاستحالة (مادية كهلاك العين، أو قانونية كاستيلاء الدولة للمنفعة العامة) فالجزاء الفسخ مع التعويض، بشرط إثبات خطأ المؤجر وسببيته في الاستحالة؛ وإلا فالفسخ فقط.

2 الإلتزام الثاني ← الالتزام بالصيانة:

المبدأ: التسليم لا يكفي؛ لابد من تمكين المستأجر من الانتفاع أثناء المدة، فالتزام التسليم إيجابي لا سلبي.

م 567 – الالتزامات: (1) على المؤجر أن يتعهد العين بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون التأجيرية، (2) وعليه أن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقوم بنزع الآبار والمراحيض ومصارف المياه، (3) ويتحمل التكاليف والضرائب المستحقة على العين ويلزم بثمن المياه إذا قدر جزافاً، فإذا كان "بالعداد" كان على المستأجر، أما الكهرباء والغاز وغيرهما مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر، (4) كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.

– المضمون والتفرقة بين الترميمات:

الفرق بين التسليم والصيانة: تسليم: المؤجر يلتزم بالترميمات الضرورية والتأجيرية معاً، صيانة: يلتزم بالضرورية فقط، ويخوله حق القيام بها رغم إرادة المستأجر — بخلاف القانون المدني القديم الذي لم يجز ذلك إلا باشتراط.

MARA 01105405478

⚠ **نطاق الصيانة:** لا يلتزم المؤجر إذا هلك الشيء كلياً — كانهيار المنزل أو الاستيلاء عليه للمنفعة العامة.

📖 **م 1/569:** "إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً انفسخ العقد من تلقاء نفسه، ويترتب انقضاء الالتزامات والفسخ — سواء كان الهلاك بخطأ المؤجر أو المستأجر أو بقوة قاهرة، ولا عبرة بالسبب إلا فيما يتعلق بالتعويض: فالهلاك بقوة قاهرة لا رجوع لأحدهما على الآخر؛ أما الهلاك بخطأ المؤجر فللمستأجر الرجوع بالتعويض.

النوع	التعريف	أمثلة
الضرورية	اللازمة للانتفاع بالعين على الوجه المقصود من العقد.	أعمال الأسطح كالتجصيص والبياض.
التأجيرية	البسيطة التي يقتضيها استعمال العين استعمالاً مألوفاً.	إصلاح النوافذ والأبواب وصنابير المياه؛ وفي الأراضي: تطهير المساقي والمصارف.

❓ **المعيار بينهما:** لا معيار نصي؛ يرجع إلى الاتفاق أو العرف أو طبيعة الشيء.

🏛 **الضرائب والرسوم:** المؤجر يلتزم بضرائب الأطيان الزراعية وضريبة الدفاع ونفقات تسوية الأرض الفضاء وتطهير المساقي والمصارف، أما رسوم البلديات على السكان (كرسم النظافة) فعلى المستأجر ولو حصلتها الإدارة من المؤجر، وثمن المياه جزافاً على المؤجر؛ بالعداد على المستأجر؛ وكذلك الكهرباء والغاز.

➖ مدى جواز الاتفاق على التعديل وجزاء الإخلال:

⚖ **م 4/567:** "كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك،" فالأحكام **مكملة** ، ويجوز الاتفاق الصريح أو الضمني المستفاد من ظروف الحال، مثال: تأجير منزل في حي قديم بأجر زهيد يدل على قبول المستأجر بالحالة وإعفاء المؤجر ضمناً من الترميمات الضرورية — لأنها ستكلفه نفقات باهظة لا تتناسب مع الأجرة.

⚖ **التفسير:** عند وجود اتفاق على الإعفاء أو التعديل يجب تفسيره بدقة، وعند الغموض يفسر الشك لمصلحة من يضار منه.

أولاً: التنفيذ العيني: م 1/203 : "يجبر المدين بعد إعذاره طبقاً للمادتين 219 و220 على تنفيذ التزامه عينياً، متى كان ذلك ممكناً." م 2/203 : "إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً." شروطه: (1) ممكن، (2) غير مرهق للمدين، (3) ألا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً بعدم التنفيذ العيني.

ثانياً: الفسخ: إذا ترتب على التنفيذ العيني إرهاق للذمة المالية للمؤجر — بشرط ألا يلحق بالمستأجر ضرراً جسيماً.

ثالثاً: إنقاص الأجرة: صورة من التعويض، شرطان: (1) أن يكون الإنقاص متناسباً مع الضرر — لا بقدر ما نقص من العين، (2) أن يكون عن المدة التي تلي إعذار المؤجر بالقيام بوقت مناسب — لا من وقت نشوء الالتزام.

الخصم من الأجرة: لا يتم إلا وفقاً لقواعد المقاصة — بتراضي الطرفين أو بحكم قضائي.

التعويض في جميع الأحوال: يشترط إثبات خطأ المؤجر أو أحد أتباعه، مثال: انهيار حائط بسبب إهمال المؤجر في ترميمه ← تعويض، أما لو كان الانهيار بزلزال أو قوة قاهرة فلا — م 3/569 : "ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضاً إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه." والأساس مسئولية عقدية، فلا تعويض إلا عن الضرر المباشر المتوقع.

الرأي الأول (الإعذار لازم): لا استحقاق للتعويض إلا بعد إعذار طبقاً لم 218 ، وإذا كان المؤجر قد تسبب بفعله في الإخلال بأن جعل العين بحاجة إلى ترميم، فالإعذار غير لازم.

الرأي الثاني (الراجح عندنا): لا ضرورة للإعذار — (1) العقد مستمر، فالمؤجر ملتزم طوال المدة، (2) م 585 اكتفت بإخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله دون شرط الإعذار للرجوع بالتعويض.

الرأي الأول (الراجح عندنا): له الحبس — إعمالاً للدفع بعدم التنفيذ، (1) الثاني يخالف القواعد العامة، (2) لا مبرر لحرمانه من حقه، (3) القول بأن التزام الصيانة ثانوي غير صحيح.

الرأي الثاني: لا — (1) الصيانة التزام ثانوي، (2) الحبس يضع المؤجر تحت رحمة المستأجر، (3) قد تكون الصيانة محل منازعة في الوفاء ومقداره.

3 الإلتزام الثالث ← التزام المؤجر بالضمان:

المبدأ: مسؤولية عن كل فعل يعكر صفو الانتفاع — سواء كان تعرضاً من المؤجر أو أتباعه، أو عيباً خفياً في العين، مطلبان.

− ضمان التعرض:

م 1/571: "على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع."

التعرض المادي: عمل مادي يحول دون الانتفاع كلياً أو جزئياً دون سند حق، مثال: سد نافذة، منع المستأجر من دخول العين.

التعرض القانوني: تصرف قانوني من المؤجر أو أتباعه قبل الإيجار أو بعده يؤدي إلى حرمان أو انتقاص حق المستأجر، مثال: تقرير حق عيني أو شخصي لشخص آخر على العين ويحتج به.

الشرط	المضمون
١- وقوع التعرض فعلاً	فلا ضمان لمجرد الخشية أو الاحتمال، مثال: بيع العين لا يستوجب مسؤولية المؤجر إلا إذا تعرض المشتري وطالب بالإخلاء.
٢- وقوعه أثناء مدة الانتفاع	سواء المدة الأصلية أو الامتداد (قانوني أو اتفاقي أو قضائي)، فالتعرض قبل البدء أو بعد الانتهاء لا يستوجب ضماناً.
٣- ألا يستند إلى سبب مشروع	فإن استند إلى قانون أو اتفاق أو حكم قضائي فلا ضمان.
٤- ترتب الحرمان على التعرض	حرمان من الانتفاع بالمزايا المادية أو المعنوية كلياً أو جزئياً.

تعديلات العين: لا خلاف بين الفقهاء — **م 1/570** يحسم المسألة (ولا اجتهاد مع النص)، وخروجاً على القاعدة، نرى مع بعض الفقهاء أن للمؤجر الحق في تعديلات بشروط: (1) ألا يوجد نص يمنع — **باستثناء م 32 من القانون 49/1977** : "يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك ولا

يخل هذا بحق المستأجر في إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل،" (2) ألا يترتب عليها ضرر جسيم بالمستأجر، (3) أن يكون الغرض تحقيق مصلحة جدية للمؤجر والمستأجر.

جزاء التعرض الشخصي: للمستأجر طلب وقف التعرض (تنفيذ عيني)، أو الفسخ إن وجد مبرراً، أو إنقاص الأجرة، وله في جميع الأحوال التعويض إن كان له مقتضى.

ضمان التعرض الصادر من الغير:

م 572: (1) إذا ادعى أجنبي حقاً يتعارض مع حقوق المستأجر بمقتضى الإيجار، وجب على المستأجر المبادرة بإخطار المؤجر، وكان له أن يخرج من الدعوى — وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر، (2) فإذا ترتب على الادعاء أن حرم المستأجر فعلاً من الانتفاع، جاز له تبعاً للظروف طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتضى.

الشرط	المضمون
١- صدوره من الغير	فالمؤجر ليس من الغير؛ لأنه طرف في العقد.
٢- أن يدعي الغير حقاً متعلقاً بالعين يتعارض مع حق المستأجر	يكفي مجرد الادعاء — سواء كان مبنيّاً على أساس أو لا؛ حتى لو كان ظاهر البطلان.
٣- وقوعه بالفعل	مثال: ادعاء شخص بحق ارتفاق بالمرور؛ يضطر المستأجر لرفع دعوى ضمان يدخل فيها المتعرض خصماً مدعى عليه لا مدعياً.
٤- وقوعه أثناء المدة	—

1. **الإخطار:** يجب على المستأجر المبادرة بإخطار المؤجر في أقرب وقت ليتخذ إجراءاته، لم يحدد القانون ميعاداً ولا شكلاً — يجوز بإعلان محضر أو كتاب مسجل أو غير مسجل أو شفوي، وعبء إثباته على المستأجر، فإن تأخر أو لم يخطر وترتب على ذلك فوات الفرصة، وأثبت المؤجر أن التعرض قائم على غير أساس، فلا رجوع للمستأجر بالضمان — بل للمؤجر الرجوع عليه بتعويض لتقصيره.
2. **دفع المؤجر للتعرض:** فور إخطاره — تنفيذ عيني لالتزامه بالضمان.

3 **دفع المستأجر للتعرض بنفسه:** الأصل: لا؛ لأن حقه شخصي، استثناءً: له أن يدفع بنفسه وباسمه (لا باسم المؤجر) في الحالات التي يصلح فيها خصماً حقيقياً — (أ) جميع دعاوي الحيازة، (ب) جميع الدعاوي الأخرى التي له فيها صفة الخصم، مثال: شراء شخص للعين بتاريخ لاحق لعقد الإيجار الثابت، ثم رفعه دعوى إخلاء — للمستأجر صفة الخصم وله التمسك بعقد الإيجار الثابت السابق على البيع، دون حاجة لإدخال المؤجر.

4 **نجاح المتعرض:** للمستأجر الرجوع بضمان الاستحقاق على المؤجر، وله تبعاً للظروف الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض.

⚠ **التعديل بالاتفاق – م 578:** "يقع باطلاً كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب، إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان."

⚖ **م 575 – التعرض المادي من الغير:** (1) لا يضمن المؤجر التعرض المادي من أجنبي لا يدعي حقاً — دون إخلال بحق المستأجر في رفع دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوي وضع اليد باسمه على المتعرض، (2) إذا وقع التعرض المادي بسبب لا يد للمستأجر فيه، وكان من الجسامة بحيث يحرمه من الانتفاع، جاز له تبعاً للظروف طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.

🏛 **م 574 – عمل الجهة الحكومية:** "إذا ترتب على عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، وله أن يطالب المؤجر بتعويضه إذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسؤولاً عنه، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره." لا يعد تعرضاً مبنياً على سبب قانوني — فالجهة الحكومية تستند إلى حقوق السلطة العامة لا إلى حق خاص.

➖ المطلب الثاني: ضمان العيوب الخفية:

📖 **المبدأ:** أحكام البيع أصل يرجع إليه فيما لم يرد نص خاص أو يتعارض مع طبيعة الإيجار — لأن المشرع عرض لضمان العيوب وفوات الوصف في صدد البيع.

⚖ **م 576:** (1) "يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصاً كبيراً، ولكنه لا يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها وهو مسؤول عن خلو العين من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك."

الشرط	المضمون
١- العيب مؤثر	حكم قاضٍ الموضوع بحسب الحالة؛ ولا عبرة بالمعيار الشخصي، مثال: سيارة تستهلك وقوداً أكثر من المقدار المعين.
٢- العيب خفي	ألا يستطيع المستأجر تبينه لو فحص بعناية الرجل العادي — أو كان يستطيع لكن المؤجر أكد خلو العين منه أو تعمد إخفاءه غشاً.
٣- غير معلوم للمستأجر	وقت تسلم العين، لا يتخلص المؤجر من الضمان إلا بإثبات علم المستأجر — م 2/576 :

م 577 – الجزاء: (1) إذا وجد بالعين عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر تبعاً للظروف طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، وله كذلك طلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان الإصلاح لا يبهظ المؤجر، (2) فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب.

الخلاصة: للمستأجر التنفيذ العيني، أو الفسخ، أو إنقاص الأجرة، مع التعويض في جميع الأحوال إن كان له مقتضى.

الفصل الثاني: التزامات المستأجر:

الالتزامات الخمسة: دفع الأجرة، استعمال العين، عدم إحداث تغييرات، المحافظة، الرد.

الإلتزام الأول ← دفع الأجرة:

الميعاد – م 1/586: "يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينها عرف الجهة،" فإن لم يكن اتفاق ولا عرف: تدفع مؤخراً لا مقدماً، وعن كل مدة انتفاع عند انقضائها.

التقادم – م 1/375: "يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهيأة والأجور والمعاشات،" تسقط الأجرة بخمس سنوات من وقت حلولها — حتى لو اشترط دفعها مقدماً — أو من وقت حلول كل قسط.

المكان – م 2/586: "ويكون الوفاء في موطن المستأجر، ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك،" هو المدين، فالمكان موطنه — تطبيقاً للقواعد العامة.

1. **تغيير المستأجر لموطنه:** بعد الإبرام: المكان موطنه وقت الدفع لا السابق.
2. **اشتراط الدفع في غير موطنه:** (كموطن المؤجر) عمل بالشرط.
3. **تغيير المؤجر لموطنه:** لم يلتزم المستأجر بالدفع في الموطن الجديد — لأن اشتراط الدفع في موطن المؤجر استثناء لا يتوسع فيه، وإذا أرادا أن يكون الدفع في موطن المؤجر ولو تغير فيجب النص على ذلك.

استثناء المكان: إذا تعين مكان الدفع لم يجز الدفع في غيره إلا إذا اقتضى الأمر — كحجز دائن للمؤجر على الأجرة تحت يد المستأجر، فيجوز إيداعها خزانة المحكمة.

الطريقة: إن كانت الأجرة أو بعضها من غير النقود فلا يجوز الدفع نقداً إلا برضاء المؤجر، الدفع بحوالة بريدية صحيح ما لم يشترط العقد خلافه — والنزاع في صحته ليس من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لأنه يمس الموضوع، الدفع بشيك أو سند إذني أو كمبيالة لا يصح إلا برضاء المؤجر — وإذا رضي لم يكن تجديداً للأجرة بل توثيقاً لها، ويبقى امتياز المؤجر وسائر الضمانات قائمة حتى بعد كتابتها، ما لم يتفق على غيره.

الإثبات – م 587: "الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط، حتى يقوم الدليل على عكس ذلك،" المستأجر لا يحتاج للاحتفاظ بالمخالصات خمس سنوات — تكفيه الأخيرة، والقرينة قابلة لإثبات العكس، وعبء الإثبات على المؤجر (مثلاً: بالرغم من مخالصة مارس، فبراير لم يدفع)، **المذكرة الإيضاحية** : "وبفضل هذه القرينة لا يضطر المستأجر أن يحتفظ بإيصالات دفع الأجرة عن خمس سنوات، ويكفيه أن يحتفظ بالإيصال الأخير،"

1. **وضع منقولات – م 588:** "ويجب على كل من استأجر منزلاً أو مخزناً أو حانوتاً أو مكاناً مماثلاً لذلك أو أرضاً زراعية أن يضع في العين المؤجرة أثاثاً أو بضائع أو محصولات أو مواشي أو أدوات تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة عن سنتين، أو عن كل مدة الإيجار إذا قلت عن سنتين، هذا ما لم تكن الأجرة قد عجلت، ويعفى المستأجر من هذا الالتزام إذا تم الاتفاق على هذا الإعفاء أو إذا قدم المستأجر تأميناً آخر،"

2 **امتياز على المنقولات – م 1/1143:** "أجرة المباني والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار، يكون لها جميعاً امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقولات قابلة للحجز ومن محصول زراعي،" الحق لا يتجزأ — كل منقول يضمن الحق كله، وكل جزء من الحق مضمون بجميع المنقولات، **م 2/1143** : "ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر، أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة،"

3 **حبس المنقولات – م 589:** (1) للمؤجر — ضماناً لكل حق يثبت له بمقتضى العقد — أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين ما دامت مثقلة بامتيازه، ولو لم تكن مملوكة للمستأجر، وله أن يمانع في نقلها؛ فإذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه كان له الحق في استردادها من الحائز ولو كان حسن النية، مع عدم الإخلال بحقوق هذا الحائز، (2) وليس له أن يستعمل الحبس أو الاسترداد إذا كان نقل الأشياء أمراً اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف من شؤون الحياة، أو كانت المنقولات المتروكة أو المستردة تفي بضمان الأجرة وفاءً تاماً.

4 **الحجز التحفظي:** بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها موطنه — يترتب عليه منع المستأجر من إخراج منقولاته أو استردادها إن أُخرجت.

– الإلتزام الثاني ← استعمال العين بحسب ما أعدت له:

م 579: "يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق، التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له،"

1 **اتفاق:** يلتزم بما نص عليه (سكنى، زراعة، مصنع).

2 **بدون اتفاق:** بحسب طبيعة العين والظروف وقرائن الأحوال — ومنها: مهنة المستأجر (لا سيما إن ذكرت في العقد)، وما كانت مستعملة فيه من قبل، وكيفية إعداد العين (قد تدل على غرض خاص كمقهى أو مسرح أو مخبز)، والإعلانات السابقة.

⚠ **الالتزام واجب لا مجرد حق:** فالمستأجر الذي يهجر منزلاً للسكنى ولا يترك من يتعهده بالصيانة مسؤول عن تعويض ما يترتب على الترك من تخرب أو تلف — أو من ضرر لعدم النظافة أو

التهوية، أما من استأجر منزلاً مصيفاً فلا يلزم بسكناه طوال السنة، وما دام يتعهده بالصيانة فلا مسؤولية.

الجزاء: للمؤجر طلب التنفيذ العيني، وله التهديد المالي، وله عند الاقتضاء طلب وضع العين تحت الحراسة لإدارتها على الوجه الواجب، وله طلب الفسخ — وليست المحكمة ملزمة بإجابته، وقد تكتفي بالحكم بالاستعمال المشروع وتعويض الضرر، وله في الحالتين التعويض.

الإلتزام الثالث ← إحداث تغييرات في العين:

م 580: (1) "لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجر، إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر." (2) "فإذا أحدث المستأجر تغييراً في العين المؤجرة مجاوزاً في ذلك حدود الالتزام الواردة في الفقرة السابقة، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها، وبالتعويض إن كان له مقتض."

المراد بالتغيير: مادي — لا مجرد تغيير الاستعمال، كفتح نوافذ جديدة، سد نوافذ، تغيير ترتيب الغرف، أي تغيير مادي آخر، فإن ترتب عليه ضرر للمؤجر دون إذنه كان مخلاً.

إن لم يترتب ضرر: للمستأجر إحداثه ولو بغير إذن — بشرط إعادة العين إلى أصلها عند نهاية الإيجار إن طلب المؤجر، مثال: تغيير تنسيق حديقة دون اقتلاع أشجار، وعبء إثبات عدم الضرر على المستأجر، لكن إن اشترط المؤجر عدم إحداث أي تغيير فلا يجوز — ولو كان غير ضار — إلا بإذنه.

الجزاء: للمؤجر إلزام المستأجر بإعادة العين إلى حالتها وبالتعويض إن كان له مقتضى — تطبيقاً للقواعد العامة، وله التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض.

م 581 – وضع أجهزة حديثة: (1) "يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتلفون والراديو وما إلى ذلك ما دامت الطريقة التي توضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية، وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار." (2) "فإذا كان تدخل المؤجر لازماً لإتمام شيء من ذلك، جاز للمستأجر أن يقتضي منه هذا التدخل، على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر."

1. **الشرط الأول:** ألا تهدد سلامة العقار (كبناء قديم يخشى عليه من أنابيب المياه).

2 **الشرط الثاني:** أن يراعى الأصول المرعية — بألا يزيد على القدر الواجب.

3 **الشرط الثالث:** أن يرد المستأجر نفقات تدخل المؤجر.

− الإلتزام الرابع ← المحافظة على العين:

م 583: (1) "يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد،" (2) "وهو مسؤول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالاً مألوفاً،"

م 1/211: "في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، وفي كل حالة يبقى المدين مسؤولاً عما يأتيه من غش أو خطأ،"

الترميمات التأجيرية – م 582: "يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية التي يقضي بها العرف، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك،" (مثل: إصلاح النوافذ والأبواب وألواح الزجاج والأقفال والمفاتيح،) ويرجع في تحديدها إلى العرف.

مسؤولية الحريق – م 584: (1) "المستأجر مسؤول عن حريق العين المؤجرة، إلا إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه،" (2) "فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد كان كل منهم مسؤولاً عن الحريق بنسبة الجزء الذي يشغله، ويتناول ذلك المؤجر إن كان مقيماً في العقار، هذا ما لم يثبت أن النار ابتداء شبوبها في الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسؤولاً عن الحريق،"

الطبيعة: مسؤولية عقدية عن أي عين ولو كانت منقولات، والالتزام بتحقيق غاية لا بذل عناية — فلا يتخلص بإثبات عناية المعتاد، بل بإثبات السبب الأجنبي، ويجوز إثباته بكافة الطرق — بما في ذلك محاضر البوليس أو النيابة أو المحكمة.

1 **العقارات بالتخصيص:** يدفع قيمة العقارات بالتخصيص التي احترقت مع العقار.

MARA 01105405478

2 **المنقولات غير المشمولة:** لا يدفع قيمة المنقولات التي تركها المؤجر في العين دون أن يشملها الإيجار أو أودعها الغير فيها — أضرار غير متوقعة، لا مسؤولية عنها إلا بالتقصيرية أو بالعقدية عند العمد أو الخطأ الجسيم.

3 **إعادة البناء:** لا يجبر على إعادة البناء بنفسه — بل يكتفي بالحكم بالنفقات، إلا إذا طلب هو القيام بذلك (حتى لو أثبت المؤجر خطأً في جانبه، أو شُرط رد العين على حالتها).

4 **الأجرة الفائتة:** يدفع الأجرة الفائتة في المدة اللازمة لإعادة العين إلى أصلها، وكذلك عن المدة التي تبقى فيها العين خالية بعد الإعادة إلى أن تؤجر.

الإلتزام الخامس ← رد العين:

م 590: "يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزماً أن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر." ويلزم برد العين كاملة — فإن حصل عجز في المساحة أو المقدار كان مسؤولاً عنه ما لم يثبت السبب الأجنبي أو عدم خطئه.

م 1/591: "على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه،" فإن كان التسليم بمحضر استلام فالتحقق ميسور؛ أما بدونه فيفترض — حتى يقوم الدليل على العكس — أن المستأجر تسلمها في حالة حسنة.

الجزاء: للمؤجر التنفيذ العيني أو التعويض، ولا يتصور الفسخ — لأن الرد لا يكون إلا عند انتهاء الإيجار، فلا معنى للفسخ.

حكم التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن:

القاعدة – م 593: "للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن، وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك،" فإن وُجد شرط مانع وجب إعماله.

الاستثناء – م 2/594: "ومع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر، واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق."

NARA 01054054178

الشرط	المضمون
١- وجود متجر	مملوك لشخص، مقام على عقار مملوك لآخر، ومالكه مستأجر للعقار وممنوع من الإيجار من الباطن أو التنازل.
٢- ضرورة تقتضي البيع	العجز عن العمل، الموت، عدم استطاعة الورثة الإدارة، إفلاس المالك (فيتنازل السنديك للمشتري)، تقدير الضرورة لقاضي الموضوع.
٣- ضمان كافٍ للمؤجر	زيادة على المنقولات (التي عليها امتياز وغالباً معدة للبيع فلا تكفي) — كرهن أو كفالة.
٤- عدم لحوق ضرر محقق	كأن يكون المشتري سيئ السمعة بخلاف المستأجر الذي روعيت فيه اعتبارات شخصية، عبء الإثبات على المؤجر، والقاضي يقدر.

م 1/594: "منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار، وكذلك العكس،" (بخلاف فرنسا: يجب تنفيذ الشرط المانع بدقة،) والسبب: المتعاقدان لا يدركان عادة الفرق — فيفترض قصدهما منع العملين معاً. **المذكرة الإيضاحية** : "فإذا وجد الشرط المانع من التنازل، فإنه يقتضي المنع من الإيجار من الباطن، وكذلك العكس، وليس هناك ما يمنع من ظهور نية صريحة في المنع من أحد الشيئين دون الآخر."

أسباب انتهاء عقد الإيجار:

١ انتهاء الإيجار بانقضاء مدته

٢ انتهاء الإيجار بانتقال ملكية العين

الفصل الأول: انتهاء الإيجار بانقضاء مدته:

المغتصب: إذا انقضت المدة وبقي المستأجر دون رضاء المؤجر فلا يعد مستأجراً بل **مغتصباً** — لا سند له، ويجوز الحكم عليه بالإخلاء والتعويض (عادة أجرة المثل عن مدة البقاء بعد الانتهاء).

وجوب التنبيه: إن اشترط المتعاقدان التنبيه بالإخلاء وجب — وهو الغالب في عقود الإيجار، فإذا لم يحصل أصلاً أو حصل بعد فوات الأجل المحدد، امتد الإيجار إلى المدة الأخرى التي حددها

المتعاقدان ولا يتجدد.

1. **من يصدره:** المؤجر أو المستأجر، أو من ينوب عنهما (وكيل، ولي، وصي، قيم)، أو من يحل محلهما (خلف عام كالورثة؛ خلف خاص كمشتري العين بالنسبة للمؤجر، والمتنازل له عن الإيجار بالنسبة للمستأجر).
2. **لمن يوجه:** الطرف الآخر أو من يمثله، أو الخلف العام أو الخاص.
3. **شكله:** لا شكل خاص — إنذار على يد محضر، كتاب مسجل، كتاب عادي، شفوي، وعبء الإثبات على من صدر منه.
4. **مشتملاته:** بيانات من صدر ولمن صدر، تحديد عقد الإيجار المراد إنهاؤه، وإفصاح صريح عن إرادة الإخلاء.

الميعاد – م 563: (1) أراضٍ زراعية وبور: الفترة ستة أشهر أو أكثر — ثلاثة أشهر قبل انتهائها؛ وإذا كانت أقل: قبل نصفها الأخير — مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف، (2) منازل وحوانيت ومكاتب ومتاجر ومصانع ومخازن وما إليها: الفترة أربعة أشهر أو أكثر — شهرين قبل انتهائها؛ وإذا كانت أقل: قبل نصفها الأخير، (3) مساكن وغرف مؤثثة وأي شيء غير ما تقدم: الفترة شهرين أو أكثر — شهر قبل نهايتها؛ وإذا كانت أقل: قبل نصفها الأخير.

الجزاء: التنبيه بعد الميعاد **باطل** — ويتمسك ببطلانه كل من المتعاقدين، فإذا صدر من المؤجر بعد الميعاد وأراد التمسك به وطلب الإخلاء، فللمستأجر أن يتمسك ببطلانه — ولو كان صادراً منه — وله البقاء محتجاً بامتداد الإيجار.

الفصل الثاني: انتهاء الإيجار بانتقال ملكية العين:

القاعدة: ينتهي ببيع العين — ولو لم يذكر في العقد — بموجب قواعد الاشتراط لمصلحة الغير، ويجب على المشتري تنبيه المستأجر بالإخلاء في المواعيد المقررة في **م 563** .

الاستثناء: إذا كان المشتري هو المستأجر، ينتهي الإيجار بمجرد البيع — سواء كان ثابت التاريخ أو لا، متقدماً أو لا؛ لأن المستأجر حل محل المؤجر فاجتمعت فيه الصفتان، فينقضي الالتزام باتحاد الذمة.

م 146: "إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته، وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه،" فإذا اعتبرنا الالتزامات والحقوق من مستلزمات العين انتقلت معها إلى الخلف، وصار الإيجار نافذاً في حقه، وحل محل المؤجر في مواجهة المستأجر.

م 1/604: "إذا ما انتقلت ملكية العين المؤجرة اختياراً أو جبراً إلى شخص آخر، فلا يكون الإيجار نافذاً في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية،"

الشرط	المضمون
١- وجود خلف خاص	من يتلقى من سلفه ملكية شيء معين بالذات أو حقاً عينياً فيه.
٢- عقد في شأن الشيء المستخلف فيه	أنشأ التزامات وحقوقاً تعتبر من مستلزماته.
٣- أن يكون مبرماً قبل انتقال الشيء	أي ثابت التاريخ وسابق على التصرف الناقل.
٤- علم الخلف بالالتزامات والحقوق	وقت انتقالها.

MARA 01105405478

العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

• المذكـرة الأساسيـة •

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

- تأصيل تحليلي
- تطبيقات قضائية
- صياغة أكاديمية

مـدنـي (عقد التأمين)

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثالثة

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

عقد التأمين:

المحاور الآتية

النشأة	الأسس الفنية للتأمين	أركان التأمين
الأحكام العامة للتأمين	آثار عقد التأمين	

التأمين قديماً: نشأ التأمين بحثاً عن الأمان أمام الخطر، تحصناً من نتائجه الضارة وحصراً لها في أضيق نطاق، وكان قديماً مضاربة وضرراً محضاً: يتفق شخصان على تأمين آثار حادث معين مقابل مبلغ، فإن تحقق دفع الأول للثاني وخسر، وإن لم يتحقق احتفظ بما أخذ.

التأمين الإحصائي (حديثاً): لم يعد مضاربة، بل عملية منظمة على أسس علمية بحتة

إذ تستطيع شركة التأمين بأسس الإحصاء وقانون الأعداد معرفة عدد الحوادث التي ستقع فعلاً، ومقدار الضرر، ومقدار التعويض الذي يتحمله في كل عقد، بما يحقق التعاون بين المستأمنين ويوزع عبء الخطر بينهم، ويمنع أي احتمال للخسارة أو الإثراء، فاختفت المغامرة وحلت الأسس الفنية المنظمة، لكن استقرار التأمين بهذا المعنى لم يتم مرة واحدة، بل كان وليد تطور كبير في كل فرع على حدة حتى استقرت قواعده المعروفة الآن.

فوائد التأمين:

تكوين رؤوس الأموال: تتجمع من الأقساط مبالغ ضخمة، تُدفع منها مبالغ التأمين عند الكوارث، ويُحتفظ بجزء احتياطياً، ويُستغل الباقي في تمويل مشروعات للأفراد والدولة، وهذا يطمئن المؤمن لهم على حصولهم على مبالغ التأمين، ويزيد فرص الاستثمار بما ينهض بالاقتصاد القومي.

زيادة فرص الائتمان: وسيلة ائتمانية يقدمها المدين ضماناً لقروضه؛ فوثيقة التأمين ترهن بشروط خاصة، وتتيح للمؤمن له طلب قرض من المؤمن يخصم من مبالغ التأمين المستحقة، كما أن مبلغ التأمين يحل محل الشيء المؤمن عليه مما يضمن للدائن سداد حقوقه.

بث الطمأنينة والأمان: المخاطر والكوارث تشعر الإنسان بالقلق والتردد، فإذا أيقن أنه سيحصل على تعويض يجبر الضرر ويخفف الأثر، عادت الطمأنينة إليه، وأقدم على مشروعاته آمناً على نفسه وماله، فتزيد كفاءته الإنتاجية ويتسع نطاق معاملاته، ما يزيد الإنتاج الفردي والقومي.

ملامح قانونية واقتصادية: ولأهميته جعلته بعض الدول جبرياً في أحوال معينة مثل العمل وجرت شركات التأمين على إعادة التأمين مع شركات أخرى على جزء من المخاطر، فتتوزع وتخفف آثارها ويوجد توازن بينهما في تحمل الكوارث ويزيد الأمان لديهما.

محاور الفصل الأول:

١ نشأة التأمين وتطوره (عالمياً ومصرياً)
٢ الأسس الفنية وتعريف التأمين
٣ وظائف عقد التأمين
٤ التقسيمات المختلفة للتأمين

١ المبحث الأول: نشأة التأمين وتطوره:

الخلاف في النشأة: يرى عدد كبير من فقهاء القانون الفرنسي والمصري أن التأمين نظام حديث نسبياً، وأن العصور البدائية لم تعرفه؛ لأنه ليس من وضع المشرع، بل نتيجة تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للتجارة، وخاصة البحرية، التي أدت للحاجة إلى تأمين النقل البحري.

العصور البدائية: إلا أن العصور البدائية لم تخل من صور يمكن إدراجها في مضمون فكرة التأمين الحديثة، حيث قصرت تغطية المخاطر الناتجة من نشاط معين: ما ورد في التلمود من جمع أموال مشتركة لتعويض ثمن المواشي الهالكة أو السفن الغارقة، **لكن الفقه لا يدرجها في التأمين بمعنى الفني المنظم — القائم على تعاون المستأمنين لتغطية آثار خطر معين — وإنما هي صور من المضاربة والرهان** .

العصور الوسطى وظهور فكرة التبادل:

التبادل والإقطاع: لم يعرف العصر الوسيط التأمين كعملية منظمة فنية، لكن تطوره أدى إلى ظهور فكرة التبادل، وهي من الأسس الجوهرية في عملية التأمين، وقد تسببت في ظهور علاقات الإقطاع التي استلزمت تجمع صغار المزارعين حول كبار الملاك من الإقطاعيين والنبلاء.

الرصيد المشترك: وكان الغرض تكوين رصيد مشترك باشتراك يدفعه كل عضو، يُخصص لتعويض من تلحقه الكوارث: الوفاة، تلف المحصول، موت الماشية.

نهاية العصور الوسطى: ومع تقسيم الإقطاعيات الكبيرة إلى قطع صغيرة، وظهور صغار الملاك الزراعيين وحاجتهم لأمان يحميهم من المخاطر، وازدهار التجارة المتبادلة بين المقاطعات وخاصة البحرية، تهيأت الظروف لظهور فكرة التأمين الحقيقي.

ظهور التأمين البحري:

أول صورة فنية: لا شك أن التأمين البحري كان أول صورة ظهرت للتأمين بالمعنى الفني الصحيح، وقد سبقه عقد القرض البحري: يتعهد فيه شخص بإقراض صاحب السفينة مبلغاً لتجهيزها وشحن البضاعة، فإن غرقت لا يستوفي الدائن دينه، وإن وصلت سالمة رد المدين المبلغ مع فوائد باهظة مقابل مخاطرة الدائن، لكن تم تحريم هذه الفائدة فظهر...

عقد بيع معلق على شرط فاسخ: فظهر عقد جديد يحمل كل خصائص التأمين الحقيقية ما عدا الاسم: "عقد بيع معلق على شرط فاسخ"، بمقتضاه يتفق الشخص على شراء السفينة وما عليها من بضاعة وسائر الأشياء المؤمن عليها بثمن معلوم يدفعه المشتري "المؤمن" إذا لم تصل الشحنة، ويوضع شرط فاسخ يكون العقد بموجبه مفسوخاً إذا وصلت السفينة سالمة لميناء الوصول، مع تعهد صاحب السفينة "المستأمن" بدفع مبلغ معين للمشتري مقابل هذه المخاطر.

خصائص التأمين الأساسية: والعقد في هذه الصورة يحمل كافة خصائص التأمين الأساسية: **المشتري "المؤمن" يتعهد بدفع ثمن البضاعة والسفينة إذا غرقت، والبائع "المستأمن" بدفع مبلغ معين مقابل تحمل المخاطر** .

ظهور التأمين البري:

النشأة التابعة: ظهر متأخراً بعد البحري، أولاً في إنجلترا في القرن السابع عشر، في صورة عملية تابعة للتأمين البحري؛ إذ كانت شركات التأمين البري تؤمن على نقل البضائع بحراً، فتشمل عملية التأمين بعض مراحل النقل براً — كرفع البضاعة في الميناء على السفينة وتفريغها، وأحياناً نقلها براً وتوصيلها للمرسل إليه.

الاستقلال: لكن هذه العمليات كانت ثانوية وتابعة للعملية الأساسية (تأمين مخاطر النقل البحري)، وفي خلال القرن السابع عشر بدأت صوره في الظهور مستقلة، ومن أهمها:

التأمين ضد الحريق: أول صورة ظهرت من التأمين البري، عقب حريق هائل في لندن عام 1666 التهم أكثر من ثلاثة عشر ألف منزل ونحو مائة كنيسة، ولم توجد وسيلة لعلاج آثاره أو تعويض خسائره،

❶ فبعد عام واحد أنشأت لندن مكتباً للحريق ثم شركة كبيرة للتأمين ضد الحريق كتبت وثيقة التأمين العادية لمدة سبع سنوات،

❷ ولم تكن تعوض الخسارة كلية، بل تترك بعضها على عاتق المستأمن،

❸ ثم انتشر في القرن الثامن عشر في كثير من البلدان غير إنجلترا، وبخاصة فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية،

❹ ولعل أول شركة حقيقية أنشأت لتأمين مخاطر الحريق على الأسس الفنية كانت عام 1750 تحت اسم "الغرفة العامة للتأمين" في باريس، ثم امتد نشاطها فأصبحت تؤمن كافة الأضرار التي تصيب المنازل من الحريق،

❺ وكان التأمين في هذا الوقت يقتصر على العقارات دون المنقولات، لسهولة إخفائها والتحايل لقبض مبلغ التأمين، ثم تطور وشمل المنقولات أيضاً.

التأمين على الحياة: ظهر في القرن التاسع عشر، بسبب الهجوم الذي وجه إليه أكثر من غيره، ولكنه ما لبث أن تغلب على كل معارضة، واتخذ في ظهوره صورتين قائمتين على الضرر والمضاربة:

❶ اتفاقيات المقامرة: صورة من التأمين على حياة البحارة وتجار البحر ضد مخاطر النقل البحري، لا تستند لأي أساس فني وإنما مقامرة قد تؤدي للكسب أو الخسارة،

❷ الاتفاقيات التونتية: تبرم جماعة اتفاقاً يدفع كل منهم اشتراكاً سنوياً طول حياته، ومن يتوفى يؤول نصيبه إلى سائر الشركاء الأحياء، ويوزع الناتج بينهم، والهدف ليس التأمين على الحياة، إنما المضاربة لتحقيق الأرباح والمكاسب، **وهذه الصورة هي السبب في تحريم التأمين على الحياة في هذه الفترة** .

التأمين من المسئولية: ظهر بفعل تطور وسائل الحياة الحديثة وانتشار السيارات والآلات الميكانيكية والثورة الصناعية، مما أدى لزيادة نشاط الإنسان وتوسعه، وصاحبه تعدد الحوادث وكثرة حالات المسئولية عن تعويض الغير بما حققه من ضرر،

صور أخرى للتأمين: شهدت بداية القرن العشرين صوراً حديثة أهمها: التأمين من السرقة والتبديد، ومن تلف المزروعات والآلات الميكانيكية، ومن موت المواشي، ومن الإصابات، ومن أخطار الحروب، ومن حوادث النقل الجوي، ومن المسئولية عن مزاولة المهنة (كمسئولية الطبيب والجراح والمهندس)، ومن المسئولية عن الغير، ومن استهلاك السندات وتأمين الدين.

التأمينات الاجتماعية: وظهرت صور متنوعة من التأمينات الاجتماعية تتولاها الدولة دون الشركات الخاصة والنشاط الحر: تأمين العمال من إصابات العمل والمرض والعجز والشيخوخة والوفاة، وبجانبه التأمين الإجباري من إصابات العمل وحوادث السيارات، ولم ينته منتصف القرن العشرين إلا وتدخلت الدولة في مجال التأمين، فأنشأت شركات التأمين ضماناً لبسط السيطرة والرقابة على مختلف قطاعاته.

تطور التأمين في مصر:

البداية التاريخية: تطور التأمين في مصر مساير لتطوره بصفة عامة، فالتأمين البحري كان أول صورة منظمة، وجاء منظماً في القانون التجاري البحري في المواد من 173 إلى 234، بينما كانت المجموعتان المدنيتان القديمتان المختلطة والأهلية خاليتين من أي إشارة للتأمين البري، ولم يرد عقد التأمين ضمن العقود المسماه في القانون المدني المصري.

التنظيم التشريعي: ولكن بعد انتشاره من أواخر القرن التاسع عشر وكثرة عقوده وتعدد الهيئات القائمة به، بدأ التنظيم القانوني يلقى اهتماماً من المشرع، بدءاً بتنظيم العقد وصولاً للتأمين الكامل للهيئات وإخضاعها لسيطرة الدولة المباشرة، عبر خطوات:

MARA 01054054178

1. **القانون رقم 92 لسنة 1939:** للإشراف والرقابة على هيئات التأمين، أفادت مذكرته الإيضاحية أنه يهدف إلى:

❶ وضع نظام لمراقبة هيئات التأمين أسوة بسائر الدول، لحماية الادخار القومي وصيانة أموال صغار المدخرين،

❷ ضمان قدرة الهيئات على الوفاء بالتزامها نحو المستأمنين واستبعاد غير الجدية، ولتحقيق ذلك استلزم إيداع كل هيئة تأمين كفالة في أحد بنوك مصر قيمتها عشرة آلاف جنيه عن كل قسم من أقسام التأمين بالشركة،

❸ ضمان اتباع نظام حسابي صحيح على أسس فنية محددة،

❹ منع الهيئات من المضاربة في استثمار أموالها للربح حتى لا تتعرض حقوق المستأمنين للضياع.

2. **القانون رقم 86 لسنة 1942:** الذي جعل التأمين عن حوادث العمل إجبارياً، فألزم كل صاحب عمل بالتأمين على حوادث العمل التي يلتزم بالتعويض عنها طبقاً للقانون رقم 64 لسنة 1936 بشأن إصابات العمل.

3. **القانون رقم 156 لسنة 1950:** لتحقيق الرقابة عبر عدة إجراءات أهمها:

❶ المادة 1 أنشأت مصلحة خاصة بالإشراف والرقابة تابعة لوزارة المالية (مصلحة التأمين) لتتولى كافة شئون التأمين المالية والإدارية والفنية،

❷ المادة 10 بينت إجراءات تسجيل الهيئات بطريقة فعالة تسمح للدولة برفض تسجيل غير المستوفية للشروط والالتزامات لحماية المستأمنين،

❸ المادة 7 ألزمت الهيئة القائمة بالتأمين أن تتخذ شكل شركة مساهمة لا يقل رأسمالها المدفوع وقت التسجيل عن خمسين ألف جنيه، لضمان مركزها المالي وقدرتها على الوفاء بالتزامها عند تحقق الخطر،

- وقد رفع قانون 1950 القيمة التي ألزم بها قانون 1939 شركات التأمين على الحياة (الاحتفاظ بنسبة 60% من احتياطي العقود)، فألزمها بالاحتفاظ في مصر باحتياطي كامل لا يقل عن عشرة آلاف جنيه عن كل قسم، بالإضافة لبعض الالتزامات المالية الأخرى لمختلف هيئات التأمين.

4 **تشريعات وقرارات الخمسينيات:** عدة تشريعات وقرارات لبسط المزيد من سيطرة الدولة المباشرة، أهمها القانون رقم 23 لسنة 1957 بتأميم شركات التأمين، ثم القرار الجمهوري بالقانون رقم 195 لسنة 1959 الشامل للإشراف على جميع هيئات التأمين والادخار وتكوين الأموال، حيث أخضع للرقابة جميع الهيئات التي تقوم بالتأمين ومن بينها هيئات إعادة التأمين، وذكر الشروط التفصيلية في هيئات التأمين وإجراءات تسجيلها والتزاماتها.

5 **القانون رقم 60 لسنة 1963:** الخطوة الخامسة والأخيرة لتنظيم عمل المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي التي تمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً أو زراعياً أو مالياً أو تعاونياً، وتدخل فيها المؤسسة المصرية العامة للتأمين.

3 المبحث الثاني: أصول فن التأمين وتعريفه:

◆ **فكرة التأمين:** تقوم على جانبين مترابطين:

الجانب القانوني: العلاقة بين المستأمن والمؤمن، وتقوم على وجود خطر أو حادث يخشى وقوعه لشخص معين (المستأمن)، فيسعى لتأمين نفسه منه فيتعاقد مع آخر (المؤمن، وعادة شركة تأمين) يغطي الخطر ويعوض المستأمن نظير قسط معين.

الجانب الفني: الأسس التي يستند إليها المؤمن في تغطية الخطر، فالشركة عندما تعوض المستأمن عند وقوع الخطر لا تفعل ذلك على وجه المضاربة — وإلا لأصبح التأمين مقامرة أو رهاناً وكان عقداً غير مشروع — وإنما تتعاقد مع عدد كبير من المستأمنين تتقاضى من كل منهم قسطاً، بحيث عند وقوع الخطر لأحدهم تعوضه من مجموع الأقساط التي تقاضتها من سائرهم، وتستعين عند تقدير القسط بقوانين الإحصاء الدقيقة بحيث تحدده تحديداً لا يعرضها للخسارة أو الخطر الجسيم.

تعريف عقد التأمين: عرفه المشرع بأنه: **"عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه، مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن."**

مميزات التعريف: يمتاز بأنه يبين العناصر القانونية الأساسية: أطراف العقد (المؤمن، المؤمن له، المستفيد)، وفكرة الخطر الذي يلتزم المؤمن بتغطيته، والتزام المؤمن له بدفع

الأقساط، كما يمتاز بأنه لم يعرف التأمين بأنه يستهدف التعويض عن خسارة احتمالية، فجاء سليماً؛ لأنه يصدق على التأمين على الأشخاص والتأمين من الأضرار على السواء.

المآخذ عليه: يؤخذ عليه أنه لم يتعرض إلا لأحد الجانبين — القانوني — دون الفني، مع أن التأمين لا يتصور وجوده إلا في ظل خلفية فنية هامة، وأهميته ترجع إلى الأساس الفني الذي يقوم عليه، ولهذا يجب أن يوضح التعريف فن التأمين إلى جانب الفكرة التعاقدية.

التعريف الشامل: فالتأمين هو عملية يحمل بمقتضاها أحد الطرفين — المؤمن له — نظير دفع مبلغ معين (القسط) على تعهد لصالحه أو للغير في حالة تحقق خطر معين من الطرف الآخر — المؤمن — الذي يتحمل على عاتقه مجموعة من المخاطر يجرى المقاصة بينها وفقاً لقوانين الإحصاء.

وظائف عقد التأمين:

بجانب الوظيفة الظاهرة (تغطية الخطر) توجد وظائف أخرى:

وسيلة من وسائل الائتمان: يكفل للمؤمن له الأمان من المخاطر، خاصة بعد أن أصبحت الحياة المعاصرة مليئة بالأخطار من جراء تقدم الحضارة وما صاحبه من انتشار الآلات الميكانيكية والسيارات ووسائل النقل البرية والبحرية والجوية والمصانع والعمارات الضخمة والحرائق المتعددة والمتنوعة، مما جعل الناس يعمدون إلى التأمين ليكفل لهم الأمن ويقيهم شر الأخطار.

وسيلة لتكوين رؤوس الأموال: التأمين على الحياة في أغلب صوره وسيلة ادخار، يستطيع المؤمن له عن طريقه ادخار القليل شيئاً فشيئاً بأقساط التأمين، فإذا به عند نهاية التأمين يملك رأس مال يعتد به لم يكن يستطيع ادخاره بغيره.

وسيلة لدعم الاقتصاد القومي: أثره لا يقتصر على المؤمن له بل يمتد للاقتصاد القومي؛ فشركات التأمين تجمع أقساطاً فتتكون لديها ثروات ضخمة توجه للاقتصاد القومي في شتى المجالات، باستثمارها في المشروعات العامة أو وضعها في سندات قروض تطرحها الدولة في الأسواق.

عامل من عوامل تقليل وقوع الحوادث: إلى جانب دوره المباشر في التعويض، يلعب دوراً غير مباشر في تقليل نسبة الحوادث والحد من المخاطر، فأصبح عاملاً من عوامل الوقاية، ويتحقق ذلك من ناحيتين:

أثره في المجال الدولي وفي تطهير القانون: التأمين بطبيعته نظام دولي، إذ أن المخاطر التي يغطيها متشابهة في معظم الدول، وبعضها لا يمكن وضع حد جغرافي له كالنقل والشحن، كذلك يرجع له الفضل في تطوير كثير من نظم القانون الخاص وإيضاح معالمها.

أقسام ← عقد التأمين:

1 التأمين التعاوني والتأمين بقسط ثابت:

التأمين التعاوني: تتفق فيه مجموعة من الأشخاص على تعويض الأضرار التي تلحق أحدهم إذا تحقق خطر معين، ويتميز بما يأتي:

1. **نفس الأشخاص:** يقوم نفس الأشخاص بدور المؤمن والمؤمن لهم.
2. **الاشتراك المتغير:** يدفع كل عضو اشتراكاً يتغير بتغير تغطية الحوادث خلال السنة، فيزيد بزيادتها أو ينقص بنقصها، وقد يحصل المستأمن على عوض جزء من الأضرار إذا أعسر أحد المشتركين أو كان ما دفعه كل عضو لا يكفي لتغطية الأضرار، وقد يتفق على أن يزيد كل عضو اشتراكه للحد الذي يغطي الأضرار أو يدفع اشتراكاً أكبر يفيض جزء منه احتياطياً لحالات الأعصار أو ازدياد المخاطر، وفي حالة زيادة الأقساط في النهاية عن مبالغ التأمين يكون للأعضاء الحق في استردادها وفقاً لإتفاق.

التأمين بقسط ثابت: تتفق فيه شركة مع عملائها على تعويضهم عن الأضرار التي تلحق أحدهم عند تحقق خطر نظير دفع كل منهم قسطاً ثابتاً يحدد مقداره وقت العقد، ويتميز بـ:

← يدفع كل عميل مبلغاً ثابتاً، وتتولى الشركة دفع مبلغ التأمين المتفق عليه عند وقوع الخطر، سواء كان المبلغ المدفوع يساويه أم يقل عنه أو يزيد عليه، والشركة تسعى للربح ويتحقق لها إذا قلت مبالغ التأمين عن مجموع الأقساط، والربح من حق الشركة لا من حق المستأمنين بخلاف التأمين التعاوني.

2 التأمين الإجتماعي والتأمين الفردي:

التأمين الاجتماعي: تأمين من يعيشون على كسب عملهم من الأخطار التي قد تحول بينهم وبين أدائه، كالتأمين ضد المرض والعجز والشيخوخة والبطالة كما في قانون التأمينات الاجتماعية، ويتميز بالآتي:

1. غالباً ما يكون إجبارياً، تفرضه الدولة فلا يكون اختيارياً،
2. يقوم على فترة التضامن الاجتماعي،
3. يدفع المؤمن جزءاً من القسط، وتتولى الدولة أو صاحب العمل دفع الجزء الباقي،
4. تقوم الدولة بالإشراف الكامل عليه عبر المؤسسات (كمؤسسة التأمينات الاجتماعية) أو المصالح (كمصلحة الضمان الاجتماعي)، على أن تتحمل الحكومة مبالغ التأمين إذا زادت عن الأقساط المدفوعة.

التأمين الفردي (الخاص): يعقده شخص ليستفيد به شخصياً في تأمين نفسه من خطر معين، ويتميز بالآتي:

1. يدفع المستأمن قسط التأمين كله،
2. لا يخضع لإشراف الحكومة، وإنما تقوم به شركات على أسس فنية وإحصائية يوازن بها المؤمن بين مجموع الأقساط ومجموع مبالغ التأمين المحتمل دفعها،
3. يقوم على أساس الدافع الشخصي،
4. غالباً ما يكون اختيارياً فيقوم على سلطة الإرادة، ومع ذلك قد يفرضه القانون كما في تأمين أصحاب السيارات من المسئولية عن حوادث السيارات، وتأمين أصحاب الأعمال من المسئولية عن حوادث وإصابات العمل.

3 التأمين البحري والنهري والبري والجوي:

البحري: يغطي مخاطر النقل في البحار بالنسبة للسفن وحمولتها من البضائع، وهو تأمين على الأشياء، فلا يشمل تأمين الأشخاص المعرضين لمخاطر البحر في السفينة.

النهري: يطبق عليه عادة قواعد التأمين البحري، ويغطي مخاطر النقل في الأنهار والترع العامة بالنسبة للسفينة أو حمولتها.

البري: يغطي المخاطر في البر.

الجوي: يغطي المخاطر بالنسبة للطائرة أو حمولتها من البضائع.

MARA 01105405478

4 تأمين الأشخاص وتأمين الأضرار:

تأمين الأشخاص: دفع مبلغ من المال إذا تعرض الإنسان لخطر في شخصه، وهو نوعان:

1. **التأمين على الحياة:** دفع مبلغ عند الموت (تأمين لحالة الوفاة)، أو عند البقاء على الحياة بعد سن معينة (تأمين لحالة البقاء)، وقد يكون مختلطاً (لحال الموت والبقاء معاً)، كأن يؤمن الشخص في حياته لمدة ثلاثين عاماً على أن يؤول مبلغ التأمين لمستفيد آخر إذا مات قبل ذلك، وقد يكون المستأمن الذي يلتزم بدفع الأقساط غير المؤمن على حياته وغير المستفيد، كأن يؤمن على حياة ابنه أو زوجته، وقد تتولى عقد التأمين هيئة أو مؤسسة أو نقابة لصالح أعضائها، وهنا يكون التأمين جماعياً.
2. **التأمين من الإصابات:** تأمين الأشخاص من الحوادث التي تمس سلامة أبدانهم.

ثانياً: التأمين من الأضرار: تعويض الخسارة التي تلحق ذمة الشخص المالية، وهو نوعان:

❶ تأمين الأشياء: تعويض المؤمن له عن خسارة لحقت بشيء من أمواله، والمؤمن له هنا هو ذاته المستفيد، ومن أمثلته التأمين ضد الحريق والسرقة أو الاختلاس والأعصار،

❷ تأمين المسئولية: تعويض المؤمن له عما يدفعه من تعويض عند مسئوليته عما يصيب الغير من ضرر.

ملاحظة قانونية: **والتأمين من الأضرار عقد من عقود التعويض، بخلاف التأمين على الأشخاص فليست له صفة تعويضية،** ويترتب على ذلك في التأمين على الأشياء:

❶ يقدر التعويض على حسب جسامة الضرر الناشئ عن الخطر، أي تسري قاعدة التعويض،

❷ لا يتجاوز التعويض قيمة الضرر حتى لو تعدد بتعدد عقود التأمين على نفس الخطر.

MARA 01054056478

الفصل الثاني...فن التأمين:

١ المبحث الأول: إعادة التأمين

٢ المبحث الثاني: الأسس الفنية للتأمين

١ المبحث الأول: إعادة التأمين:

التعريف: **عقد بين المؤمن الأول (المباشر) ومؤمن ثانٍ (المعيد)، يلتزم بمقتضاه المعيد بتحمل جزء من المخاطر مقابل قسط معين، مع بقاء المباشر مديناً أصلياً في مواجهة المستأمنين.**

المعنى: نظام يزيد الأمان الناتج عن عقد التأمين، ويقضي بقدر الإمكان على أي احتمال مفاجئ لوقوع الخطر، فالمؤمن يتبع أسس الإحصاء وقانون الأعداد الكثيرة لحساب الاحتمالات ومعرفة نسبة وقوع الخطر، لتحديد سعر القسط المناسب، لكنه يخشى أن تزيد قيمة الخطر على الحساب المعمول، فيلجأ إلى مؤمن آخر (المعيد) يضمن له قيمة المخاطر الزائدة مقابل قسط يتقاضاه منه.

النطاق: قد تكون لجزء من المخاطر (وهو الغالب) أو لكل المخاطر أحياناً، مع بقاء المؤمن الأول ملتزماً أمام المستأمنين.

التقسيم: تتنوع إعادة التأمين إلى الأنواع الآتية:

1. **اختيارية:** حرية كاملة للطرفين؛ لا يلتزم المباشر بالإعادة، ويستطيع المعيد الموافقة أو الرفض.
2. **إجبارية بنص القانون:** كالقانون رقم 195 الذي ألزم هيئات التأمين بإعادة التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر، على أساس نسبة معينة وطبقاً لتعريفات محددة، بالنسبة للتأمين من الأضرار.
3. **إجبارية بالاتفاق:** اتفاق عام بين المؤمن ومؤمن آخر يلتزم بموجبه الطرفان بإعادة التأمين لنوع معين، فأي وثيقة من هذا النوع تدخل تلقائياً في عمليات الإعادة، وميزتها: التلقائية في تغطية الخطر دون اتفاق جديد، والاقتصاد في النفقات، والسرعة، وتجنب المفاوضات الطويلة في كل مرة.

MNARA 01105405478

وظيفتها: تحقيق التناسق بين الأخطار، وتمكين شركة التأمين من قبول شتى المخاطر — خاصة المرتفعة القيمة كحوادث الطيران والسفن والسيارات — دون التعرض لكارثة مالية، بمساهمة شركة الإعادة في تعويض الخطر.

صـور إعادة التأمين:

1 إعادة التأمين بالمحاصة:

المضمون: يشترك المعيد مع المباشر في جميع عمليات التأمين التي يقوم بها، أو في نوع معين منها، بالنصف أو الثلث أو الربع أو أي نسبة أخرى.

مثال: اتفاق المعيد مع المباشر على ضمان 35% من عقود التأمين ضد الحريق في مدينة معينة، فيستوفي ربع الأقساط في الوثائق المبرمة ويغطي ربع التعويضات التي يدفعها المباشر.

المعنى والتطبيق: أن يكون المعيد شريكاً للمؤمن في جميع عمليات هذا النوع، سواء ما كان كبير القيمة لا يستطيع المؤمن وحده تحمل مخاطره فتكون المشاركة نافعة، أو محدود القيمة يستطيع تحملها دون مشقة فتكون المشاركة غير ذات نفع بل خسارة، إذ يشاركه في الأقساط، وهذه الصورة تكون عادة للعمليات القليلة الأهمية للشركات الحديثة النشأة.

عيبها: ارتباط المعيد بحد معين من التعويض الفعلي المدفوع عند تحقق الكارثة فعلاً — جزء الواجب الدفع أولاً.

التأمين من المسئولية: غالباً تكون في التأمين من المسئولية: يضع المؤمن حداً معيناً لكل وثيقة، فإذا تحققت المسئولية في وثيقة ورجع المؤمن بمبلغ التعويض، فإن لم يجاوز الحد تحمله كله، وإن زاد تحمل الحد وتحمل المعيد الزيادة، وتسمى "إعادة التأمين من الخطر الثاني"، ولبساطتها تمتد لفروع أخرى كالنقل والحريق.

2 إعادة التأمين فيما جاوز حداً معيناً من الخسارة:

المضمون: اتفاق المباشر مع المعيد على نسبة مئوية معينة من مجموع الأقساط التي يتقاضاها في فرع معين (كالتأمين من المسئولية والصقيع والحياة)، وبمقتضاها تتحقق الإعادة عن المخاطر خلال العام بأكمله؛ فلا يتدخل المعيد إلا إذا جاوزت مجموع التعويضات

التي يدفعها المباشر خلال العام نسبة معينة من مجموع الأقساط في هذا الفرع، فإن لم تبلغها تحملها المباشر وحده، وإن تجاوزتها تحمل المعيد الزيادة.

✅ **ميزتها:** التبسيط الشديد في الإجراءات، وعدم الحاجة لحسابات معقدة ومراسلات متصلة مستمرة؛ يكفي إخطار عام من المباشر إلى المعيد في نهاية السنة يعلمه فيه بالنتيجة النهائية للتعويضات وهل تجاوزت النسبة المتفق عليها.

❌ **عيبها:** عدم استنادها إلى أساس فني دقيق في تقدير الخطر.

➖ آثار إعادة التأمين:

1 التكييف القانوني (آراء الفقه):

1. **الرأي الأول (الوكالة):** إعادة التأمين عقد وكالة، يقوم فيه المباشر بدور الوكيل عن المعيد (الموكل) بالنسبة للقدر الزائد.

   نقده: أحكام الإعادة تختلف تماماً عن الوكالة التي لا يلتزم فيها الوكيل بأي التزام ناشئ عن العقد، بل تنصرف الالتزامات إلى ذمة الموكل مباشرة؛ بينما في الإعادة يلتزم المباشر شخصياً أمام المستأمن، ويبقى المعيد أجنبياً غير ملتزم.

2. **الرأي الثاني (الكفالة):** المعيد كفيل للمباشر أمام المستأمن؛ ومرجعه ما جرى عليه العمل في بعض وثائق الإعادة من شرط الضمان الذي يلتزم به المعيد بإيداع نقود أو أوراق مالية ضماناً لتنفيذ التزامه، وغرضه تحقيق غايتين: ضمان كافٍ للمباشر، والمساهمة في تكوين الاحتياطي بصوره المختلفة.

   نقده: المؤمن لم يبرم الإعادة لصالح المستأمن بل لصالحه شخصياً؛ ولو كان المعيد كفيلاً لكان للمستأمن حق الرجوع عليه مباشرة، بينما هو أجنبي عن العقد.

3. **الرأي الثالث (الشركة):** المباشر والمعيد شريكان؛ لأن العقد يجمع صفات عقد الشركة، إذ يقصد طرفاه الاشتراك في الأرباح والخسائر.

   نقده: لا يشتركان دائماً في تحمل الأرباح والخسائر؛ فقد يكون الربح حليف المباشر بينما يخسر المعيد، فضلاً عن أن الإعادة لا تخضع للإجراءات الشكلية التي يخضع لها عقد الشركة.

4 **الرأي الرابع (الحوالة):** نقل القدر الزائد والمطلوب الإعادة فيه عن طريق الحوالة،

نقده: بعض التشريعات استعارت لفظ الحوالة بصدد عقد الإعادة، لكن التسليم به عسير لاختلاف أحكام الكفالة والإعادة تماماً؛ فالحوالة تقتضي نقل عقد قديم فقط دون نشوء عقد جديد بجانبها، بعكس الإعادة التي عقد جديد متميز تماماً عن عقود التأمين القائمة، ولا يؤثر على الالتزامات الناشئة عنها.

الرأي المختار: **إعادة التأمين عقد تأمين بالمعنى الصحيح** ، دون رده إلى أحد أنواع التأمين المعروفة، بل صورة جديدة أدى إليها تطور التأمين وتضخم المسئولية وتضاعف قيمة المخاطر وقيام الحاجة إلى الإعادة لبعض المخاطر.

2 الأحكام القانونية:

الخصائص: يتفق مع سائر عقود التأمين في خصائصها (ملزم للجانبين، رضائي، معاوضة، وغيرها)، لكنه يتميز بمبدأين:

المبدأ الأول: حسن النية: **ثقة كاملة متبادلة تفوق أي نوع آخر من التأمين** ؛ يعتمد المعيد اعتماداً كاملاً على حسن نية المباشر في تقدير الأخطار وإدارة أعماله، ويقتضي إخطار المباشر للمعيد بجميع البيانات المتعلقة بالخطر المعاد وقت إبرام العقد، وبكل ما يستجد من ظروف تؤثر عليه فترفع قيمته أو نسبة حدوثه، فإذا كذب في إحداها بطل عقد الإعادة.

المبدأ الثاني: وحدة المصير: مصير المعيد مرتبط بالمباشر.

الالتزامات: يتفق مع سائر عقود التأمين في الالتزام بدفع القسط والتعويض، ويتميز بالآتي:

1 **قوائم التطبيق:** يلتزم المباشر بتقديمها للمعيد ليخطر فيها بكل خطر جديد يتعاقد على تغطيته حتى يحاط المعيد علماً بالتزاماته، وتمر بمرحلتين:

❶ مؤقتة عند إبرام أي عقد جديد تتضمن بيانات موجزة عن الخطر، وسعر القسط،

❷ نهائية تتضمن بيانات تفصيلية عن الخطر المؤمن ومقداره ومقدار الجزء المعاد الذي سيتحمله المعيد، حتى تكون لديه فكرة كاملة عن الخطر ومدى التزاماته.

MUARA 01054054178

2 **الوديعة:** يلتزم المعيد بترك وديعة تحت يد المباشر ضماناً لالتزاماته الناشئة عن الإعادة، وهي تخصيص مبالغ معينة تحت تصرف المباشر كاحتياطي لدفع التعويضات الداخلة ضمن القدر المعاد التأمين عليه، وقد تكون **نقدية** (استبقاء أقساط إعادة التأمين تحت يد المؤمن بوصفها ديناً نقدياً)، أو **شراء بعض القيم المنقولة** بأقساط التأمين تودع في مصرف باسم المؤمن ولحسابه حتى يسدد منها التعويضات المستحقة.

3 **العمولة:** يلتزم المعيد بدفع عمولة للمباشر تحدد بنسبة مئوية من أقساط التأمين، تعويضاً عن النفقات المختلفة في إدارة أعماله وجلب العقود وسائر المصروفات الإدارية المترتبة على نشاطه، ويشارك المباشر أيضاً في جزء من الأرباح التي يجنيها من وراء عملية الإعادة.

4 **الإفلاس:** تشتمل عقود الإعادة على شروط حماية، وتختلف الأحكام حسب من وقع منه الإفلاس.

إفلاس المعيد: تشتمل عقود الإعادة على شروط حماية المباشر، وأهمها حقه في طلب فسخ العقد، والاحتفاظ بالنقود والقيم المنقولة المودعة لديه على سبيل الضمان حتى يستوفي حقوقه منها.

إفلاس المباشر: قد يقال لا يلحق المعيد ضرر، فلا يحق له طلب فسخ الإعادة، خاصة وأن وثائق الإعادة لا تشتمل على إعطائه حق الفسخ، وإن كان البعض يتصور إمكان لحوق ضرر به؛ لأنه سيلتزم بالتزاماته كاملة (دفع التعويض) مع حرمانه من القسط لإفلاس المباشر، وأياً كان الأمر، فحق المستأمنين لا يضيع، ويحق لهم التنفيذ على القيمة المنقولة، سواء كانت ملكاً للمباشر (ينفذون على ملك مدينهم) أو للمعيد (لأنها مرهونة لمدينهم المباشر).

2 المبحث الثاني: الأسس الفنية للتأمين:

التمهيد: يرتكز الجانب الفني على ثلاثة أسس: التبادل أو التعاون بين المستأمنين، والمقاصة بين المخاطر، والاستعانة بأسس وقوانين الإحصاء.

– أولاً: التبادل أو التعاون بين المستأمنين:

تعريفه: لا يقوم التأمين على الصدفة البحتة؛ فالمؤمن لا يبرم العقد مضاربة أو مقامرة فيربح إذا لم يقع الخطر أو يخسر إذا وقع، وإنما يستند إلى عملية منظمة تعاونية تقوم على

تقاضي أقساط عديدة من أشخاص مختلفة، ثم تعويض من تلحقه الخسارة منهم من هذه الأقساط، ولا يلعب المؤمن إلا دور المنظم.

جوهر التعاون: **تجمع مجموعة من الأشخاص تتعرض لمخاطر من طبيعة واحدة أو متشابهة** ، بقصد تغطيتها وحمايتهم منها على سبيل التبادل، بتوزيع أضرارها عليهم جميعاً بالتساوي، فتكون آثارها السيئة أخف بكثير مما لو تحملها كل شخص وحده، وهو من المعايير الأساسية التي تميز التأمين عن غيره من العقود الاحتمالية القائمة على الصدفة البحتة؛ فلو انعدم لما كنا بصدد عقد أو عملية تأمين بالمعنى الفني، بل نظام آخر يقوم على المقامرة والرهان.

1. **في التأمين التبادلي أو التعاوني:** يظهر بأوضح مظاهره؛ فلا توجد هيئة أو شركة تمارسه، بل كل شخص مؤمن ومستأمن في آن واحد، يشترك المعرضون لمخاطر متشابهة ويدفعون مبالغ تسمى اشتراكات، تُستخدم في تعويض من تلحقه الخسارة منهم، فالتعاون ركن مميز لهذا النوع.
2. **في التأمين بأقساط محددة:** الظاهر أن التعاون ينعدم؛ فالتأمين يتم بعقد فردي بين مؤمن ومستأمن يلتزم فيه الأول بتغطية خطر معين والثاني بقسط معين، لكن الواقع خلاف ذلك؛ فالمؤمن غالباً شركة تأمين تجمع الأقساط من المعرضين لمخاطر متشابهة، ثم تجري الإحصائيات وتعتمد على قانون الأعداد الكثيرة وحساب الاحتمالات، فتكون على فكرة دقيقة عن عدد المخاطر والضرر الفعلي لكل منها، وعلى أساسها تحدد القسط الذي لا يحملها خسارة والذي يجعل المستأمنين يتحملون فيما بينهم عبء الخسارة التي تلحق بأحدهم.

صور التعاون:

❶ **شخصي:** يقوم على تعدد المستأمنين، فالتعاون والمقاصة بين عدة أشخاص،

❷ **موضوعي أو مادي:** لا يكون التبادل بين أشخاص بل بين مخاطر متعددة؛ وتقوم به الشركات الكبرى ذات النشاط الضخم كشركات النقل أو البترول، فتقدم رصيداً مشتركاً ضخماً على أساس نفس جداول الإحصاء، فلا تتم المقاصة بين أشخاص بل بين أخطار مختلفة.

NARA 01105405478

الميزة الأولى: تجزئة المخاطر: توزيع الآثار السيئة لضرر محتمل على عدد كبير من الأشخاص، فالقسط يفقد ذاتيته بمجرد دخوله الرصيد المشترك، وكل قسط عبء بسيط على كل مستأمن على حدة، لكن المؤمن بتجميعه يستطيع استخدامه في تعويض الأضرار الجسيمة التي تلحق بأي مستأمن، فتتجزأ المخاطر وتوزع نتائجها على أشخاص عدة فتفقد جسامتها وتذهب خطورتها.

الميزة الثانية: تحقيق الأمان: لكل من المؤمن والمستأمن في وقت واحد، فالمؤمن يجمع الأقساط فيستطيع دفع الخطر إذا وقع دون أن يتحمله أو تلحقه الخسارة، والمستأمن يتحقق له الأمان بضمان الحصول على التعويض عند تحقق الخطر، ويكون في مأمن من إعسار المؤمن؛ لأنه يعلم أنه يجمع لديه رصيداً مشتركاً يستطيع استخدامه في أي لحظة لتعويض من تلحقه الخسارة.

ثانياً: المقاصة بين المخاطر:

تعريفها: وسيلة يضع بها المؤمن مبدأ التعاون بين المستأمنين موضع التطبيق الفعلي، بتجميع المخاطر كل حسب طبيعته في مجموعة واحدة، وإجراء المقاصة بينها لتوزيع الأضرار التي تترتب عن بعضها على سائر المستأمنين، فالمقاصة هي المبدأ الإيجابي، وعناصرها: تجانس المخاطر وتكاثرها.

1 تجانس المخاطر:

القاعدة: لا مقاصة إلا بين مخاطر متجانسة متشابهة، حتى يمكن حساب درجة احتمال تحققها؛ أما إذا لم يوجد أي تجانس فيستحيل إجراء المقاصة، ويتحقق التجانس في:

1. **الطبيعة:** جمع المتشابه طبيعياً في طائفة؛ فتوضع عمليات التأمين على الحياة في مجموعة، والأضرار في طائفة، والمسئولية في ثالثة، لاختلاف طبيعة الخطر، وفي داخل الحياة تقسيم فرعي: الوفاة في مجموعة، والبقاء في أخرى، وفي الأضرار تتعدد الفروع حسب طبيعة الخطر (حريق، سرقة).
2. **الموضوع:** تقسيم على أساس موضوع الأشياء أو الأشخاص محل العقد؛ فالتأمين على الأشياء: العقارات في مجموعة، والمنقولات في أخرى، وفي داخل العقارات تقسيم فرعي: المبنية وغير المبنية، وحسب مادة البناء (خشب أو طوب)، وحسب الغرض (سكنى أو غيرها).

MARA 01105405478

3. **القيمة:** تقارب القيمة في كل مجموعة؛ فلا يوضع عقار قيمته ألف جنيه مع آخر قيمته عشرون ألف، وإلا لم يمكن إجراء مقاصة متساوية بينهما، فتوضع كل مجموعة متقاربة القيمة في قسم واحد تسهيلاً للمقاصة.

4. **المدة:** تقارب مدة التأمين في المجموعة؛ فكلما تقاربت المدد في فرع معين سهل على المؤمن إجراء المقاصة.

2 تكاثر المخاطر:

القاعدة: يجب أن يكون عدد المخاطر من الكثرة بحيث يكفي لتطبيق قانون الأعداد الكثيرة وعوامل الإحصاء، لاستنتاج معلومات دقيقة عن عدد الحوادث وقيمة الأضرار، فيحدد السعر المناسب للقسط الذي يواجه المخاطر ويوزع آثارها بالتساوي، فالخطر القابل للتأمين يجب أن يكون من الكثرة بحيث يمكن تطبيق الإحصائيات عليه وتحديد متوسطه ودرجة احتمال وقوعه وآثاره، أما النادر الوقوع بحيث لا يمكن توقع درجة وقوعه، فلا يمكن تطبيق الإحصاء عليه، ولا يكون قابلاً للتأمين.

ثالثاً: عوامل الإحصاء:

التمهيد: الأسس والقواعد التي يجمع بها المؤمن المخاطر بين المستأمنين ويجري المقاصة لتحديد السعر المناسب للقسط الذي يلتزم كل مستأمن بدفعه، وتستند إلى ثلاث قواعد:

1. **حساب الاحتمالات:** تحديد درجة وقوع الخطر صار سهلاً بفضل فن الإحصاء؛ لأن الاحتمالات والتوقعات تخضع لقانون يسمى قانون الصدفة، يقضي بأن كل خطر — وإن كان محتمل الوقوع وغير محدد الآثار إذا نظر إليه وحده — إلا أنه بتجميع المخاطر في أعداد كثيرة وحساب درجة احتمال وقوعها في المجموع يمكن استخلاص نسبة مئوية تحدد سعر القسط.

2. **استخدام الإحصائيات:** الإحصائية وسيلة فنية أو طريقة إجرائية تُطبق على عدد كبير من الوقائع أو الأشخاص أو الظواهر، وعن طريق فحص عددها وحالاتها ومقارنتها يمكن استخلاص نتائج أقرب ما يكون إلى الواقع، وتسمى "إحصائيات الاحتمالات"، ويقصد بها معرفة درجة احتمال وقوع الخطر في الحياة العملية وقيمة الأضرار التي يسببها، وتطبيقها على تأمين الأشخاص وتأمين الأضرار أياً كان الخطر.

MNARA 01105405478

3 **أسس الإحصاء الدقيقة:** يجب توافر عدة أسس أو خصائص حتى تكون النتائج أقرب للحقيقة، وتشمل:

الاعتماد على قانون الاستقراء: فحص أكبر قدر ممكن من الأشخاص والحوادث؛ فكلما اتسعت دائرة البحث دقت النتائج، فالمخاطر التي تبدو محكومة بالصدفة البحتة محكومة في الحقيقة بقانون متواتر (قانون الصدفة) يجعل وقوعها بانتظام محسوس وبطريقة متكررة يمكن الوصول إليها وتحديدها بمراقبة أكبر عدد من الحوادث والأشخاص.

انتشار المخاطر وتجانسها: يجب أن يرد الإحصاء الدقيق على خطر مساحة واسعة من إقليم واحد؛ وكلما اتسعت الساحة وكانت في مكان من طبيعة واحدة ضبطت النتائج، فإحصاء الوفيات أو الحريق أو السرقات في مدينة كبيرة كالقاهرة يعطي نتائج واحدة أو متشابهة كل عام، بينما تتغير النسب من حي لآخر، ويراعى في المخاطر التي تتناولها الإحصائيات أن تكون متجانسة من حيث الطبيعة والقيمة.

تواتر المخاطر: لكي تقوم الإحصائية بدورها يجب أن تكون المخاطر متواترة الوقوع في الحياة العملية بدرجة كافية تسمح بملاحظة وقوعها ومعرفة عدد مراته، أما غير المنتظمة التي لا تقع بدرجة كافية فلا تصلح أساساً للإحصاء، وبالتالي لا تصلح للتأمين، وعلى هذا: الزلازل والبراكين والأزمات الاقتصادية لا تصلح للتأمين؛ لأنها غير منتظمة الوقوع، فلا يستطيع المؤمن تطبيق أسس الإحصاء عليها ولا تحديد درجة احتمال وقوعها لتحديد القسط، فتكون غير قابلة للتأمين.

محاور الفصل الثالث:

1. الأركان الثلاثة (الخطر، القسط، مبلغ التأمين)
2. المصلحة (الركن الرابع)

تعريف المشرع (المادة 747 مدني): **"عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن،"**

الأركان الأربعة: يبين من التعريف أن الخطر ركن جوهري، يستتبع أن يدفع المؤمن له القسط، وأن يدفع المؤمن مبلغ التأمين عند تحقق الخطر، **فالأركان ثلاثة — الخطر المؤمن منه، والقسط، ومبلغ التأمين — نضيف إليها ركناً رابعاً هو المصلحة في التأمين،** وندرس الأربعة في فروع مستقلة.

1 الفرع الأول: الخطر المؤمن منه:

أهمية الخطر: الخطر أهم أركان التأمين؛ لأن الغرض من العقد دائماً تأمين شخص من خطر يتهدده، أي من حادث يحتمل وقوعه، فإذا تحقق ووقع سمي كارثة.

المدلول الواسع: غير أن للخطر والكارثة في التأمين مدلولاً أوسع من المألوف؛ فعادة يستعملان في شر يهدد شخصاً، وهذا هو المعنى الغالب (التأمين من الحريق أو السرقة أو الإصابات أو الوفاة)، لكن قد يكون الحادث المؤمن منه **سعيداً**، كما في:

1. **تأمين الأولاد:** يتقاضى المؤمن له المبلغ كلما رزق ولداً.
2. **تأمين الزواج:** يتقاضاه إذا تزوج قبل بلوغه سناً معينة.
3. **تأمين المهر:** يكون المستفيد أحد أولاد المؤمن له إذا عاش إلى التاريخ الذي يغلب أن يتزوج فيه فيحتاج للمهر.

تعريف الخطر: **حادثة محتملة لا تتوقف على إرادة أحد الطرفين، وخصوصاً إرادة المؤمن له،** ففكرة الخطر خاصة بالتأمين، ولها فيه معنى خاص غير معناها في القانون

المدني أو اللغة المادية.

محل الالتزام: القسط محل التزام المؤمن له، ومبلغ التأمين محل التزام المؤمن، والخطر محل التزام كل منهما؛ فالمؤمن له يدفع الأقساط ليؤمن نفسه من الخطر، والمؤمن يدفع مبلغ التأمين لتأمين المؤمن له من الخطر.

شروط الخطر:

١ الشرط الأول: غير محقق الوقوع:

1. **وقوعه غير محتمل:** قد يقع وقد لا يقع، كالتأمين من الحريق أو السرقة أو الإصابات.
2. **وقوعه محتمل لكن وقته غير معروف:** خطر محقق مضاف إلى أجل غير محقق، كالتأمين على الحياة لحالة الموت (الموت محقق ووقته غير محقق)، والتأمين لحالة البقاء (بقاء المؤمن له حياً بعد مدة أمر غير محقق).

البطلان للاستحالة: فإذا كان الخطر مستحيل الوقوع كان محل التأمين مستحيلاً، ومن ثم بطل العقد.

٢ الشرط الثاني: غير متعلق بمحض إرادة أحد طرفي العقد:

القاعدة: إذا تعلق الخطر بمحض إرادة أحد الطرفين انتفى عنصر الاحتمال وأصبح تحقيقه رهناً بمشيئته، ومن النادر أن يتعلق بمحض إرادة المؤمن، وإلا لاستطاع منع تحقق الحادث فلا يتحمل خطراً محلاً للتأمين، ويجب ألا تثور فكرة التأمين من خطر متعلق بمحض إرادة المؤمن له؛ لأنه يؤمن نفسه من خطر يستطيع تحقيقه بمحض إرادته، فلابد من تدخل عامل آخر غير محض إرادته: عامل المصادفة والطبيعة أو إرادة الغير.

مدى جواز التأمين من الخطأ العمدي: **لا يجوز لشخص أن يؤمن نفسه من خطئه العمدي؛ لأنه يتعلق بمحض إرادته،** فإذا أمن على حياته لا يستحق مبلغ التأمين إذا انتحر؛ لأنه تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه وهو الموت (م 756 مدني)، وإذا أمن على حياة غيره لمصلحته ثم تسبب عمداً في وفاته فقد تعمد تحقيق الخطر، فلا يرجع على المؤمن بالتعويض (م 757 مدني)، وإذا أمن على منزله من الحريق ثم تعمد إحراقه فقد تعمد تحقيق الخطر (م 2/768 مدني)، ولا يشترط أن يتعمد المؤمن له الإضرار بالمؤمن، بل يكفي أن يتعمد تحقيق الخطر المؤمن منه وهو عالم أن بتحقيقه يثير مسئولية المؤمن عن تعويض الضرر.

٣ الشرط الثالث: مشروع غير مخالف للنظام العام والآداب:

النص القانوني (م 749): يجب أن يكون الخطر متولداً عن نشاط للمؤمن له غير مخالف للنظام العام أو الآداب، وقد اشترط المشرع صراحة أن تكون المصلحة المؤمن عليها اقتصادية مشروعة بنص المادة 749 مدني: **"يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين،"**

1. **الغرامات والمصادرة:** لا يجوز التأمين من الغرامات المالية أو المصادرة الجنائية؛ لأن كلاً منهما عقوبة، والعقوبة يجب أن تبقى شخصية مراعاة للنظام العام، فالتأمين منهما باطل لمخالفته النظام العام.
2. **المخدرات:** لا يجوز التأمين من الأخطار المترتبة على الاتجار في المخدرات، وإلا كان العقد باطلاً لمخالفته النظام العام.
3. **الدعارة والمقامرة:** لا يجوز التأمين على منزل يدار للدعارة أو المقامرة إذا كان الغرض التمكين من هذه الأعمال المنافية للآداب، فهو باطل لمخالفته الآداب.
4. **الخليلة:** لا يجوز التأمين على الحياة لمصلحة الخليلة إذا كان الغرض دفعها للرضا بالعلاقة غير المشروعة أو الاستمرار فيها أو العودة إليها بعد انقطاعها، أما إذا كان الغرض تعويضها عما لحقها من ضرر بسبب هذه العلاقة، فالتأمين مشروع.

– أنواع الخطر:

1. **الخطر الثابت والمتغير:** الأصل أن يتبع القسط الخطر؛ فيجب أن يتغير من سنة لأخرى بحسب تغير الخطر تصاعداً أو تنازلاً، ولكن المؤمن يجعل مقدار القسط السنوي ثابتاً لتبسيط التعامل وتيسير الأمر على المؤمن له.
2. **الخطر المعين وغير المعين:**

المعين: إذا كان المحل الذي يقع عليه الخطر إذا تحقق — شخصاً أو شيئاً — معيناً وقت التأمين، كالتأمين على حياة المؤمن له أو حياة غيره، أو على منزله من الحريق،

غير المعين: إذا كان المحل غير معين وقت التأمين، وإنما يتعين عند تحقق الخطر، كالتأمين من المسئولية عن حوادث السيارات.

MNARA 01105405478

3 **أهمية التمييز:** تظهر في تعيين مقدار مبلغ التأمين عند تحقق الخطر:

في المعين: يسهل تعيين المبلغ، فهو قيمة الشيء المعين الذي يقع عليه الخطر في التأمين على الأشياء، وفي التأمين على الأشخاص يجوز تعيين أي مبلغ ويلتزم المؤمن بدفعه كاملاً دون نظر لمقدار الضرر.

في غير المعين: لا يوجد شيء يُرتكز عليه وقت التأمين لتعيين المبلغ، فيصح أن يكون غير محدد فيلتزم المؤمن بتعويض كامل عن مسئوليته عن أي حادث — التأمين غير المحدد، ويصح أن يحدد الطرفان مبلغاً معيناً حداً أقصى لما يلتزم به المؤمن — التأمين المحدد.

2 الفرع الثاني: القسط:

التعريف: القسط هو المقابل المالي الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن مقابل التزام الأخير بتحمل الخطر وتغطيته، فهو **ثمن التأمين لا ثمن الخطر** ؛ فالمؤمن يطلب عادة أكثر من ثمن الخطر، إذ لا يكون ثمن الخطر إلا عنصراً من عناصر التأمين، فيضيف المؤمن عناصر أخرى لتقدير القسط الإجمالي.

الترابط مع الخطر: القسط ركن أساسي كالخطر، وبينهما ترابط وثيق؛ فمن الناحية الفنية القسط هو الذي يمكّن المؤمن من تغطية المخاطر — فبدون الأقساط لا يستطيع تعويض الأضرار — ولهذا يجب أن يتناسب القسط مع الخطر، بل إن الترابط يظهر عملياً في استعمال كلمة "خطر" للدلالة على قيمة الخطر لا على الحادثة غير المتوقعة، فيقصد بها قيمة التزام المؤمن لحظة إبرام التأمين، **فإذا لم يكن تأمين بلا خطر، فلا تأمين بلا أقساط؛ فكلاهما وجها العملية الواحدة** .

القسط والاكتتاب: يستعمل لفظ القسط للدلالة على التزام المؤمن له، سواء مع شركة مساهمة أو مع أعضاء جماعات التأمين بالاكتتاب، وقد كان يطلق على المقابل المالي في الحالة الأخيرة "اكتتاباً"، وزالت الآن كل أهمية للتفرقة بعد استقرار العمل على تحديد حد أقصى للاشتراك، وبعد أخذ شركات التأمين بمبدأ المساهمة في الأرباح وتخفيف عبء القسط.

تحديد القسط:

المنظور القانوني: لا يشترط أن يكون مبلغ القسط محدداً في العقد، بل يكفي أن يكون قابلاً للتحديد طبقاً للتعريفات التي تضعها شركة التأمين للأخطار المماثلة، لكن ذلك يثير

مشاكل وخلافاً بين الأطراف، خاصة وأن تحديده يقوم على أسس علمية وفنية قد يصعب على العامة فهمها، فجرى العمل على إيضاح قيمته في العقد، ولا يسري ذلك إذا كان تحديد القسط يتوقف على أجر المؤمن له في فترة معينة (كالتأمينات الاجتماعية)، ولكن توضح عادة أسس تحديده.

كيف يتحدد؟: الأصل أنه يتوقف على اتفاق الأطراف، وهو عادة محل مناقشة بينهما، لكن المشرع قد يتدخل لتحديد الحد الأقصى والأدنى الذي تتراوح فيه الأقساط، كنوع من الرقابة على شركات التأمين ومنع المنافسة التي قد تضر بالمؤمن لهم.

مكوناته: يتحدد على أساس **القسط الصافي** — المستخلص من دراسة الإحصائيات، ويغطي قيمة الخطر أو ثمنه، ويسمى القسط الصافي أو النظري — ثم تضاف إليه **الأعباء** التي يجب أن يساهم المؤمن له في تحملها (كالمصاريف العامة)، ومن مجموعهما يتكون **القسط التجاري أو الإجمالي** الذي يتحمله المؤمن له فعلاً.

القسط الصافي وعناصره:

التعريف: القسط الصافي هو ما يوازي على وجه التقريب قيمة الخطر كما يقدره المؤمن استناداً إلى الإحصائيات والأسس الفنية، فهو المبلغ اللازم ليغطي الخطر دون ربح أو خسارة، والخطر هو العنصر الأساسي لتحديده، لكن تدخل في الاعتبار عوامل مساعدة: مبلغ التأمين، ومدة التأمين، وسعر الفائدة الذي يحصل عليه المؤمن من استغلال رصيد الأقساط المتجمع.

1. **قسط الخطر (المبدأ):** يتحدد القسط أساساً على ضوء الخطر؛ فقيمته تقابل فنياً تكلفة ضمان الخطر، ولهذا يجب أن يكون مساوياً للخطر، والتساوي من ناحيتين: احتمال تحقق الخطر، ومدى جسامته، فإذا اختفى الخطر سقط حق الشركة في طلب القسط؛ فإذا احترقت المنقولات المؤمن عليها ضد السرقة لم يتحقق الخطر، فيسقط حق المؤمن في تقاضي القسط.

2. **قسط الخطر (التغير والمثال):** ويجب أن يتبع القسط الخطر ثباتاً وتغيراً؛ فيزداد بازدياد احتمالات الخطر، ويظل ثابتاً متى كانت درجة الاحتمال ثابتة على مدار العام، والمثال الواضح على الخطر المتغير: التأمين على الحياة لحال الوفاة، فاحتمالات الوفاة تزداد كلما تقدم الشخص في السن، فكان يجب أن يكون القسط في الشباب أقل منه في الشيخوخة.

3 **قسط الخطر (التطبيق العملي):** لكن عملياً لو اتبع ذلك لنفر الناس من التأمين؛ لأن دفع قسط كبير وقت الشيخوخة — حيث تنضب الموارد وتزداد الأعباء — ينقل كاهل الشخص، فيبتعدون عن التأمين على الحياة، ولتفادي ذلك تحدد الشركات قسطاً ثابتاً، لكن حصيلة هذه الأقساط تعادل تماماً حصيلة الأقساط لو كانت متغيرة مع السن.

4 **مبلغ التأمين:** يتحدد القسط تبعاً لتغير قيمة المبلغ المؤمن به، والجداول الفنية التي تضعها الشركات المصرية تكون على أساس القسط بالنظر إلى كون مبلغ التأمين مائة جنيه؛ فلو كان القسط ثلاثة جنيهات فهو على أساس أن مبلغ التأمين 100 جنيه، وعلى هذا إذا أريد أن يكون مبلغ التأمين 300 جنيه فالقسط 9 جنيهات، ويجد ذلك صداه القانوني في المبدأ الذي يقرر أنه إذا تبين يوم تحقق الكارثة أن قيمة الشيء المؤمن عليه تزيد عن قيمة مبلغ التأمين، فإن المؤمن له هو الذي يتحمل قيمة الزيادة، أي أن المؤمن لا يضمن إلا في حدود مبلغ التأمين ولا يلتزم بضمان القيمة الزائدة، ما لم يوجد اتفاق مخالف، فالتناسب بين قيمة الشيء ومبلغ التأمين يرجع إلى ضرورة التناسب بين القسط ومبلغ التأمين.

5 **مدة التأمين:** لما كان عقد التأمين من عقود المدة، توقف القسط أيضاً على مدة التأمين، ولهذا يحسب دائماً بالنظر إلى وحدة زمنية محددة، عادة السنة؛ لأن الشركات تتخذ السنة مدة لإجراء الملاحظات اللازمة لتكوين قواعد إحصائية يمكن على ضوئها تحديد فرص تحقق الخطر واستخلاص نتائج متماثلة من سنة لأخرى طبقاً لقانون الكثرة، فإذا أوضحت الشركات أن القسط جنيه للتأمين من الحريق، وجب فهم ذلك بالنظر إلى أن التأمين لمدة سنة؛ فحساب الاحتمالات الذي يقوم عليه الإحصاء اللازم لتحديد الاحتمالات يكون بالنظر إلى وحدة زمنية هي السنة، فاحتمال وقوع الحادثة ينظر فيه إلى العام بأكمله لا إلى جزء منه.

6 **سعر الفائدة:** لما كان المبدأ أن القسط يدفع مقدماً، تتجمع لدى الشركات مبالغ كثيرة في الفترة بين أداء القسط ودفع مبلغ التأمين عند تحقق الكارثة، كما أن التأمين على الحياة يؤدي إلى تجمع مبالغ كبيرة تمثل الاحتياطي، فلا تترك الشركات هذه الأموال دون استثمار، والاستثمار يدر أرباحاً كثيرة، ولهذا يدخل في الاعتبار عند تحديد القسط ما يدره مجموع الأقساط من فائدة، بإنقاص قيمة القسط بما يوازي سعر الفائدة التي يدرها عند استثماره.

أعباء القسط:

التعريف: هي المبالغ التي يجب إضافتها إلى القسط الصافي لتغطية النفقات المتعلقة بإدارة مشروعات التأمين وإدارة عقد التأمين الخاص، فالقسط الصافي لا يمثل إلا مقابل قيمة الخطر، لكن المؤمن له يدفع قسطاً أعلى، وتلك الزيادة تنشأ من حاجة إدارة عملية التأمين لنفقات كثيرة؛ فشركات التأمين تحتاج لنفقات للقيام بدور الوسيط بين مجموع المؤمن لهم، فتقوم بتوزيعها عليهم، ويتكون بالتالي مجموع القسط الفعلي لتغطية الخطر محل التعاقد، وتقسم:

1. **النفقات العامة:** كإيجار المكان وأجور الموظفين والخبراء الذين يندبون لتقدير الكوارث، وهي مرتفعة للغاية، وتجتهد الشركات في ضغطها وتقليلها.
2. **الأرباح:** فشركات التأمين شركات مساهمة تنتظر ومساهموها ربحاً معيناً مقابل توظيف الأموال في عملية التأمين، فتحمل المؤمن لهم بقيمة الربح المرغوب، وبالتالي يدخل في أعباء القسط.
3. **نفقات إبرام العقود:** نظراً لعدم انتشار الوعي التأميني، توجد طائفة من الوسطاء تذهب للناس لإقناعهم بفائدة التأمين وتحثهم على إبرام العقود، ويتقاضون عمولات كبيرة عن كل عملية، لتعويض مجهودهم أيضاً في العمليات التي لم تتم، وتوازي هذه العمولات أحياناً حوالي 20% من الأقساط الواجب سدادها.
4. **الإعلانات:** التي تقوم بها الشركات لدى وسائل الإعلام المختلفة لإقناع الناس بالتأمين وفوائده.
5. **الأعباء الضريبية:** لما كان القانون يفرض ضرائب كثيرة على شركات التأمين مقابل عملياتها، لجأت إلى نقل عبئها إلى المؤمن لهم، بإدخال قيمتها إما ضمن المصاريف الإدارية المحملة على الأقساط، وإما بتحميل عبئها مباشرة على المؤمن له عند إبرام العقد كبند إضافي إلى جانب القسط الصافي، كما يحدث في الدمغة.

3 الفرع الثالث: مبلغ التأمين:

في تأمين الأضرار: يقصد به تعويض المستأمن عما أصابه من ضرر بسبب وقوع الخطر في حدود المبلغ المتفق عليه، ولهذا يسمى **التعويض** .

في تأمين الأشخاص: يتحدد مقدماً دون أن يكون تعويضاً لشيء، ويسمى **رأس المال** .

NARA 01105405478

تحديد مبلغ التأمين:

القاعدة: قد يتحدد في الوثيقة بقدر معين (كما في تأمين الأشخاص)، أو بحد أقصى معين (كما في تأمين الأضرار)، غير أنه يجوز أن يرد غير محدد بقدر أو بحد أقصى، كما في تأمين الأضرار حيث يتفق على إلزام المؤمن بتعويض كافة الأضرار الناشئة عن الخطر.

قانون 652 لسنة 1955: وقد جعل القانون رقم 652 لسنة 1955 التأمين غير المحدد إجبارياً ضد حوادث السيارات، فنصت المادة الأولى على أن: **"المؤمن يلتزم بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955، ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته، ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه."**

1 مبلغ التأمين في تأمين الأضرار:

الصفة التعويضية: يتوقف على الضرر الناشئ عن الحادث المؤمن منه والمبلغ المؤمن به، فلا يستحق إلا إذا حدث ضرر بالفعل نشأ عن وقوع الخطر، فيكون المبلغ تعويضاً عنه، أي أن التأمين ضد الأضرار ذو صفة تعويضية، **ولا يجوز أن يتجاوز مبلغ التأمين قيمة الضرر وإلا كان إثراء بلا سبب**، وإذا لم يحدث ضرر فلا التزام للمؤمن بشيء، ولا يحق أن يتجاوز مبلغ التأمين الحد الأقصى المتفق عليه أياً كان الضرر ومداه، على أنه يجوز أن يكون التأمين غير محدود، وفي التأمين على الأشياء يمكن تحديد أقصى خسارة للمستأمن بقيمة الشيء المؤمن عليه يوم وقوع الحادث، وبالتالي لا يتجاوز مبلغ التأمين هذه القيمة.

2 مبلغ التأمين في تأمين الأشخاص:

انتفاء الصفة التعويضية: ليس له صفة تعويضية، ولهذا يتحدد بالقدر المحدد والمتفق عليه في الوثيقة بصرف النظر عما إذا حدث ضرر أو لم يحدث عند وقوع الحادث.

1. **الجمع بين المبلغ والتعويض:** يحق للمؤمن له الجمع بين هذا المبلغ وبين التعويض الذي قد يحكم له به قبل الغير الذي أصابه ضرر نشأ عن الخطر؛ لأن مصدر مبلغ التأمين هو عقد التأمين، ومصدر التعويض هو العمل غير المشروع.

2 **تعدد مبالغ التأمين:** يجوز أن تتعدد مبالغ التأمين بتعدد عقود التأمين، وللمؤمن له قبضها جميعاً.

4 الفرع الرابع:المصلحة:

التمهيد: المصلحة أن يكون للمؤمن له أو للمستفيد مصلحة في عدم وقوع الخطر المؤمن منه.

– تحديد معنى المصلحة في التأمين من الأضرار:

المصلحة في تأمين الأشخاص: ولا تظهر أهميتها كركن في التأمين على الأشخاص إلا في حالة **التأمين على حياة الغير** ؛ فيثور التساؤل: هل يجب أن يكون للمؤمن له مصلحة في بقاء المؤمن على حياته؟ وفي رأينا أن المشرع المصري لم يشترط ذلك، لكن هذا القول قد يدفع المؤمن له للتسبب عمداً في وفاة الغير ما دام لا مصلحة له في بقائه، وما دام يفيد من موته باستحقاق مبلغ التأمين، وقد تلافى المشرع هذه الخشية فاشترط في التأمين على حياة الغير موافقة هذا الغير كتابةً قبل إبرام العقد، طبقاً لنص المادتين 755 و757 مدني.

المصلحة في تأمين الأضرار: المصلحة أن يكون للمؤمن له أو للمستفيد مصلحة في عدم وقوع الخطر، وقد نصت المادة 749 مدني على أنه: **"يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين،"** فيجب أن تكون المصلحة اقتصادية، أي ذات قيمة مالية، وأن تكون مشروعة، فإذا لم تكن للمؤمن له أو للمستفيد في التأمين من الأضرار مصلحة اقتصادية مشروعة في عدم تحقق الخطر، كان عقد التأمين باطلاً لانعدام المحل أو لعدم مشروعيته.

ALARA 01105405478

محاور الفصل الرابع:

١ خصائص عقد التأمين | ٢ إبرام عقد التأمين

١ المبحث الأول: خصائص عقد التأمين:

تمهيد المرجعية: الأصل خضوع عقد التأمين للأحكام العامة للعقود في القانون المدني، لكنه يخالفها في مواطن كثيرة لطبيعته ولتدخل العرف التأميني، والمرجعية في أي مسألة: **الأحكام الخاصة أولاً (أضرار/أشخاص)** ، ثم **الأحكام العامة لعقود التأمين** ، ثم **الأحكام العامة للعقود كافة** .

– أولاً: الخصائص العامة:

الخصيصة	المضمون
رضائي	ينعقد بتبادل إرادتين متطابقتين دون شكل خاص، وكتابة بعض القوانين للإثبات لا للانعقاد؛ ويجوز الاتفاق على جعله شكلياً (لا ينعقد إلا بالكتابة) أو عينياً (لا ينعقد إلا بدفع القسط).
ملزم للجانبين	التزامات متبادلة: المستأمن — دفع القسط وبيان أوجه الخطر والإعلان عن تفاقمه؛ المؤمن — دفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر.
احتمالي	يصدق على علاقة المؤمن بالمؤمن له (انظر البند ٢ من الخصائص الخاصة).
زمني	الزمن عنصر جوهري: يُعقد لزمن معين، بوحدات (سنة، شهر، يوم) أو بمقدر (رحلة، محاولة شاقة، محفوظة بالمخاطر)، والزمن يحدد مدى التزام الطرفين، وفسخه لا أثر رجعي له، فلا يسترد المؤمن له أقساط المدة السابقة على الفسخ.

– ثانياً: الخصائص الخاصة:

١ عقد إذعان:

التكييف القانوني: نصت المادة 100 مدني على أن **"القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها،"** وبتطبيقه

على التأمين: شركات التأمين تضع وثائق مطبوعة بشروط عامة تتعلق بإبرام العقد والتزامات المستأمن وسقوط حقه في حالات كثيرة، ولا يكون أمامه إلا القبول بها برمتها أو رفضها دون مناقشة، وقد نادى عدد كبير من الفقهاء بتدخل المشرع لحماية المستأمن من تعسف الشركات وشروطها القاسية.

2 عقد احتمالي:

التعريف: العقد الاحتمالي هو الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين أو أحدهما وقت إبرام العقد معرفة القدر الذي يأخذه أو يعطيه، فلا تتحدد مدى التزاماته أو منفعته إلا في المستقبل تبعاً لأمر غير محقق الوقوع أو غير معروف وقت حصوله، وعقد التأمين كذلك بلا جدل؛ لأن مقدار التزام أو منفعة كلا المتعاقدين معاً يقوم على الخطر المؤمن منه.

1. **من الناحية القانونية:** لا جدل في اعتباره من العقود الاحتمالية، **للمستأمن:** إن تحقق الحادث بعد فترة قصيرة ربحت الصفقة (لم يدفع إلا أقساطاً بسيطة)، وإن دفع الأقساط كلها ثم لم يتحقق خسر (لم يحصل على مقابل)، **للمؤمن:** يُنظر إلى كل عقد على حدة لا إلى مجموع العقود، فيكون كل عقد احتمالياً؛ لأن التزامه بدفع المبلغ معلق على تحقق الخطر، فإن تحقق دفع، وإن تخلف لم يدفع شيئاً واحتفظ بالأقساط.
2. **من الناحية الفنية:** التأمين ليس عملية احتمالية بحتة أو مجرد رهان؛ إذ يعتمد المؤمن على الإحصاء وقوانين الأعداد لتحديد أقساط دقيقة ومقاصة المخاطر، مما يزيل عنصر المفاجأة، فعلى الرغم من أن العقد يبدو احتمابياً من الناحية القانونية، إلا أن عمليات التأمين برمّتها تعدّ في الواقع نظاماً فنياً محكماً وبعيداً عن المضاربة العشوائية.
3. **علاقة المؤمن بمجموع المؤمن لهم:** التعاون بين مجموعهم يلغي أثر الحظ أو المصادفة ويوزع أثر الكارثة بين الجمع، فإن لم تتحقق فالأقساط المدفوعة مقابل التعاون أو توزيع الحظ فيما بينهم جميعاً، فإن قام التأمين على الأسس الصحيحة كان احتمال الكسب أو الخسارة بالنسبة للمؤمن مما لا يتجاوز مألوف التجارة.

3 عقد حسن النية:

التضييق في التفسير: يجب التضييق في تفسير عقود التأمين؛ فلا يلتزم المؤمن إلا بما نص عليه صراحةً وفي حدود الوثيقة فقط، دون أي توسع أو إضافة، وقد أكد القضاء المصري

أن الشروط التعاقدية الصريحة لا تقبل التأويل أو الخروج عن مضمونها، وأن الشروط المطبوعة ملزمة تماماً، وليس للمستأمن المنازعة في صحتها بحجة أنها مطبوعة مسبقاً.

الفقه الحديث: يرفض وصف التأمين بأنه عقد من العقود الضيقة؛ لأنه لم يعد يتلاءم مع التنظيم القانوني للعقود في العصر الحديث، ويرى أن الوصف لم يقصد به أكثر من تأكيد كون المؤمن لا يلتزم إلا بضمان المخاطر المحددة صراحةً وفي نطاق الحدود الموضحة، وأنه ليس إلا تطبيقاً لقاعدة **"العقد شريعة المتعاقدين"** التي تنطبق على جميع العقود — والدليل أن المبدأ لا ينطبق عند تعارض شرط في وثيقة التأمين مع نص آمر من النصوص المنظمة للعقد.

لا يقتصر حسن النية على الإبرام: بل يتطلبه أثناء التنفيذ وطول السريان:

1. يلتزم المستأمن باتباعه والامتناع من إيقاع الخطر عمداً والمحافظة على الشيء وعدم اتخاذ تصرف يزيد نسبة تحقق الخطر أو يشدده،
2. إبلاغ المؤمن بالظروف الجديدة التي تزيد نسبة التحقق أو تشديده،
3. العمل بقدر جهده عند تحقق الخطر على حصر نطاقه في أضيق الحدود والتقليل من الضرر، ويتعرض من يخالف لعدة جزاءات متنوعة تصل أحياناً إلى سقوط الحق في مبلغ التأمين.

2 المبحث الثاني: إبرام عقد التأمين:

– المطلب الأول: الأحكام العامة:

التمهيد: تتعلق بأركان العقد كسائر العقود: التراضي، والأهلية، وسلامة الإرادة، والمحل والسبب، ولما كان المحل الرئيسي هو الخطر فقد سبق بحثه، ونقتصر على الثلاثة الأولى:

1 **التراضي:** العقد رضائي ينعقد بمجرد توافق الإيجاب، ما لم يشترط القانون أو المتعاقدان شكلاً خاصاً، لكنه يتميز عملياً بأن وثيقة التأمين تشتمل في معظم الحالات على شرط يعلق الإبرام على التوقيع، فيتحول إلى عقد شكلي معلق على التوقيع، وعقد عيني لا يتم إلا بدفع القسط الأول، ويجب تفسير اتفاق المتعاقدين بدقة لمعرفة هل الكتابة ودفع القسط شروط متطلبة لإبرام العقد أم لمجرد تنفيذه، وقد حكم القضاء بأن الكتابة وإن لم تكن شرطاً لازماً إلا أن الأصل أن ارتباط المتعاقدين لا يوجد إلا عند التوقيع، إذ هو العرف الثابت الذي جرت عليه الشركات، ويرى الفقه أنه إذا اشترط ألا يتم العقد إلا بتوقيع كلا الطرفين، ووقعه المؤمن وحده، جاز للمستأمن العدول.

2 **الأهلية:** لما كان يشترط في المؤمن شركة مساهمة، فأهمية الأهلية تظهر بالنسبة للمستأمن، ولما كان التأمين من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، ومن عقود الإدارة، فأهليته أهلية مباشرة عقود الإدارة، فيجوز للبالغ الرشيد، وللصبي المميز المأذون بالإدارة، أما غير المأذون فلا يجوز إبرامه، وإلا كان قابلاً للإبطال لمصلحة القاصر بناءً على طلبه أو طلب الوصي أو الولي أو القيم، إلا إذا أجازه الولي أو الوصي أو القاصر نفسه بعد الإذن أو بعد الرشد، ويجوز للولي أو الوصي أو الوكيل بوكالة عامة إبرامه لمصلحة القاصر دون استئذان؛ لأن التأمين من عقود الإدارة التي يملكون القيام بها نيابةً عن المحجور عليهم.

3 **عيوب الإرادة:** يخضع التأمين لأحكام النظرية العامة، وفي جانب المستأمن، وإن كان من النادر أن تشوب إرادته عيوب لأنه لا يقدم على التأمين بسببها، فإن عيوب الإرادة لها أهمية كبرى بالنسبة للمؤمن؛ لاعتماده في كثير من الأحيان على بيانات المستأمن التي تساهم في تكوين فكرة كاملة عن الخطر وأوصافه ودرجة احتمال تحققه، وقد سبق أن التأمين من عقود حسن النية، وأن دوره فيه أكبر من أي عقد آخر، فيجب الإدلاء بصدق ودقة بكل البيانات المتعلقة بالخطر، ليتمكن المؤمن من التمسك بالإبطال للغلط أو التدليس إذا كان من شأن كتمان المستأمن أو كذبه أن يدفعه للتعاقد، وقد حكم القضاء بالإبطال للتدليس أو الغلط إذا أبرم العقد بعد وقوع الحادث المؤمن منه وكان المؤمن يجهله والمستأمن يعلمه وكتمه.

– المطلب الثاني: الإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر عند إبرام العقد:

التمهيد: يلتزم المستأمن وقت الإبرام بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالخطر، وإذا استجدت ظروف أثناء السريان من شأنها زيادة نسبة احتمال وقوعه، وجب إعلان المؤمن بها، فإن لم يقم تعرض لجزاء، وله التمسك بعدة دفوع، وندرسه في أربع مسائل: (1) إدلاء المستأمن وقت العقد، (2) تقريره بما يستجد، (3) الجزاء، (4) الدفوع.

1 أولاً: وقت وشروط الإدلاء وقت إبرام العقد:

الالتزام: يلتزم المستأمن بتقديم كافة البيانات المتعلقة بتحديد الخطر وجسامته وأوصافه وقت الإبرام؛ لأن عليها يبني المؤمن قبوله للعقد وتحديد سعر القسط، فإن وافق، تقدم بإيجاب يطلب فيه إبرام العقد بالشروط التي تضمنها الطلب والقسط الذي حدده المؤمن.

MNARA 01054054078

2 ثانياً: التكييف القانوني لطلب التأمين ومدى قوته الملزمة:

النص الفرنسي: تنص المادة السابعة من قانون التأمين الفرنسي على أن طلب التأمين لا يلزم المستأمن ولا المؤمن، ونرجع لأثره بالنسبة للمؤمن، ثم للمستأمن، ثم لأهميته العملية:

1 بالنسبة للمؤمن:

❶ مجرد تسليم المؤمن طلب التأمين للمستأمن لا يعتبر إيجاباً منه؛ لأن غرض الطلب رغبته في معرفة بيانات الخطر وأوصافه وظروفه ليقرر في ضوئها القبول أو الرفض،

❷ ولا يمكن اعتباره عرضاً دائماً موجهاً للجمهور؛ لأن غرضه يتضمن في جميع الحالات تحفظاً حتمياً لم تجر العادة على طبعه في العقد، فيكون تقديم الطلب أعمال إعلان وحث الجمهور وشروط العقد عملاً، ودعوة إلى التعاقد،

❸ ولا يمكن اعتبار تسلمه بعد ذلك من المستأمن قبولاً من المؤمن؛ لأنه إنما يطلب البيانات دون التزام من جانبه، فيكون حراً بعد وصول الطلب في قبوله أو رفضه، وإذا رفض فلا يلتزم بشيء نحو الطالب، ولا ببيان أسباب الرفض أو إبلاغه خلال مدة معينة، ما لم يتفق على عكس ذلك.

2 بالنسبة للمستأمن:

الأصل أن تحرير الطلب وتقديمه لا يعتبر إيجاباً منه؛ لأنه مجرد عرض تمهيدي أو استعلام عن مقدار القسط وسائر الشروط التي سيعرضها المؤمن بعد معرفته للبيانات، فلا يلتزم بإبرام العقد، وله بعد وصول رد المؤمن ومعرفة القسط أن يبرم أو ينقض دون مسئولية،

لكن هناك حالة: إذا ضمن طالب التأمين طلبه كافة الشروط التفصيلية والعناصر الجوهرية اللازمة للانعقاد — البيانات المتعلقة بالخطر، ومبلغ التأمين، ومقدار القسط، ومواعيد الوفاء وكيفيته، ومدة العقد — فإنه يعبر عن نية قاطعة في الإبرام، فيكون إيجاباً باتاً كافياً للانعقاد إن صدر القبول من المؤمن، أما قوته الملزمة: فالمبدأ في التقنين المدني أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه؛ فالإيجاب في هذه الحالة لا ينتج أثره ولا يلزم صاحبه إلا إذا اتصل بعلم المؤمن، وقبل ذلك يستطيع العدول فيه أو الرجوع عنه.

3. **أهميته العملية:** رغم عدم الأثر الملزم، فإن للطلب أهمية كبيرة إذا أبرم العقد بعد ذلك؛ لأنه الوثيقة الأساسية التي يرجع إليها في تحديد البيانات المتعلقة بالخطر وجسامته وأوصافه وظروفه، فيكون المستأمن مسئولاً عن صحتها ودقتها وعن أي كذب أو غلط فيها.

3 ثالثاً: وثيقة التأمين:

المقصود والشكل: المحرر أو الدليل العادي الذي جرى العمل على اتخاذه وسيلة لإثبات عقد التأمين، لا يشترط فيها شكل معين: عرفية أو رسمية، مطبوعة أو مكتوبة باليد — وإن كانت الأغلبية مطبوعة، ولا لغة معينة؛ وقد كانت المادة 1057 من المشروع التحضيري تشترط العربية أو إحدى اللغات الدولية في التعامل إذا رغب الطالب، لكنها حذفت.

الشروط العامة (المطبوعة): العادية الموجودة في كل وثيقة تأمين، لا تختلف من وثيقة لأخرى.

الشروط الخاصة (المكتوبة): الخاصة بكل عقد على حدة، تختلف من وثيقة لأخرى، مكتوبة بخط اليد أو بالآلة الكاتبة تمييزاً لها عن العامة.

1. **تاريخ التوقيع:** يحدد وقت قبول المؤمن الإبرام نهائياً، واللحظة الأخيرة للإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر وجسامته، وترتيب المؤمنين المتعاقبين عند تعدد العقود على نفس الخطر.
2. **بيانات المتعاقدين:** للمستأمن: اسمه ولقبه وصناعته، وفي التأمين على الحياة يضاف اسم المستفيد والشخص المؤمن على حياته في التأمين على حياة الغير، وللمؤمن: اسم الشركة ومقدار عملها وقيدها في السجل وتاريخ ترخيصها بخضوعها لقانون هيئات التأمين.
3. **جميع بيانات الخطر:** في تأمين الأشخاص يحدد الشخص المؤمن على حياته أو إصابته بدقة، وفي تأمين الأضرار يحدد الشيء المؤمن عليه بدقة، وطبيعة المخاطر المؤمن ضدها على وجه التفصيل.
4. **مبلغ التأمين:** الالتزام الأصيل للمؤمن، وتحديده جوهري في تأمين الأشخاص، أما في تأمين الأضرار فيمكن عدم تحديده، إذ يتوقف مقداره على جسامة الضرر عند تحقق الخطر.

MNARA 01105405478

5 **القسط:** كافة البيانات: تحديد سعره بالضبط، وميعاد استحقاقه، وكيفية الوفاء به، ومكانه.

6 **تاريخ تنفيذ العقد:** الذي يبدأ فيه التزام المؤمن بالتأمين والتزام المستأمن بالقسط، وتاريخ انتهاء العقد.

> **ملاحظة:** البيانات ليست على سبيل الحصر، بل تمثل العناصر الجوهرية الرئيسية؛ فقد يغفل بعضها وتذكر أخرى، وإذا تخلفت بعض الثانوية فيمكن تحديد العقد عن طريق تعريفه أو إرادة المتعاقدين الضمنية أو العرف وطبيعة التعامل.

4 دور الوثيقة في بدء السريان:

الفرض	التكييف	الأثر
الأصل	دليل إثبات لا شرط انعقاد	ينعقد بمجرد تمام الاتفاق النهائي ولو قبل تحرير الوثيقة، فإذا أرسل المستأمن إيجاباً باتاً يشمل البيانات الجوهرية، لزم الجانبين بمجرد وصول القبول لعلمه دون تحرير أو توقيع أو دفع القسط الأول، وترتبت الالتزامات في ذمة كل منهما: المستأمن بالقسط، والمؤمن بتحمل الخطر.
تعليق الانعقاد	عقد شكلي (بكتابة الوثيقة) وعيني (بتسليم القسط الأول)	جرى العمل على اشتراط المؤمن ألا يتم العقد إلا بتوقيع الوثيقة ودفع القسط الأول، وأيده القضاء، فصارت الوثيقة شرطاً في الانعقاد ذاته، فلا يكون العقد قائماً إلا من لحظة التوقيع والاستلام؛ وإذا رفض المستأمن التوقيع والدفع فلا يجبر عليهما ولا يقاضى على أساس العقد (لعدم وجوده)، ولا يبقى للمؤمن إلا الرجوع بالتعويض لعدوله.
تأجيل التنفيذ	العقد تام، التنفيذ معلق	يتفقان على أن التوقيع والدفع شرط لتنفيذ العقد لا لانعقاده؛ فيتم العقد ويلزم الجانبين بمجرد التراضي، لكن يعلق تنفيذ التزام المؤمن بتغطية الخطر على التوقيع والدفع، حتى يتخلص من احتمال تحمل الخطر ودفع المبلغ رغم مماطلة المستأمن.

5 التفسير:

الحالة	التفسير

العبارة واضحة	تفسير حرفي، لا انحراف عن المعنى الواضح بدعوى التفسير، وإلا خالف العقد وجاز نقض الحكم، ويسري على جميع الشروط مطبوعة أو لا، ما لم يتعارض مع شرط آخر: فإن أمكن التوفيق عمل بهما، وإلا استخلص الشرط الواجب العمل به طبقاً للنية، والشرط الواضح يطبق على عمومه دون تفرقة بين حالة وأخرى.
العبارة غامضة	استخلاص النية المشتركة مع الاستهداء بطبيعة التعامل وحسن النية.
عقد إذعان	التفسير لمصلحة الطرف المذعن، إلا أن المادة 750 مدني تقضي ببطلان كثير من الشروط التعسفية.

6 الملحق:

المقصود: محرر إضافي لاحق على الوثيقة بين المؤمن له والمؤمن، يعدل شروطها — كزيادة مبلغ التأمين، أو إضافة خطر لم يكن مؤمناً منه، أو تغيير المستفيد، أو إضافة شرط سكت المتعاقدان على إدراجه، ويسري عليه ما يسري على العقد الأصلي.

طريقة الإثبات: يجب أن يتفق الطرفان على التعديل في ملحق يوقعانه، وليس ما يمنع من إثباته كتابةً بصورة أخرى: على هامش الوثيقة أو في ذيلها مع توقيع الطرفين، أو بخطابات متبادلة، وقد يستفاد من سلوك الطرفين وما جرى عليه العمل — كسكوت المؤمن له قوة كافية عن الرد على إيجاب في شأن الملحق، فيكون قبولاً ينعقد به.

الأثر: وإذا كان التعديل جزءاً من الوثيقة الأصلية، نفذ في حق الطرفين من تاريخ إجرائه، ولا يسري بأثر رجعي إلى تاريخ الانعقاد أو بدء السريان، فإذا تضمن زيادة في القسط، لم يلتزم المؤمن له بدفعها إلا عن الأقساط المستقبلية؛ وكذلك لا يضمن المؤمن المخاطر الجديدة إلا من وقت التوقيع على الملحق، ومع هذا فقد تتجه نية الطرفين إلى جعل الملحق ذا أثر رجعي إلى تاريخ سريان العقد الأصلي، كما إذا كان الغرض تدارك شرط سقط سهواً أو جلاء غموض في بعض الشروط.

محاور الفصل الخامس:

1. التزامات المؤمن له
2. التزامات المؤمن

1 المبحث الأول: التزامات المؤمن له:

– المطلب الأول: الإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر:

الأهمية: من الالتزامات الرئيسية؛ فبها يقدر المؤمن جسامة الخطر ويحدد القسط — وإن كان يستطيع بوسائل خاصة التحري والاستعلام عن الخطر ومدى جسامته وأن يسلم ببعض الظروف.

الالتزام بالتوضيح: يلتزم المؤمن له عند الإبرام بتوضيح كل ما يعلمه أو يستطيع أن يعلمه من أوجه الخطر، التي على أساسها يقدر المؤمن القبول أو الرفض أو مقدار القسط.

1. **بيانات شخصية:** أخلاق المؤمن له وسيرته الذاتية، سبق شهر إفلاسه أو إعساره، سبق سحب رخصة القيادة، سبق رفض طلبه من مؤمن آخر، سبق فسخ عقد أبرمه مع شركة أخرى، سبق إبرام عقود أخرى على نفس الخطر، ومنها صفته بالنسبة للشيء المؤمن عليه: مالكاً أم مستأجراً أم دائناً مرتهناً أم مودعاً عنده.
2. **بيانات موضوعية:** **في الأشياء:** نوع الشيء والمواد المصنوع منها وتخصيصه وموقعه بالنسبة لمصادر الخطر (كمصنع للمواد الملتهبة) ووجوه استعماله، **في الأشخاص:** السن والحالة الصحية ماضياً وحاضراً في الحياة، **في الحوادث:** المهنة ونوع العمل.

حدود الإدلاء: ويلتزم بالإدلاء من تلقاء نفسه، لا بالإجابة عن أسئلة النماذج المطبوعة فقط، إذ قد لا تشمل كافة الظروف.

1. **معلومة للمؤمن له:** التزامه قاصر على ما يعرف أو كان يمكنه أن يعرف أو كان مفروضاً عليه حتماً أن يعرف، فإن لم يكن عالماً بها بأي وجه فلا يلتزم، وإلا كان تكليفاً بمستحيل — كمن أصيب في سن مبكرة بمرض ولم يعلم به، والمعيار ذاتي لا موضوعي مجرد.

MARA 01054054178

2 **جوهرية البيان:** بحيث تؤثر في قبول المؤمن أو رفضه أو تحديد القسط، أما ما لا يؤثر — كبيان عمر المؤمن له في التأمين من الحريق — فلا يلتزم به.

جزاء الإخلال وحسن النية: حسن النية مفترض، وعلى من يدعي خلافه الدليل، فإذا أدلى المؤمن له بالبيانات، افترض أنها صحيحة وأنها كل ما يعرفه، فإذا ادعى المؤمن عدم صحتها أو كتمان بعضها وجب عليه إثبات ذلك وإثبات سوء النية — وينصب على وقائع مادية فتجوز كافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن.

عنصر سوء النية	الحكم
الوقت	يبطل سواء اكتُشف قبل الكارثة أو بعدها.
الأثر على الخطر	يبطل سواء كان للبيان أو الكتمان دخل في وقوع الخطر أو لم يكن.
الثبوت	يجب إثبات سوء النية: علم المؤمن له بأن البيان كان من شأنه التأثير على قبول المؤمن أو تقدير القسط، ومع ذلك قدمه أو كتمه عمداً بقصد الخداع، ومجرد العلم بالبيان المكتوم لا يكفي — فقد يكون الكتمان بحسن نية.
آثار البطلان – المؤمن له	زوال العقد بأثر رجعي كأن لم يكن: يرد كل ما تلقاه من تعويضات — عن الكارثة التي كشفت غشه أو الكوارث السابقة التي عوض عنها طوال العقد — مع فوائدها من تاريخ دفعها لا من تاريخ المطالبة القضائية.
آثار البطلان – المؤمن	خلافاً للأثر الرجعي: لا يرد الأقساط المدفوعة قبل البطلان، وله مطالبته بالأقساط المستحقة قبل تقرير البطلان، ولا يتمسك المؤمن له بتقادمها؛ لأن التقادم لا يبدأ إلا من وقت اكتشاف الغش (م 2/752 مدني)، وهو جزاء أو عقوبة مدنية خاصة ضد سيئ النية لا تعويض — إذ التعويض يقدر بقدر الضرر.
الاحتجاج	للمؤمن التمسك بالبطلان في مواجهة المؤمن له والمستفيد وأي من الغير يحتج بالعقد كدائن للمؤمن له.

حسن النية (القاعدة): إذا أدلى ببيانات غير صحيحة أو كتم بعض ما يعرفه وهو حسن النية — أي لا يعلم بعدم الصحة ولم يخطر بباله أن ما لم يدل به كان جوهرياً — فلا يؤثر ذلك في قيام العقد، كل ما في الأمر أن القسط قدر بأقل مما كان يجب دفعه لو علم المؤمن بكل الظروف، فهو لم يقصد الخداع ولا دفع قسط أقل.

خيار المؤمن (قبل الكارثة)	المضمون
إبقاء العقد دون تغيير	تنازل عن الجزاءات الأخرى، وغالباً ما يلجأ إليه المؤمن لعدم أهمية البيان أو رغبة في الاحتفاظ بالعميل، ويستمر العقد بشروطه في القسط ومبلغ التأمين.
إبقاء العقد مع زيادة القسط	ليتناسب مع حقيقة الخطر، يجب إخطار المؤمن له بالرغبة محدداً مدة لتلقي رده، فإن وافق التزم بها من تاريخ قبوله؛ وإن رفض أو انقضت المدة دون موافقة كان للمؤمن الخيار الثالث.
فسخ العقد	بإخطار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويجري عرف الشركات على عدم وقوع الفسخ إلا بعد عشرة أيام من اليوم التالي لإرسال الخطاب، فيظل المؤمن له مغطى خلالها.

الاكتشاف بعد الكارثة: للمؤمن تخفيض مبلغ التأمين أو التعويض بنسبة الفرق بين القسط المتفق عليه والقسط الذي كان يجب دفعه لو علم المؤمن بكل الظروف — تطبيقاً لمبدأ التناسب بين القسط والخطر وبين التعويض والأقساط، فإذا كان المتفق عليه 75 جنيهاً والواجب 100 جنيه، خُفض التعويض بواقع الربع.

المطلب الثاني: الإعلان عن تفاقم الخطر:

أساس الالتزام: تقديم البيانات عند التعاقد لا يبرئ المؤمن له من التزاماته أثناء التنفيذ، فالعقد من العقود المستمرة التي تتطلب مدة، فقد تطرأ ظروف تقلل الخطر أو تزيده، فيصبح القسط غير متناسب مع الخطر ويخل بأحد المبادئ الأساسية، فإذا نقص الخطر سعى المؤمن له لإخطار المؤمن ليخفض القسط؛ وإذا زاد، فالقسط أقل مما يجب، وقد لا يجد المؤمن له — لانعدام مصلحته — دافعاً للإخطار، فهل يترك الأمر لمحض إرادته؟ الواقع أنه ملتزم بإعلان أي تفاقم، ويؤسس هذا الالتزام على **مبدأ تناسب القسط مع الخطر** ، الذي يفرض إخطار المؤمن بأي تفاقم يحدث من سريان العقد إلى انتهائه لأي سبب، فهو **مكمل** للالتزام بالإدلاء بالبيانات: الأخير عند التعاقد، والأول أثناء التنفيذ، والهدف واحد: إحاطة المؤمن بأوصاف الخطر وظروفه ليتخذ القرار المناسب.

المقصود بتفاقم الخطر: كل زيادة تطرأ بعد إبرام العقد — في درجة احتمال الوقوع أو درجة الجسامة — حتى لو لم يكن سبب التفاقم هو الذي أدى إلى وقوع الخطر أو استفحال أثره بالفعل، فالتفاقم في ذاته — بصرف النظر عن أسبابه — يهم المؤمن؛ إذ لو تصور الخطر

بحالته بعد التفاقم فربما لم يكن ليقبل التأمين، أو تعاقد بقسط أكبر، بغض النظر عن وقوع الخطر.

1. **فعل المؤمن له:** تغيير مهنته إلى أشد خطورة، نقل الشيء المؤمن عليه من الحريق لمكان تزيد فيه فرصة الخطر، تحويل السيارة من خاصة إلى أجرة، تحويل المصنع من صناعة غير خطرة (كصناعة الثلج) إلى صناعة مواد متفجرة.
2. **سبب أجنبي:** إنشاء مصنع كيماويات بالقرب من المحل المؤمن عليه من الحريق، حدوث زلزال أو براكين بالقرب من العقار المؤمن عليه.

نطاق الإخطار: يجب حتى لو لم يؤثر في سعر القسط — كما لو شهر إفلاس المؤمن له وكان من شأنه زيادة الخطر — لأن الأمر يؤثر في قبول التأمين أو عدمه، ولا يفيد المؤمن له الادعاء بأن الظروف لا تأثير لها على وقوع الخطر أو جسامته؛ إذ لا يشترط لتوقيع الجزاء ارتباط بين ظروف التفاقم ووقوع الكارثة أو مداها، ويلتزم أياً كانت أسباب التفاقم، بصرف النظر عن ذكرها في الوثيقة أو عدم ذكرها؛ لأن الالتزام يمليه مبدأ تناسب القسط مع الخطر لا وجود بند.

المفهوم	المضمون	المثال
تفاقم الخطر	زيادة عبء الخطر على المؤمن: بزيادة درجة وقوعه أو درجة جسامته.	0.5% ← أعلى.
زيادة الخطر	زيادة قيمة الخطر ذاته دون زيادة عبء الخطر على المؤمن.	فندق بنجمتين + مفروشات وتكييف توطئة لأربع نجوم — التزام المؤمن لا يزداد؛ يلتزم بالضرر الواقع فعلاً في حدود المبلغ المؤمن به، ويتحمل المؤمن له وحده نتيجة الزيادة إذا كان المبلغ المؤمن به أقل من قيمة الأشياء وقت الكارثة، طبقاً لقاعدة التخفيض النسبي.
استبعاد الخطر	اتجاه إرادة المتعاقدين عند الإبرام إلى عدم تغطية المخاطر التي تتحقق في ظروف معينة — جائز.	الحرب والثورات الأهلية في التأمين على الأشياء، أو المسابقات الرياضية في التأمين على الأشخاص، فالخطر المستبعد خارج عن نطاق التأمين، فلا إخطار عن تفاقمه ولا تعويض عنه، أما المتفاقم فمؤمن منه ويلزم

التعويض حال تحققه، ويلزم الإخطار عن الظروف الطارئة.

1. **لا يقوم في التأمين على الحياة:**
   - الظروف المؤدية للتفاقم فيه تدخل في الاعتبار فعلاً عند الإبرام (تقدم السن وتدهور الصحة)، فلا محل للإخطار عنها،
   - فرضه فيه يحد من نشاط المؤمن له.
2. **يقوم أياً كانت الأسباب:** دون تمييز بين الأسباب الواردة في الوثيقة أو غيرها.
3. **الموجب للإخطار:** هو ما يصل إلى علم المؤمن له، سواء رجع إلى فعله أو لسبب أجنبي، أما ما يجهله فلا يلتزم بإخطاره ولا يتعرض للجزاء — كالجار يخزن مواد ملتهبة في بدروم منزله دون علمه.

بفعل المؤمن له: قبل الشروع الفعلي — كتحويل السيارة من خاصة إلى أجرة — دون مدة معينة، ولا يتعين انتظار موافقة المؤمن.

بغير فعله: المبادرة بالإخطار، وليس في القانون المصري مدة معينة، بل الأمر لقاضي الموضوع يقدر المدة المعقولة، ويرى الفقه المصري: إذا تضمنت الوثيقة مدة وجب الالتزام بها، وإلا فخلال مدة معقولة يقدرها القاضي.

شكل الإخطار: كان المشروع التمهيدي يتضمن نصاً في المادة 1069 يقضي بأن الإخطار "بكتاب موصى عليه"، وقد حذفت في لجنة المراجعة، ومع ذلك يجمع الفقه المصري على أنه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

آثار الإخطار: إذا قام المؤمن له به فقد نفذ التزامه، ويظل الخطر مغطى تغطية مؤقتة دون زيادة في القسط إلى أن يتخذ المؤمن موقفاً محدداً، فإذا تحقق الخطر بعد الإخطار استحق مبلغ التأمين كاملاً، حتى لو كان التحقق راجعاً إلى الظروف المستجدة.

خيار المؤمن	الأحكام
فسخ العقد	تطبيقاً للقواعد العامة؛ لأن أحد شروط العقد تغير بدون رضائه، فإن رأى التزامه مرهقاً جاز له الفسخ، يترتب عليه: انقضاء العقد، تحرر المؤمن من التغطية، براءة المؤمن له من القسط مستقبلاً، لا

	تعويض عن الفسخ إلا في تفاقم بفعل المؤمن له، الإخطار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، قبل حلول موعد القسط التالي (فقبول القسط دون زيادة تنازل عن التمسك بالفسخ)، ولا ينتج الفسخ أثره إلا بعد عشرة أيام من إرسال الإخطار، ما لم يتفق في الوثيقة أو ينص في الإخطار على ميعاد أكبر.
إبقاء العقد مع زيادة القسط	بقدر يتناسب مع زيادة الخطر، يشترط لسريان الزيادة قبول المؤمن له، فإن رفض لم يكن أمام المؤمن سوى الفسخ.
إبقاء العقد دون زيادة	كأن يرى بعد إخطاره إبقاء العقد بشروطه السابقة، والقبول صريح أو ضمني — كاستمراره بعد الإخطار في تحصيل القسط المتفق عليه دون زيادة ودون تحفظ، أو دفعه التعويض.

زيادة الخطر (تفصيل): لا محل لها في التأمين على الأشخاص لأن التزام المؤمن له يتحدد عند الانعقاد بالمبلغ المؤمن به، وتكون في التأمين من الأضرار، وتنصرف إلى زيادة قيمة الشيء المؤمن عليه أو قدره، فإذا أمن شخص على منزله من الحريق بسبعمائة جنيه ثم وسع مفروشاته فزادت قيمة ما يملك، فهذه لا تعني زيادة احتمالات الخطر أو جسامته، ولا تؤثر على التزام المؤمن المحدد بمبلغ التأمين، فإذا ارتفعت القيمة عن مبلغ التأمين لم يلتزم المؤمن إلا به، ويتحمل المستأمن وحده نتيجة الزيادة إذا كان المبلغ المؤمن به أقل من قيمة الشيء وقت الكارثة، طبقاً لمبدأ التناسب بين مبلغ التأمين وقيمة الشيء.

نوع التأمين	حكم الإخلال بالإدلاء
التأمين على الحياة	لا يبطل للبيانات الخاطئة أو الغلط في السن — ولو كان حسن النية — بل يجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والواجب على أساس البيانات الصحيحة (إذا كان المتفق عليه أقل)، أو تخفيض الأقساط التالية للحد المتناسب مع البيان الصحيح (إذا كان أكبر) مع رد الزيادة في الأقساط دون فوائد، إلا إذا كانت السن الحقيقية تجاوزت الحد المعين في تعريفة التأمين ← يبطل.
غير التأمين على الحياة	القواعد العامة: تناسب القسط مع الخطر، وقابلية العقد للإبطال للغلط أو التدليس عند الانعقاد، وجواز الفسخ عند الإخلال، من المادة 764 مدني يُفهم أن التأمين الخاضع للقانون المدني يخضع الإخلال فيه للقواعد العامة عدا التأمين على الحياة، فتحكمه 764 و752.

باتفاق الطرفين	إذا اتفقا على بطلان العقد عند عدم بيان المستأمن أوجه الخطر، صح الاتفاق وبطل التأمين إذا لم يبينها.
التأمين البحري	يبطل عند كتمان المستأمن بيانات الخطر التي من شأنها التقليل من أهميته أو تغيير موضوعه، وكذلك عند الإعلان الخاطئ عنها — ولو كان حسن النية.
التأمين الإجباري للسيارات	للمؤمن الرجوع على المؤمن له بقيمة ما أداه من تعويض إذا ثبت أن التأمين عقد بإدلاء ببيانات كاذبة أو إخفاء وقائع جوهرية تؤثر في قبول التغطية أو السعر والشروط، أو أن السيارة استخدمت في أغراض لا تخولها الوثيقة.

المطلب الثالث: الالتزام المتعلق بالكارثة:

⚠ **الإخطار بوقوع الكارثة:** إذا تحقق الخطر المؤمن منه فهذه "الكارثة"، ووقوعها يلقي على المؤمن التزامات أهمها تغطيتها، فمن مصلحته أن يعلم بأسرع وقت ليتخذ ما يراه كفيلاً بالمحافظة على حقوقه، لذلك يفرض المؤمن على المؤمن له التزامات عند تحققها، أهمها الإخطار، يلتزم المؤمن له إذا وقعت الكارثة بإخطار المؤمن، نصت عليه المادة 4/15 من قانون التأمين الفرنسي، ولم ينص عليه المصري، ولكن جرت عادة الشركات على النص عليه في وثائقها.

🕒 **الميعاد:** الفرنسي: "فور علمه بوقوعها" وعلى الأكثر خمسة أيام، المصري: لا نص، وإجماع الفقه على مدة معقولة.

✎ **الشكل:** لا شكل معين، ولكن لما كان عبء الإثبات على المؤمن له، فمن مصلحته أن يكون كتابة، ويقع عليه عبء الإخطار، ويقوم به إلى المؤمن.

⚖ **جزاء الإخلال (نظرية السقوط):** الالتزام بالإخطار اتفاقي، يستطيع العقد أن يحدد جزاءه. فيمكن الاتفاق على تعويض المؤمن عن ضرر عدم الإبلاغ أو التأخير فيه، وعادة الشركات جرت على النص على سقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين جزاءً على الإخلال، والسقوط طريق لانقضاء الحقوق، وهو في التأمين دفع يسمح للمؤمن برفض تنفيذ تعهده بالضمان رغم تحقق الخطر، لإخلال المؤمن له بالتزاماته عند وقوع الكارثة، **وهو جزاء خطير لأنه يترتب عليه فقد المؤمن له حقه في الضمان على سبيل العقوبة** .

شرط الصحة	المضمون
١- اتفاق خاص صريح	الأصل أن الإخلال لا يستبعد حتماً سقوط الحق؛ فالقواعد العامة في المسئولية العقدية لا ترتب هذا الجزاء، فالسقوط خروج على القواعد العامة، فيجب الاتفاق عليه صراحة.
٢- بارز ظاهر	إذا ورد بين الشروط المطبوعة، نصت المادة 3/750 مدني على أنه
٣- غير تعسفي	تدخل المشرع لوضع قيود على حرية المؤمن، ويبطل الشرط إذا ظهر تعسف، نصت المادة 750 مدني على أنه

1. **مخالفة القوانين واللوائح:** الشرط الذي يسقط الحق في كل مخالفة تعسفي؛ لأنه يترتب عليه في الأغلب سقوط الحق، حيث يغلب أن يقع الحادث بسبب مخالفة، فما الذي يبقى للمستأمن في تأمين المسئولية عن حوادث السيارات إذا أجيز للمؤمن الخروج من نطاق الضمان للأضرار التي ترجع لمخالفة لوائح المرور؟ ولهذا أبطل إلا إذا انطوت على جناية أو جنحة عمدية.
2. **التأخير في تبليغ السلطات:** يبطل في حالة التأخر لوجود عذر؛ لأنه طالما كان هناك عذر فالتمسك بالسقوط تعسف في استعمال الحق.
3. **التأخير في تقديم المستندات:** يبطل إذا كان التأخير لعذر مقبول.

معنى السقوط وأثره: عدم حصول المؤمن له على مبلغ التأمين بسبب عدم قيامه بواجب معين، وفي حالة السقوط: يحتفظ المؤمن بما قبض من أقساط، كما يقتضي ما حل ولم تدفع، أما المؤمن له فله الحق في مبلغ التأمين عن الحوادث التي وقعت ولم يقصر في التزاماته بها، وعن الحوادث المستقبلية ما لم ينته العقد لسبب آخر، وضياع حقه في السقوط على سبيل العقوبة المدنية، ليس جبراً عن ضرر، فلا شأن له بأحكام التعويض القضائي (عقدية أو تقصيرية) ولا بأحكام التعويض الاتفاقي.

أثر السقوط على العقد: إذا صح الشرط ترتب عليه حرمان المستأمن من مبلغ التأمين عند وقوع الخطر، والعقد لا ينتهي بالسقوط: يظل المستأمن ملزماً بأداء الأقساط وعدم استرداد ما دفعه، ويلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين عن الأخطار التي لم يشملها شرط السقوط، ما لم ينته العقد لسبب آخر.

MARA 01054054478

1. **التنازل:** تنازل المؤمن عن التمسك به — ويجب أن يكون واضحاً لا لبس فيه؛ لأن التنازل عن الحق لا يفترض.

2. **القوة القاهرة:** أن التأخر عن الإخطار كان بسبب القوة القاهرة أو الحادث الفجائي — كمرض عضوي أو نفسي.

3. **إصلاح الإخلال:** أنه أصلح ما بدأ منه من إخلال بالتزامه، وكان قد قدم في الميعاد بياناً صحيحاً عن الخسائر بعد أن قدم بياناً خاطئاً.

المطلب الرابع: دفع القسط:

المدين والدائن: القسط هو المقابل الذي يجب على المؤمن له أداؤه للمؤمن، وهو واجب في جميع أنواع التأمين، **ملاحظة:** في التأمين على الحياة يجوز للمؤمن له التحلل من دفعه بعد إخطار المؤمن بكتاب يرسله إليه، فتبدأ ذمته من دفع الأقساط اللاحقة.

أطراف الالتزام: **المدين أساساً:** المؤمن له، وقد يكون الملتزم به الخلف العام — كالوارث حين ينتقل الشيء المؤمن عليه إليه — أو الخلف الخاص — كالمشتري — أو من الغير، فيحق له الرجوع بالقسط على المدين طبقاً للقواعد العامة، **والدائن:** المؤمن، وقد يدفع القسط للوسيط إذا كان مفوضاً في قبضه.

1. **زمان الوفاء:** في الميعاد المتفق عليه، وتجرى العادة على تقديمه حتى يحدد المؤمن موقفه ويعد ميزانيته وحساباته السنوية على نحو منظم، وقد يتفق على الوفاء مرة واحدة — كما في التأمين ضد مخاطر النقل — أو على دفعات تيسيراً، وفي حالة وفاة المؤمن له لا يتغير الميعاد، وعلى الورثة الوفاء فيه.

2. **المكان:** الدين مطلوب لا محمول، فعلى الدائن السعي إلى محل إقامة المدين ومطالبته — أي يحق للمؤمن السعي إلى المؤمن له في موطنه، وقد يتفق على غير ذلك (كأن يكون الوفاء في موطن المؤمن)، وقد يجرى العرف على غير ذلك (كالقسط الأول)، وقد يتأخر المؤمن له فيعذره المؤمن فيلتزم بالأقساط المتأخرة في موطن المؤمن.

3 **الكيفية:** الأصل نقداً، وليس ما يمنع من قبول الوفاء بحوالة بريدية أو شيك أو سند إذني ما لم يتفق على خلاف، ويجوز بطريقة المقاصة إذا كان للمؤمن حقوق قبل المؤمن له، وللمؤمن طبقاً للقواعد العامة حبس مبلغ التأمين حتى يستوفي القسط المتأخر.

4 **الإثبات:** يتم إذا قام المؤمن أو مندوبه بقبضه، وغالباً ما يعطي المؤمن للمؤمن له مخالصة، ويجوز للمؤمن له إثبات الوفاء بالبينة إذا كانت قيمته لا تجاوز عشرين جنيهاً.

تجزئة القسط (الرأي الراجح): الأصل دفع الأقساط كاملة، لكن قد يُعقد التأمين لمدة سنة ثم يبطل أو يفسخ بعد ستة أشهر، فهل يلتزم بكامل القسط أم بنصفه، فيتجزأ؟ **الراجح في الفقه جواز التجزئة ما لم يتفق على خلافها**؛ لأنه لا يجوز للمؤمن بعد أن أنهى ضمانه في نصف المدة أن يحصل على القسط كاملاً، وإلا لكان إثراء بلا سبب، وقيل رداً: إن التجزئة قد تخل بحسابات المؤمن الذي بنى ضمانه على أساس فترة معينة، وقد تعجزه عن تغطية المخاطر، ومع هذا، **إذا كان القسط مستحقاً في أول السنة ووقع الخطر أثناءها، وجب دفع القسط السنوي كاملاً** حتى لو كان مجزأً؛ لأن وقوع الخطر على هذا النحو مثبت به ضمان المؤمن كاملاً، فله أن يستوفي القسط المستحق كاملاً، ولا تسري حينئذ قاعدة التجزئة، إذ هي خاصة بالأحوال التي ينتهي فيها ضمان المؤمن قبل أوانه — كالفسخ أو الإبطال قبل انتهاء المدة.

جزاء عدم الوفاء (القواعد العامة): لا نص خاص، وإنما القواعد العامة: للمؤمن المطالبة بالتنفيذ العيني الجبري أو الفسخ مع التعويض في أي من الحالتين إن كان له مقتضى، بعد إعذار المدين، ولما كان التنفيذ العيني الجبري يأخذ وقتاً قد يبقى فيه المؤمن ضامناً للخطر، وكان طلب الفسخ يخضع لتقدير القاضي ولا يحكم به إلا بعد وقت، فقد درجت الشركات على تضمين عقودها شرطاً فاسخاً صريحاً — أن العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى إعذار أو حكم عند عدم الوفاء بالقسط، وهو شرط جائز، لكنه في غاية الخطورة للمستأمن، خصوصاً إذا كان الوفاء في مقر الشركة، إذ قد لا ينتبه لميعاد الوفاء، وقد تشترط الشركات وقف التأمين في هذه الحالة:

عنصر وقف التأمين	الحكم
معناه	أن المؤمن لا يتحمل المخاطر التي تقع في مدة الوقف بسبب إخلال المؤمن له بدفع القسط، حتى لو سدد القسط بعد وقوع الخطر.

شروطه	لا يصح إذا كان الامتناع بعذر، فإذا امتنع أو تأخر لقوة قاهرة أو لخطأ المؤمن فلا محل للوقف.
آثاره	الوقف لا ينهي العقد، فالعقد يسري، لكن ضمان المؤمن للخطر يقف من وقت الامتناع إلى حين الدفع؛ فإذا وقع الخطر خلال هذه الفترة فلا ضمان على المؤمن، ويظل التزام المستأمن بدفع الأقساط المتأخرة، فأما إعفاؤه من الأقساط خلال الوقف فيختلف به حسابات المؤمن الذي عول على مجموع معين للأقساط يغطي به المخاطر المحتملة.
مدته	يظل العقد موقوفاً من وقت الامتناع عن الوفاء بالقسط المستحق وحتى دفع القسط مع المصاريف.
زواله	(1) دفع المؤمن له الأقساط المتأخرة مع المصاريف، (2) فسخ العقد، (3) نزول المؤمن عنه صراحة أو ضمناً — كإعطاء المستأمن مهلة جديدة لدفع القسط.
التأمين على الحياة	لا يوقف العقد إذا لم يقم المؤمن له بدفع القسط؛ لأن دفع القسط فيه اختياري ويظل المؤمن ضامناً للخطر، إنما يحق للمؤمن إلغاء التأمين أو تخفيض مبلغ التأمين، ولا يكون قابلاً لتخفيض التأمين ثم إحيائه إذا كان موقتاً، وللمؤمن له أن يطلب تصفية التأمين إذا دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل، بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع، ولا يكون قابلاً للتصفية إذا كان موقتاً.

2 المبحث الثاني: التزامات المؤمن – الالتزام بدفع مبلغ التأمين:

طبيعته ونشوئه: يلتزم المؤمن بتصفية آثار الخطر المؤمن ضده حال تحققه، أي بدفع مبلغ التأمين أو عوض التأمين على النحو المتفق عليه، **وهو التزام أساسي، لكنه احتمالي لا ينعقد إلا إذا حدث الخطر** ؛ فهو ينشأ في جانبه منذ لحظة الإبرام، أما تنفيذه فلا يتم إلا إذا تحقق الخطر أو حل أجل العقد، وقام المؤمن له أو المستفيد بتقديم البيانات والمستندات التي تثبت صحة ما يطالب به؛ إذ قبل هذا الوقت لا يحق له مطالبته بتنفيذ التزامه، (وقد سبق عند دراسة الأركان تناول تقدير مبلغ التأمين بالتفصيل في التأمين على الأشخاص والأضرار، فنحيل إليه،)

1. **المادة 1064 (المشروع التمهيدي):** "متى تحقق الخطر أو حل أجل العقد أصبح التعويض أو المبلغ المستحق بمقتضى عقد التأمين واجب الأداء بعد مضى ثلاثين يوماً من الوقت الذي يخطر فيه المؤمن بالبيانات التي تسمح بالتثبت من صحة ما يطلبه المؤمن له، ومدى ما يتمسك به من حقوق."

2. **المادة 751 مدني:** "لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا في الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه قانوناً."

صور تحقق الخطر: قد يتحقق دفعة واحدة — كأن تأتي النار على الشيء المؤمن عليه كلية، وقد يتكرر عدة مرات — كعدة حرائق متتالية لذات الشيء وفي كل مرة خسارة جزئية، أو تكرر حوادث السرقة، أو ارتكاب المؤمن له من المسئولية عدة حوادث أحدثت أضراراً بآخرين، وفي التأمين على الحياة: يكون واجب الأداء متى حل أجل العقد — في التأمين لحال الوفاة، حيث موت المؤمن له هو الأجل الذي ينتهي به العقد، ويصبح الالتزام واجب الوفاء من هذا التاريخ، وفي التأمين لحال البقاء يصبح واجباً متى حل الأجل المعين مع بقاء المؤمن له حياً عند هذا التاريخ.

من يُدفع له: المؤمن له أو من ينوب عنه، وقد يكون المستفيد شخصاً آخر عنه — كالتأمين على الحياة لمصلحة الزوجة والأولاد؛ يجب الوفاء للمستفيد سواء أكان الزوجة أو الأولاد، وقد يدفع للخلف العام كالوارث، أو للخلف الخاص الذي انتقلت إليه ملكية الشيء المؤمن عليه، وقد يدفع للدائن المرتهن إذا كان الشيء مرهوناً لمصلحته ونشر حقه أو أعلنه للمؤمن، وقد يدفع للمضرور في تأمين المسئولية فيما هو مستحق من تعويض قبل المؤمن له.

وقت الوفاء: تقضي القواعد العامة بأن الوفاء يجب أن يتم فوراً بمجرد ترتيب الالتزام نهائياً في ذمة المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقتضي بغير ذلك (م 1/346 مدني)، وانطلاقاً منها كان يتعين القول بأن المؤمن يجب عليه الوفاء بمجرد تحقق الخطر أو حلول الأجل المتفق عليه، فإن لم يحدد ميعاد وجب دفعه بدون تأخير.

الإثبات والامتياز والتقادم: للمؤمن له أو المستفيد أن يثبت وقوع الخطر المؤمن منه، وحقه من الحقوق الممتازة، ومحل الامتياز ما تحتفظ به شركات التأمين من أموال في جمهورية مصر العربية، **ويتقادم الحق في مبلغ التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه مستحقه بوقوع الخطر وبحقه في التأمين (م 752 مدني)**، ولا يجوز

MARA 01105405478

الاتفاق على تقصير المدة لأنها من النظام العام، ومثل هذا الاتفاق لا يكون لصالح المؤمن له أو المستفيد فيقع باطلاً (م 753 مدني).

⚠ **جزاء الإخلال بدفع المبلغ:** قد يمتنع المؤمن أو يتأخر، فيثبت لمستحق المبلغ الحق في المطالبة بالتنفيذ العيني الجبري — الحجز على أمواله وبيعها في المزاد العلني واقتضاء المبلغ منها، على أن للمؤمن حبس مبلغ التأمين إذا لم تتحدد خسائر المستأمن، ولا يجبر على دفع شيء ولو جزئياً، ولمستحق المبلغ المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى في نطاق المسئولية العقدية؛ وإذا كان المبلغ نقوداً كان التعويض فوائد تأخيرية لا تستحق إلا من تاريخ المطالبة القضائية طبقاً للقواعد العامة، وللمؤمن أن يخصم من مبلغ التأمين ما يكون دائناً به لمستحقه — كأقساط متأخرة أو قرض اقترضه — وفقاً لقواعد المقايضة.

MNARA 01105405478

MNARA

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الثالثة

دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ مدني (عقد التأمين) — هذا المقرر الحالي

الفقه المقارن (جنايات) — متاح بالتطبيق

النقود والمؤسسات المالية — متاح بالتطبيق

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثالثة

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478